

民法考试分章题库

第一章 民法概述

一、多项选择题

1、下列各项中，不可为我国民法渊源的是（BCD）。

A 最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》

B、民间订婚的习惯

C、上海市中级人民法院的民事判决

D、某大学教授的关于精神损害赔偿的专著

2、下列属于民法所说的财产的有（ABCD）。

A、土地 B、房屋 C、商标 D、商业秘密

3、下列社会关系属于民法调整的人格关系的有（ABC）。

A、生命权法律关系 B、健康权法律关系

C、姓名权法律关系 D、配偶权法律关系 **属于身份权**

4、下列社会关系属于民法的调整对象的有（ABC）。

A、自然人甲与自然人乙之间订立的电脑买卖合同关系

B、中国公民丙与中国公民丁之间缔结的婚姻关系

C、甲税务机关与自然人乙之间订立的电脑买卖合同关系

D、甲税务机关与自然人乙之间税款征收关系 **平等主体之间的关系**

二、名词解释

1、民法：民法是调整平等主体的自然人、法人、其他组织之间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。

2、民法的渊源：可以说民法的渊源是指民法产生的根源，这是从民法与它所调整的社会关系的关系讲的；也可以说民法的渊源是法官裁决民事案件的法源，即法官判案的法律根据。通说认为，**民法的渊源，是指民事法律规范的表现形式。共十项 宪法 习惯 最高人民法院的司法解释 民事基本法 民事单行法和其他有关民事的法律规范 法规 规章 判例与法理**

三、简答题

1、我国民法的渊源有哪些？

民法的渊源，是指民事法律规范的表现形式。我国民法的渊源包括：（1）制订法：宪法中的民法规范；民事法律；国务院制订发布的民事法规；地方性法规、自治法规、经济特区法规中的民事规范；国际条约中的民法规范。（2）非制订法：司法解释：最高法院所作的民事司法解释对各级人民法院处理民事案件具有约束力；习惯：只有经过最高人民法院通过指导性文件认可的习惯才可视为习惯法。值得注意的是，判例和法理在我国均不具有民法渊源的效力。

2、我国民法的适用范围包括哪些？

民法的适用范围包括对人的适用范围、空间适用范围和时间适用范围。民法对人的适用范围，就是法律规范对于哪些人具有法律效力。根据《民法通则》第8条规定，在中华人民共和国领域内的民事活动，适用中华人民共和国法律，法律另有规定的除外。关于自然人的规定，适用于在我国领域内的外国人、无国籍人，法律另有规定的除外。我国自然人、法人在国外发生的民事法律关系，一般适用所在地的法律规定，但法律另有规定的除外。

民法在空间上的适用范围，就是民法在哪些地方发生法律效力。一般而言，我国民法适用于我国领土、领空、领海，包括我国驻外使馆，以及在我国领域外航行的我国船舶。

民法在时间上的适用范围，是指民法生效时间和失效时间，以及民事法律规范对其生效前发生的民事法律关系有无溯及力。我国民事法律规范贯彻法律不溯及既往的原则，一般没有溯及力。但司法解释中另有规定的除外。

四、论述题

1、如何理解我国民法的调整对象？

1、（1）民法是调整平等主体的自然人、法人、其他组织之间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。（2）平等主体之间的财产关系是指平等主体之间以自愿为基础的具体的经济关系。其特征：第一，财产关系的主体处于平等的地位；第二，这种财产关系一般是在自愿的基础上发生的；第三，这种财产关系一般是有偿的。（3）平等主体之间的人身关系是指在平等主体之间发生的与人身不可分离、以人身利益为内容、不直接体现财产利益的社会关系。人身关系共分两类，一类是人格关系，一类是身份关系。人格关系是指民事主体本身所应具有的权利主体资格即因人格而产生的社会关系；身份关系是指基于身份而产生的社会关系。其特征：第一，这种人身关系的主体处于平等地位；第二，这种人身关系以特定的精神利益为内容；第三，这种人身关系与主体具有不可分性。

第二章 民法的基本原则

一、单项选择题

1、下列不属于民法基本原则的功能的是（C）。

A、指导功能 B、补充功能 C、惩罚功能 D、约束功能

2、下列现象中，违反民法平等原则的是（D）。

A、甲公民（年满25周岁）可以结婚，而乙公民（13周岁）不能结婚

B、甲公司（经登记为综合类证券公司）可以从事证券经纪业务，而乙公司（登记为房地产公司）则不能从事证券经纪业务

C、国家税务机关可以在税收征收法律关系中使用强制手段，无视纳税人的意志而依法进行税收征收

D、某市合同管理干部认为，在本市建筑工程的招标投标中，市委领导的亲戚具有优先的订立合同的权利

3、甲知其新房屋南面临地将建一高层楼房，佯装不知，将房屋售与乙。半年后，南面高楼建成，乙的房屋受不到阳光照射。此例中，甲违反了民法的哪一项原则？（D）

A、平等原则 B、自愿原则 C、公平原则 D、诚实信用原则

4、下列各项中，违反民法自愿原则的有（A）。

A、赵某在服装市场上询问一件衣服的价格之后，摊主强要其购买的行为

B、钱某与孙某自愿达成的移转抵押物占有的抵押合同不能产生抵押权设定的法律效果

C、李某申请安装电话被要求在一份已经拟好的格式合同上签字

D、周某（老烟民，熟知烟的价格）花 10 元钱从小贩吴某的手中购得红塔山香烟一条，经查，该烟为假烟

5、下列行为中，不违反禁止权利滥用原则的有（B）。

A、甲将自己废弃不用的汽车置于马路中央的行为

B、乙拒绝接受丁遗赠给其一台电脑的行为

C、丙于下午在自己的房间里唱卡拉 OK 直到凌晨影响邻居休息的行为

D、丁在自己承包的耕地上建坟的行为 只能用于耕地

二、名词解释

1、平等原则

平等原则是指当事人在民事活动中的法律地位平等。平等原则是民法区别于行政法律关系、刑事法律关系的重要标志。其具体含义包括：（1）民事主体资格（民事权利能力）平等。《民法通则》第 9 条、第 10 条规定，自然人从出生时起，到死亡时止具有民事权利能力，即具有民事主体资格。自然人的民事权利能力一律平等。（2）民事主体的地位平等。在各种具体的民事法律关系中，民事主体的法律地位一律平等。

（3）民事主体平等地享有权利，承担义务。民法所调整的社会关系本质上是商品经济关系，这种关系的性质决定了民事主体平等的享有权利，承担义务。（4）民事主体的民事权益平等地受法律保护，这是由民事主体的地位平等决定的。

2、自愿原则

自愿原则是指民事主体在从事民事活动时，体现自己的意志，作真实意思表示，通过自己的内心真实意愿来设立、变更和终止民事法律关系。其具体含义包括：（1）民法规范民事主体的行为方面，体现当事人

意思自治。(2) 民事主体根据自己的意愿设立、变更或者终止民事法律关系，他人不得非法干预。(3) 双方或多方的民事行为由当事人自愿协商。(4) 违反自愿原则的民事行为，不受法律保护 遗忘

3、公平原则

公平原则是指在民事活动中以利益均衡作为价值判断标准，用来衡量民事主体之间的物质利益关系，确定民事主体的民事权利义务及民事责任承担等。其具体含义包括：(1) 民法在规范民事主体的权利义务与责任的承担上，体现公平原则，兼顾各方当事人的利益。(2) 在法律适用上应贯彻公平原则，即当民法规范缺乏规定时，应根据公平原则来设立、变更和终止民事法律关系；当法律缺乏规定时，法官应根据公平原则做出合理的判决。

4、公序良俗原则

公序良俗原则是指民事主体的行为应当遵守公共秩序，符合善良风俗，不得违反国家的公共秩序和社会的一般道德。公序良俗是公共秩序与善良风俗的简称。公共秩序是指国家社会的存在及其发展所必需的一般秩序；善良风俗是指国家社会的存在及其发展所必需的一般道德。公序良俗原则是大陆法系各国民法典通行的原则。我国《民法通则》第7条规定，民事活动应当尊重社会公德，不得损害社会公共利益，破坏国家经济计划，扰乱社会经济秩序。该条规定的原则与公序良俗原则的逻辑内涵基本一致。

三、简答题

1、如何理解民法基本原则的含义？

民法基本原则是民事立法、民事司法和民事活动的基本准则，是效力贯穿于整个民法制度和规范之中的民法根本规则。其含义包括：(1) 民法基本原则是指导民事立法、民事司法和民事活动的基本准则。民法基本原则是民事法律规范的出发点和归宿，是民事司法的基本准绳，是民事活动的基本规则。(2) 民法基本原则是贯穿于各种民事法律制度的基本准则。(3) 民法基本原则是民法调整的社会关系与民法观念的综合反映。法律是它所调整的社会经济、文化和人们生活的反映，不同时期不同国家的社会制度不同，法律原则也有所不同。

2、诚实信用原则的含义包括哪些？

诚实信用原则是指民事主体在从事民事活动中应遵循诚实守信的原则，以求达到当事人之间利益和当事人利益与社会利益之间的平衡。其具体含义包括：(1) 民事主体在民事活动中依诚实信用的方式行使权利和履行义务；(2) 在合同解释上，应依诚实信用原则；(3) 依诚实信用原则弥补法律规定之不足。诚实信用原则和公平原则一样赋予司法人员一定的自由裁量权，使其在法律规定不足时，从民法的目的出发，依诚实信用原则，公平合理地解决纠纷。

四、论述题

1、试述民法的基本原则的功能。

1、民法基本原则的功能，是指民法基本原则在民事立法、民事司法和民事活动中的作用。民法基本原则的功能是：(1) 指导功能：民法的基本原则是指导民事立法的基本准则；民法的基本原则是指导民事司法的基本准则；民法的基本原则是进行民事活动的基本准则。(2) 约束功能：民法的基本原则对民事立法、民事司法和民事活动都有约束力。我国《民法通则》规定的民法基本原则对民事单行法、民事特别法均有约束力。民事司法和民事活动都不能违反民法的基本原则。(3) 补充功能：在具体民法规范缺乏规定，

对某些民事关系用类推也不能解决的情况下，司法机关可以直接根据民法的基本原则处理民事纠纷，民事主体也可以直接依据民法的基本原则进行民事活动。

第三章 民事法律关系

一、单项选择题

1、下列各项中，不属于民事法律关系的要素的是（ D ）。

A、主体 B、客体 C、内容 D、形式

2、下列不能成为民事法律关系的客体的是（ B ）。

A、塘中的鱼 B、夜空中的星星 C、不作为 D、企业的名称权

3、下列不属于形成权的是（ C ）。形成权得以自己的意思而使法律关系形成的权利

A、撤销权 B、解除权 C、债权请求权 D、追认权

4、人身权属于（ B ）。

A、请求权 B、支配权 C、抗辩权 D、形成权

5、双务合同当事人享有的同时履行抗辩权（ b ）。

A、只为永久性抗辩权，不为延期性抗辩权

B、只为延期性抗辩权，不为永久性抗辩权

C、既为永久性抗辩权，又为延期性抗辩权

D、或为永久性抗辩权，或为延期性抗辩权

6、依据民事权利的效力范围，民事权利可分为（ b ）。

A、财产权与人身权 B、绝对权与相对权

C、主权利与从权利 D、请求权与形成权

7、民事义务依民事义务人行为的方式为标准，可分为（ AB ）。

A、积极义务与消极义务 B、法定义务与约定义务

C、法定义务与积极义务 D、约定义务与消极义务

8、依我国《担保法》规定，当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任，此种责任为（ b ）。

A、单独责任 B、按份责任 C、并行的连带责任 D、补充的连带责任

二、多项选择题

1、下列可以为民事法律关系的主体有（ ABCD ）。

A、聋哑人 B、合伙企业 C、机关法人 D、个体工商户

2、下列权利中，属于财产权的有（ ）。

A、物权 B、债权 C、亲权 D、荣誉权

3、甲乙签订合同，由甲出售一头水牛给乙，乙已经付款，现履行期已到，则乙对甲享有的权利为（ BD ）。

A、绝对权 B、相对权 仅向特定的人行使

C、期待权 D、既得权

4、紧急避险属于（ ）。

A、公力救济 B、私力救济 C、自助行为 D、自卫行为

5、某甲在路上遇见情敌某乙，遂叫某丙和某丁共同将某乙殴打一顿，某乙治疗伤病花去医药费 500 元。某甲、某丙和某丁应对某乙承担的责任为（ ad ）。

A、侵权责任 B、合同责任 C、单独责任 D、共同责任

6、下列各项中，属于民事责任承担方式的有（ abcd ）。

A、停止侵害 B、消除影响 C、赔礼道歉 D、赔偿损失

三、名词解释

1、民事法律关系 2、民事法律关系的事实构成 3、民事法律事实

4、民事权利 5、支配权 6、请求权 7、形成权 8、抗辩权

9、民事义务 10、民事责任 11、按份责任 12、连带责任 13、补充责任

四、简答题

1、民事法律关系的特征有哪些？

2、民事义务的分类有哪些？

3、民事责任的法律特征有哪些？

五、论述题

1、试述民事权利的分类。

2、试述民事责任与刑事责任、行政责任的区别。

参考答案

一、单项选择题

1、D 2、B 3、C 4、B 5、B 6、B 7、A 8、D

二、多项选择题

1、ABCD 2、AB 3、BD 4、BD 5、AD 6、ABCD

三、名词解释

1、民事法律关系是由民事法律规范所调整的社会关系，也就是由民事法律规范确认和保护的社会关系。其含义包括：（1）民事法律关系是民事法律规范调整财产关系和人身关系所形成的社会关系。（2）民事法律关系是基于民事法律事实而形成的具体的社会关系。（3）民事法律关系是以民事权利义务为内容的社会关系。

2、民事法律关系的**事实构成**是指民事法律关系的产生、变更或者消灭有时需要两个或者两个以上的法律事实为根据，这种引起民事法律关系产生、变更或者消灭的两个以上的法律事实的总和，即为民事法律关系的事实构成。

3、民事法律事实是指能够引起民事法律关系发生、变更或者消灭的客观现象或事实，简称法律事实。民事法律事实可分为行为和自然事实两类。行为事实是指由人的行为所构成的事实；自然事实是指非人的行为所构成的事实。

4、民事权利是民事法律规范赋予民事主体满足其利益的法律手段。民事权利是民事法律规范规定或确认的民事主体的权利。权利人可以在法定范围内享有某种利益或实施一定的行为。

5、支配权，是指权利人可以直接支配权利客体，而具有排他性的权利。

6、请求权，是指权利人要求他人为特定行为(作为或不作为)的权利。

7、形成权，是指权利人依自己单方的意思表示，使民事法律关系发生、变更或消灭的权利。

8、抗辩权，是指对抗他人行使权利的权利。根据抗辩权作用的不同，抗辩权又可分为永久性抗辩权和延期性抗辩权。永久性抗辩权，是指权利人有永久阻止他人行使请求权的权利。延期性抗辩权，是指权利人在一定时间一定条件下可以提出抗辩，而不是永久可以抗辩。

9、民事义务是指民事法律规范规定或当事人依法约定，义务人为一定的行为或不行为，以满足权利人的利益的法律手段。

10、民事责任是指民事主体违反合同义务或法定民事义务而应承担的法律后果。

11、按份责任是指多数当事人按照法律的规定或者合同的约定各自承担一定份额的民事责任，各责任人之间没有连带关系。

12、连带责任是因违反连带债务或者共同实施侵权行为而产生的责任，各个责任人之间具有连带关系。所谓连带关系是指各个责任人对外都不分份额、不分先后次序地根据权利人的请求承担责任。

13、补充责任，是指在责任人的财产不足以承担其应负的民事责任时，由有关的人对不足部分依法予以补充的责任。

四、简答题

1、民事法律关系是由民事法律规范所调整的社会关系，也就是由民事法律规范确认和保护的社会关系。其特征：（1）民事法律关系是平等主体之间的法律关系。民法调整的是平等主体之间的财产关系和人身关系。民法调整的社会关系的平等性质决定了民事法律关系的平等性。（2）民事法律关系主要是民事主体自主形成的法律关系。在通常情况下，民事法律关系主要是民事主体在自主自愿的基础上形成的。贯彻当事人意思自治的原则，这是民事法律关系区别于其他法律关系的又一特征。（3）民事法律关系主体的权利义务通常是对等的、相互的。民事法律关系从整体和实质上讲，每个民事主体既作为权利主体享有权利，同时又作为义务主体负有义务。这种权利义务是对等的、相互的，如合同关系中当事人之间的权利义务，一般是对等的。当然，有些民事法律关系，权利主体只享有权利，义务主体只负有义务，不具有对等性，如人格权法律关系。

2、民事权利与民事义务是相对应、相关联的，因此民事权利的分类与民事义务的分类也有相关联相类似之处。除此之外民事义务还有其相对独立的分类，主要分类如下：

（1）法定义务与约定义务。以民事义务发生的根据为标准，可分为法定义务与约定义务。法定义务，是指民事法律规范规定的民事主体应负的义务。约定义务，是由当事人协商确定的义务。约定的义务不违法即受法律保护。

（2）积极义务与消极义务。以民事义务人行为的方式为标准，可分为积极义务与消极义务。积极义务，是指义务人应作出一定积极行为的义务，又称作为义务。包括给付财物、完成工作、提供劳务等。消极义务，是指义务人必须为消极行为或容忍他人的行为，又称不作为义务。例如，不侵害他人的物权、人身权的义务，容许他人在自己所有或使用的土地上通过或作业的义务等。

3、民事责任是指民事主体违反合同义务或法定民事义务而应承担的法律后果。其特征主要有：（1）民事责任以民事主体违反民事义务侵害他人的民事权益为前提。民事义务是民事责任发生的前提，没有民事义务就没有民事责任。《民法通则》第5条规定：“公民、法人的合法的民事权益受法律保护，任何组织和个人不得侵犯。”权利含有利益在内，某种利益不被法律明文规定的民事权利所涵盖，而受法律保护的，行为人侵害了他人的这种利益，也应承担民事责任；（2）民事责任以一方当事人（加害人）**赔偿**对另一方当事人（受害人）的损害为主要目的；（3）民事责任可以由当事人在**法律允许的范围**内协商，民事责任的这一特征，是由民法的平等、自愿原则所决定。

五、论述题

1、民事权利按照不同的标准有以下主要分类：

（1）财产权与人身权。以民事权利的所体现的利益的性质为标准，可分为财产权与人身权。财产权，是以财产利益为内容的权利。所谓财产利益，通常是具有交换价值或使用价值的，可以用货币计算其价值，

可以依法转让的利益。人身权，是以人身利益为内容，与权利主体不可分离的权利。人身权又分为人格权和身份权。

(2) 支配权、请求权、形成权、抗辩权。以民事权利的作用为标准，可分为支配权、请求权、形成权、抗辩权。支配权，是指权利人可以直接支配权利客体，而具有排他性的权利。一方面，权利人可以直接支配权利客体，以满足自己的利益需要，而不需要他人行为的介入。另一方面，权利人可禁止他人妨碍其支配，而具有排他性。物权是典型的支配权。请求权，是指权利人要求他人为特定行为(作为或不作为)的权利。请求权的权利人不能对权利客体直接支配，必须通过义务人的作为或不作为，才能实现其权利。形成权，是指权利人依自己单方的意思表示，使民事法律关系发生、变更或消灭的权利。抗辩权，是指对抗他人行使权利的权利。根据抗辩权作用的不同，抗辩权又可分为永久性抗辩权和延期性抗辩权。永久性抗辩权，是指权利人有永久阻止他人行使请求权的权利。延期性抗辩权，是指权利人在一定时间一定条件下可以提出抗辩，而不是永久可以抗辩。抗辩权的作用在于“对抗”、“反对”，阻止他人行使权利，但他人的权利并不因此而消灭。

(3) 绝对权与相对权。以民事权利的效力范围为标准，可分为绝对权与相对权。绝对权，是指无须通过义务人实施一定的行为即可实现，并可以对抗不特定人的权利。人身权、物权、知识产权、继承权等属于绝对权。**绝对权有两个特征**：一是权利人无须通过义务人的行为，自己可以直接实现其权利；二是义务主体是不特定的，因此又称对世权。相对权，是指必须通过义务人实施一定的行为才能实现，只能对抗特定的人的权利。债权属于相对权。**相对权有两个特征**：一是权利人自己不能直接实现其权利，必须通过义务人的行为其权利才能实现；二是只能请求特定的人为一定行为，该权利只能对抗特定的人，因此，又称对人权。

(4) 主权利与从权利。以民事权利的依存关系为标准，可分为主权利与从权利。主权利是相互关联的两个以上的民事权利中，能够独立存在的权利。从权利是不能独立存在而从属于主权利的权利。主权利与从权利的**主从关系**主要体现在：(1) 主权利存在，从权利才能存在；主权利因履行、抵销、免除等原因而消灭时，从权利同时消灭；(2) 从权利不能与主权利分离而转让。

(5) 专属权与非专属权。以民事权利与主体的关系为标准，可分为专属权与非专属权。专属权，是指专属于某特定民事主体的权利。人格权、身份权均为专属权。专属权的性质决定专属权**不得让与和继承**，但也有例外，例如企业的名称权。非专属权，是指不属于某特定民事主体专有的权利。非专属权可以让与和继承。一般财产权多属非专属权。但矿藏、水流的所有权归国家，为专属权。

(6) 既得权与期待权。以民事权利是否已经取得为标准，可分为既得权与期待权。既得权，是指权利人已经取得而可以实现的权利。期待权，是指将来有取得与实现的可能性的权利。期待权是当事人尚未取得，必须有一定的事实发生才能取得的权利。例如附期限的权利、附条件的权利、继承开始前法定继承人的权利、保险合同受益人的权利等。

(7) 原权利与救济权。**原权利是民事法律关系中存在的权利**。如基于有体物而发生的所有权，基于合同而发生的债权等。**救济权是原权利受到侵害**，或有受到侵害的现实危险时而发生的权利。如当所有权受到侵害时，所有权人有停止侵害请求权，也有权提起诉讼。如果原权利未受到侵害或没有受到侵害的现实危险，就不会发生救济权。救济权是基于原权利而派生的权利，其目的在于救济被侵害的原权利。其实质是权利受到侵害后权利人请求侵权行为人或不履行债务的人承担民事责任。

2、民事责任与刑事责任、行政责任的区别主要表现在以下几个方面：

(1) 责任产生的根据不同。民事责任既可以由法律规定，又可以由当事人约定。刑事责任和行政责任则只能通过刑事法律规范或行政法律规范规定，而不能由当事人自行约定。

(2) 责任的法律强制程度不同。与民事责任相比，刑事责任、行政责任的强制性程度较强，主要表现在：第一，它们必须由特定的国家机关强制追究，当事人不得和解；第二，非经法定程序，任何人不得赦免或拖延刑事责任或行政责任的执行。民事责任的强制性较弱，这主要表现在当事人可以在法律允许的范围内自行协商解决，权利人可以放弃自己的权利或减免对方的责任。

(3) 责任的目的是性质不同。民事责任的目的主要在对已经造成的权利损害和财产损失给予填补和救济，使其恢复到未受损害的状态，表现出某种补偿性和恢复原状性；刑事责任和行政责任的目的，则主要是通过通过对罪犯和行政违法行为人的惩戒和处罚，来达到一般预防的目的，表现出某种惩罚性和教育性。

(4) 责任方式不同。《民法通则》规定了 10 种民事责任形式，其中大多数是财产责任。刑事责任中虽然也有罚金、没收财产等财产刑，但刑事责任的主要形式是剥夺或限制罪犯的人身自由的自由刑和剥夺罪犯生命的生命刑。行政责任的主要形式则主要是警告、记过、拘留、罚款、开除等。尽管刑事责任和行政责任中都存在着一些财产责任，但与民事责任中的财产责任不同的是，承担刑事责任或行政责任的财产要上缴国家，归国家所有，而承担民事责任的财产则主要用来赔偿权利人遭受的损失，归个人所有。

(5) 责任的构成要件不同。首先，在主观方面，民事责任分过错责任和无过错责任两种。刑事责任没有过错与无过错之分。其次，客观方面，民事责任的构成一般要有损害的发生即损害事实的存在，行为人的行为如果没有造成权利人权利的损害，那么行为人一般不负法律责任；刑事责任与行政责任则不同，有时行为人的行为虽然没有造成实际的损害，但根据行为的社会危害性，行为人仍然要承担刑事责任。第三，责任主体的不同。刑事责任与行政责任都奉行一个基本的原则，即行为人对自己的行为负责；民事责任的承担则与之不同，在有些情况下，民事主体要对他人的民事行为负责，如雇主对雇佣人的行为负责，监护人对被监护人的行为负责等等。

第四章 自然人

一、单项选择题 1、B 2、D 3、C 4、C 5、A 6、B 7、C 8、C

9、C 10、A 11、D

1、依据我国现行法规定，自然人的民事权利能力始于（ ）。

A、受孕 B、出生 C、年满 10 周岁 D、年满 18 周岁

2、张家为其孙子张名的出生日期犯愁。其母记得是 8 月 27 日傍晚出生，医院的接生记录簿记载的是 8 月 28 日，医院的出生证上记载的是 8 月 29 日，其户口簿上记载的是 8 月 30 日。依法，张名的出生日期为（ ）。

A、8 月 27 日 B、8 月 28 日 C、8 月 29 日 D、8 月 30 日

3、依照我国现行法，下列人中属于限制民事行为能力或者无民事行为能力的人是（ ）。

A、聋子 B、瞎子 C、傻子 D、瘸子

4、李某年龄 16 周岁，接受叔叔遗赠 10 万元，靠此款丰衣足食，李某（ ）。

A、为完全民事行为能力人 B、视为完全民事行为能力人

C、为限制民事行为能力人 D、为无民事行为能力人

5、甲村公民孙某，将其户口从甲村迁出，欲落到乙村，还未落到乙村，经朋友劝说，往深圳打工。深圳打工十个月，因工地上出现事故受伤，被送往北京某大医院治疗已达1年零4个月。依法孙某应以（ ）为住所地。

- A、甲村 B、乙村 C、深圳 D、北京

第十五条 公民以他的户籍所在地的居住地为住所，经常居住地与住所不一致的，经常居住地视为住所

9. 公民离开住所地最后连续居住一年以上的地方，为经常居住地。但住医院治病的除外。
公民由其户籍所在地迁出后至迁入另一地之前，无经常居住地的，仍以其原户籍所在地为住所。

6、小明是5周岁的未成年人，下列关于他的监护人的论述中，错误的是：

- A、如果小明的父母离婚了，他们仍然是小明的法定监护人
B、如果小明的父母离婚并且都不愿担任其监护人，人民法院应指定他们中的一个为小明的监护人
C、如果小明没有父母，其祖父母担任其监护人是他们的法定义务
D、如果小明只有叔叔和姑姑，他的叔叔和姑姑可以协议担任他的监护人

7、南方某村公民甲12岁，父母双亡，祖父母年过80岁，无兄姐，其他亲属中仅有堂叔愿意也有能力担任其监护人，依法应取得（ ）同意。

16. 对于担任监护人有争议的，应当按照民法通则第十六条第三款或者第十七条第二款的规定，由有关组织予以指定。未经指定而向人民法院起诉的，人民法院不予受理。

- A、甲住所地的居民委员会 B、人民法院
C、甲住所地的村民委员会 D、祖父母

8、依《民法通则》，监护人只有在（ ）情况下，才能处分被监护人的财产。

- A、征得被监护人的同意 B、经被监护人所在单位批准
C、为了被监护人的利益 D、经法院判决认定

9、自然人在战争期间下落不明的，申请其宣告死亡应经过的时限是（ ）。

- A、2年 B、3年 C、4年 D、5年

10、因意外失踪，利害关系人申请失踪人为宣告死亡人的，人民法院寻找失踪人的公告期为（ ）。

- A、3个月 B、6个月 C、9个月 D、1年

11、甲于1995年2月1日失踪，其妻乙于1999年7月3日向法院申请宣告甲死亡，法院发出一年公告后，于2000年8月4日判决宣告甲死亡。则依法，甲的死亡日期为（ ）。

A、1995 年 2 月 1 日

B、1999 年 7 月 3 日

C、2000 年 7 月 3 日

D、2000 年 8 月 4 日

36. 被宣告死亡的人，判决宣告之日为其死亡的日期。判决书除发给申请人外，还应当在被宣告死亡的人住所地和人民法院所在地公告。

二、多项选择题

1、依照我国现行法，判断限制民事行为能力人所从事的行为是否与其年龄、智力、精神健康状况相适应，应依据（ ）进行。 1、ABC 2、ABCD 3、ABCD 4、ABC 5、AC

A、行为与本人生活相关联的程度

B、本人的智力或精神状况能否理解其行为，并预见其行为后果

C、行为涉及的财产数额

D、行为的方式

2、依据我国《民法通则》规定，有权指定未成年人的监护人的有关组织包括（ ）。

A、未成年人父亲所在单位

B、未成年人母亲所在单位

C、未成年人住所地的居民委员会

D、未成年人住所地的村民委员会

3、依照我国现行法，可以担任精神病人的监护人的有关组织包括（ ）。

A、精神病人所在单位

B、精神病人住所地的居民委员会

C、精神病人住所地的村民委员会

D、精神病人住所地的民政部门

4、监护终止的原因主要有（ ）。

A、被监护人获得完全民事行为能力

B、监护人或被监护人死亡

C、监护人丧失民事行为能力

D、监护人自行辞去监护

5、自然人甲为一精神病人，因离家出走 2 年多，对是否申请其为宣告失踪人意见不一，下列人员及组织中，有权为申请人的有（ ）。

A、乙，某盲人按摩院的按摩师，因甲尚欠其按摩费 200 元而主张申请

B、丙，甲之子，14 岁，但很懂事，主张申请以保护甲的财产

C、丁，甲之父，年 80，为甲之监护人

D、戊，甲之叔，30 岁，为机关公务员

三、不定项选择题

(一)

1990 年，某幼儿班聘请某甲担任幼儿班教师。1991 年 2 月 15 日上午 9 时左右，幼儿班课间休息时，某甲离校打电话，几个幼儿在教室里的火炉旁烤火。其中两人某乙（5 岁）和某丙（4 岁）因争夺位置而打斗，某乙用石块将某丙头部打破，而某丙则把某乙按在火炉上，某乙被烫伤。为此，某丙花去医药费 500 元，某乙花去医药费 5000 元。为此发生纠纷，请回答下列问题。

1、 某乙的医药费应如何承担？

- A、由某甲承担
- B、由某丙的监护人承担
- C、主要由某丙的监护人承担，某幼儿园承担适当赔偿责任
- D、主要由幼儿园承担，某丙的监护人承担适当赔偿责任

2、 关于某丙的医药费承担，下列说法中，错误的是

- A、 幼儿园承担
- B、某乙的监护人承担
- C、某乙的监护人承担主要责任，某甲承担适当赔偿责任
- D、 幼儿园承担主要责任，某乙的监护人承担适当赔偿责任

3、在某乙之父向人民法院提起的诉讼中，有关本案当事人的诉讼地位表述正确的是

- A、某乙之父为原告
- B、某乙为原告
- C、某丙、某幼儿园为共同被告
- D、某丙、某丙之父、某幼儿园、某甲为共同被告

4、某丙之父行使侵权行为之债的请求权，其诉讼时效期间为

- A、1 年 B、2 年 C、最长不超过 20 年 D、6 个月

四、名词解释

- 1、自然人 2、自然人的民事权利能力 3、自然人的民事行为能力
- 4、监护 5、宣告失踪 6、宣告死亡

五、简答题

- 1、自然人民事行为能力的种类有哪些？
- 2、监护人的职责有哪些？
- 3、宣告失踪应具备哪些条件？
- 4、宣告死亡应具备哪些条件？
- 5、简述宣告死亡的法律后果。

六、论述题

- 1、试述未成年人监护人的设立。

七、案例分析题

1、张某今年只有 17 岁，在本镇的啤酒厂做临时工，每月有 600 元的收入。为了上班方便，张某在镇里租了一间房。7 月份，张某未经其父母同意，欲花 500 元钱从李某处买一台旧彩电，此事遭到了其父母的强烈反对，但张某还是买了下来。10 月，张某因患精神分裂症丧失了民事行为能力。随后其父找到李某，认为他们之间的买卖无效，要求李某返还钱款，取回彩电。

请问：此买卖合同是否有效？为什么？

2、渔民赵某于 1992 年出海打鱼，遇风浪一直未归。1998 年其妻钱某不得已向法院申请宣告其死亡。赵某有两个孩子，分别为赵甲、赵乙，赵某夫妇有房屋 6 间，渔船一条（已经随赵某失踪而灭失了），摩托车一辆。法院依法作出判决后，赵某留下的遗产开始继承。房屋一间由其父亲继承，其余财产均由钱某和赵甲、赵乙继承。赵某死后，钱某生活十分困难，1999 年，钱某将摩托车卖给了同村的孙某。后迫于生活压力，钱某又将赵乙送给李某夫妇作为养子。2000 年，钱某改嫁给周某。这件事情让赵某的父亲无法理解，经劝阻无效后，向法院提出要求自己作为赵甲的监护人，理由是钱某作为赵甲的监护人对其不利。不久，周某死亡。2001 年，赵某回来了，原来当时被海风刮到 A 国，失去记忆，现被送回。请回答下列问题：

- （1）赵某的父亲是否有权请求人民法院变更赵甲的监护权？为什么？
- （2）赵某是否有权要求其父亲返还继承的一间房屋？为什么？
- （3）赵某是否有权要求孙某返还摩托车？为什么？
- （4）如果钱某对赵某仍然有感情，赵某与钱某的婚姻关系能否自动恢复？为什么？
- （5）赵某是否有权要求李某夫妇解除与赵乙的收养关系？为什么？

参考答案

一、单项选择题

1、B 2、D 3、C 4、C 5、A 6、B 7、C 8、C

9、C 10、A 11、D

二、多项选择题

1、ABC 2、ABCD 3、ABCD 4、ABC 5、AC

三、不定项选择题

(一) 1、C 2、ABCD 3、BC 4、A

四、名词解释

1、自然人是基于自然规律出生的人。自然人与公民这两个概念既有区别又有联系，公民是指取得一国国籍并根据该国宪法和法律规定享有权利和承担义务的人。凡公民均为自然人，但自然人不一定是一国公民。

《民法通则》沿用前苏联民法理论，用“公民”概念，未直接用“自然人”；《合同法》采用“自然人”概念，不再用“公民”。我国《民法通则》使用的公民概念，与自然人概念意义相同，但自然人的概念比公民概念更周延。

2、自然人的民事权利能力是指自然人依法享有民事权利和承担民事义务的资格。自然人的民事权利能力始于出生，与自然人的年龄没有关系，自然人的民事权利能力终于死亡。

3、自然人的民事行为能力是指自然人能以自己的行为取得民事权利承担民事义务的资格。自然人的民事行为能力以其意思能力为前提，也就是自然人可以判断自己的行为后果的能力，民事行为能力是与民事责任能力相对应的。

4、监护是对未成年人和精神病人的人身、财产及其他合法权益进行监督和保护的一种民事法律制度。在我国，监护只对主要是针对未成年人和精神病人设立的一项法律制度，其目的在于保护他们的人身、财产和其他合法权益。

5、宣告失踪是指自然人离开自己的住所，下落不明达到法定期限，经利害关系人申请，由人民法院宣告其为失踪人的法律制度。宣告失踪是对一种不确定的自然事实状态的法律确认，目的在于结束失踪人财产关系的不确定状态，保护失踪人的利益和利害关系人的利益。

6、宣告死亡是指自然人下落不明达到法定期限，经利害关系人申请，人民法院宣告其死亡的法律制度。宣告失踪制度的目的与宣告死亡制度的设置目的不同。宣告失踪旨在解决失踪人的财产管理问题，但不能解决因失踪人生死不明而引起的民事关系的不确定问题，而宣告死亡制度使这一问题得到解决。宣告失踪制度重在保护失踪人的利益，而宣告死亡制度重在保护被宣告死亡人的利害关系人的利益。

五、简答题

1、依《民法通则》规定，按照不同年龄阶段和理智是否正常，将自然人的民事行为能力分为三类：完全的民事行为能力、限制的民事行为能力和无民事行为能力。

(1) 完全的民事行为能力是指自然人通过自己独立的行为行使民事权利、承担民事义务的能力。十八周岁以上的自然人是成年人，具有完全的民事行为能力，可以独立进行民事活动，是完全民事行为能力

人。十六周岁以上不满十八周岁的自然人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。

(2) 限制民事行为能力又称不完全民事行为能力，是指自然人在一定范围内具有民事行为能力，超出一定范围便不具有相应的民事行为能力。限制民事行为能力的自然人包括两类，10周岁以上的未成年人和不能完全辨认自己行为后果的精神病人。限制民事行为能力人只能进行与其年龄、智力、精神健康状况相适应的民事行为，其他比较复杂或重大的民事行为应由其法定代理人代理或征求其法定代理人的同意后进行。

(3) 无民事行为能力是指自然人不具有以自己的行为取得民事权利和承担民事义务的能力。不满十周岁的未成年人和不能辨认自己行为的精神病人是无民事行为能力人，由他们的法定代理人代理民事活动。但在实践中，不满十周岁的未成年人，也可以进行与他的年龄、智力相适应的民事活动；不能辨认自己行为的精神病人应经利害关系人申请，由人民法院根据司法鉴定机构或医院所作的鉴定宣告其为无民事行为能力人，由其法定代理人代理民事活动。

2、根据《民法通则》第18条的规定，监护人的职责主要有：

(1) 保护被监护人的身体健康。监护人应保护被监护人的身体健康和人身安全，防止被监护人受到不法侵害。

(2) 照顾被监护人的生活。监护人在日常生活方面必须给被监护人以必要的关心、照料。

(3) 对被监护人进行管理和教育。对被监护人要进行监督和管理，防止他们受到伤害或侵害他人利益。

(4) 保护和管理被监护人的财产。对于被监护人财产的经营和处分，监护人应尽善良管理人的注意。非为被监护人的利益，监护人不得处分其财产。

(5) 代理被监护人进行民事活动。无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的法定代理人。

(6) 代理被监护人进行诉讼。在被监护人的合法权益受到侵害或者与他人发生争议时，监护人应当代理被监护人进行诉讼，以维护其合法权益。

(7) 监护人应当承担民事责任。监护人不履行监护职责或者侵害被监护人合法权益的，应当承担民事责任，给被监护人造成财产损失的，应当承担赔偿责任。

3、宣告失踪的法律条件应具备如下条件：(1) 自然人离开自己的住所或居所没有任何音讯且这种状态持续时间满2年，战争期间下落不明的，下落不明的时间从战争结束之日起计算。(2) 经利害关系人申请，**利害关系人**是指下落不明人的**近亲属**或对该人负有监护责任的人以及该人的债权人和债务人，应当向失踪人最后居住地人民法院提出申请。(3) 由人民法院判决宣告失踪，人民法院依审判程序进行审理，认为情况属实的依法判决宣告公民失踪。在审理过程中应发出寻找失踪人的公告，公告期间为3个月。

4、宣告死亡的法律条件应具备如下条件：(1) 自然人下落不明必须满4年，在意外事故的情况下，自然人下落不明的时限为2年；(2) 经利害关系人申请；(3) 由人民法院判决宣告失踪，人民法院依审判程序进行审理，认为情况属实的依法判决宣告公民死亡。在审理过程中应发出寻找失踪人的公告，公告期间为1年。

5、宣告死亡的法律后果有：自然人宣告死亡应发生与自然人自然死亡相同的效力，即宣告死亡人丧失民事主体资格，其民事权利能力和民事行为能力终止；其原先参加的民事法律关系归于消灭；其婚姻关系自

然解除；其个人合法财产变为遗产开始继承。但宣告死亡只是依法对失踪人死亡的推定，有民事行为能力的人在**被宣告死亡期间实施的民事法律行为仍然有效。其中自然死亡前实施的民事法律行为与被宣告死亡引起的法律后果相抵触的，则以实施的民事法律行为为准。**

六、论述题

1、监护是对未成年人和精神病人的人身、财产及其他合法权益进行监督和保护的一种民事法律制度。未成年人监护人的设立情况如下：（1）父母为未成年人的当然法定监护人。这种监护是一种法定监护。这种监护关系因出生而开始，而不必另有原因。父母分居或父母离异，其监护人的资格不受影响。但父母一方或双方作为监护人对未成年人明显不利的，人民法院可以取消父母一方或双方担任监护人的除外。父母因正当理由，不能亲自履行监护职责，我国司法实践中也允许父母委托他人代为履行部分或全部监护职责，但父母仍为法定监护人。

（2）除父母之外的未成年子女的法定监护人。未成年子女的父母双亡或丧失监护能力或被取消监护人资格的，由下列有监护能力的人担任监护人：第一，祖父母、外祖父母；第二，成年兄、姐。他们担任监护人是法定义务。

（3）未成年人的其他亲属、朋友担任监护人。未成年人的父母双亡，又没有祖父母、外祖父母以及成年兄、姐的，由未成年人的其他亲属朋友担任监护人，如叔、大伯、姨、姑、舅等。他们担任监护人不是法定义务。他们担任监护人除应具有监护能力外，还应具备两个条件：一是他们愿意担任监护人，二是应得到未成年人父母所在单位或未成年人住所地的居民委员会或村民委员会的同意。

（4）有关组织担任未成年人的监护人。未成年人没有上述法定监护人，也没有其他亲属、朋友或他们不愿担任监护人的，由未成年人父、母所在单位或者未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或民政部门担任监护人。上述组织担任监护人不分顺序，遵循监护方便和对被监护人有利的原则确定。

（5）协议确定未成年人的监护人。未成年人父母双亡或丧失行为能力的，其他法定监护人及愿意担任监护人的其他亲属、朋友有两人以上又均具有监护能力的可以通过协议确定由其中一人担任监护人或由数人担任监护人。

（6）指定未成年人的监护人。指定未成年人的监护人是指**未成年人父母之外的近亲属**担任监护人。为未成年人指定监护人有两种，一种是有关组织指定，另一种是人民法院指定。有权指定未成年人的监护人的有关组织是未成年人父、母所在单位，或者未成年人住所地的居民委员会、村民委员会。当事人不服上述组织指定的，可向人民法院提起诉讼。**如果未经有关组织指定，直接向人民法院起诉的，人民法院不予受理。**

（7）未成年监护人的变更。未成年人的监护人的变更主要包括以下原因：监护人死亡、丧失了监护能力，这就需要变更监护人；监护人不履行监护职责，给未成年人造成损害的或者利用监护方便侵害未成年人财产利益的，经未成年人的近亲属申请，人民法院可以变更监护人；在法律允许的情况下，监护人之间也可以签订变更协议，更换监护人。变更未成年人监护人的目的在于保护未成年人的合法权益。

七、案例分析题

1、此买卖合同完全有效。根据我国《民法通则》第11条：“十六周岁以上不满十八周岁的公民，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人”，张某已满17周岁，且以自己的劳动收入为主要生活来源，应视为完全民事行为能力人，可以独立实施民事法律行为，无须征得其父母同意。被视为

完全民事行为能力人立遗嘱的行为在实务中应认定无效为宜。张某患上精神病丧失民事行为能力是在合同成立之后，这不影响他所订立的买卖合同的效力。张某的父亲的诉讼请求应依法不予支持。

2、（1）父母是未成年人的当然法定监护人，只有父母确实无能力履行监护职责，以及确实明显不利于未成年人的情况下，才可能取消父母对子女的监护权。本案中，钱某改嫁是其应有的权利，不构成不利于未成年人的情况，因此，赵某的父亲无权要求改变**钱某担任赵甲的监护人**。

（2）被宣告死亡的人回来后，因继承法而取得其财产的自然人应返还所取得的财产或者给予适当补偿，因此，赵某有权要求其父亲返还继承的一间房屋。

（3）无权。如果原物已经被第三人合法取得的，可不予返还。孙某取得摩托车是合法取得，因此，赵某无权要求其返还。

（4）不能。被宣告死亡人的配偶已经再婚的，即使再婚后配偶他方又死亡的，其与配偶的婚姻关系不能自动恢复。但可通过再次登记而缔结婚姻关系。

（5）无权。被宣告死亡人的子女被他人合法收养的，被宣告死亡人不能以收养未经其同意而主张收养无效，要解除收养关系应与收养人协商解决。

第五章 法人

一、单项选择题 1、C 2、D 3、B 4、D 5、A 6、C 7、C

1、下列不具有法人资格的是（ ）。

- A、上海铁路局
- B、北京市邮政局
- C、工商银行湖南省分行
- D、广州白云机场

2、国家自然科学基金委员会在性质上属于（ ）。

- A、机关法人
- B、社会团体法人
- C、基金会法人
- D、事业单位法人

3、法定代表人变更以后，原订立的合同（ ）。

- A、一律无效
- B、应继续履行
- C、经追认后有效
- D、部分有效

4、企业法人依法被撤销、解散、宣告破产或其他原因而进行清算时，企业法人（ ）。

- A、主体资格消灭，不能进行民事活动
- B、主体资格不消灭，但不能进行民事活动
- C、主体资格不消灭，仍然可以进行各种民事活动
- D、主体资格不消灭，但不能进行清算范围以外的民事活动

5、法人设立登记具有（ ）。

- A、生效效力
- B、对抗效力
- C、生效效力或对抗效力
- D、生效效力和对抗效力

6、甲公司因业务发展分立成丙公司和丁公司，双方并且约定，原欠某银行的 100 万元贷款由丙公司负责偿还。后由于丙公司无力偿还该笔贷款而发生纠纷。依法，该笔贷款应如何偿还？（ ）

- A、由丙公司偿还
- B、由丁公司偿还
- C、由丙公司和丁公司连带偿还
- D、由丙公司或丁公司偿还

7、甲企业系国有企业，经营不善，其上级主管部门市工业局决定撤销该企业，并成立了清算小组，清算时发现乙公司尚欠甲企业货款 20 万元，如果起诉要求乙公司偿还货款，应以谁为原告？

- A、甲企业
- B、市工业局
- C、清算小组
- D、市国有资产管理局

二、多项选择题 1、BD 2、BC 3、AC 4、ABCD 5、ABCD

1、下列为财团法人的是（ ）。

- A、某公司
- B、某基金会
- C、某合作社
- D、某寺院

2、下列机构为法人机关的是（ ）。

- A、某公司的销售科
- B、全民所有制企业的厂长
- C、某公司的董事会
- D、某企业的工会

3、在我国依法设立的有限责任公司为（ ）。

- A、企业法人
- B、社会团体法人
- C、社团法人
- D、财团法人

4、在我国，法人设立的方式有（ ）。

- A、命令设立
- B、发起设立
- C、募集设立
- D、捐助设立

5、企业法人有下列情形的，应及时向登记机关登记并进行公告。（ ）

- A、分立
- B、合并
- C、增加注册资本
- D、减少注册资本

三、名词解释

1、法人 2、企业法人 3、机关法人 4、事业单位法人 5、社会团体法人

6、社团法人 7、财团法人 8、营利法人 9、公益法人 10、法人机关

11、法定代表人 12、法人合并 13、法人分立

四、简答题

- 1、法人的本质特征有哪些？
- 2、比较法人的民事权利能力与自然人的民事权利能力。
- 3、区分社团法人与财团法人的意义有哪些？
- 4、法定代表人的特点有哪些？
- 5、法人设立与法人的成立有何区别？
- 6、法人终止的原因有哪些？

五、论述题

- 1、论述法人应具备的条件。

六、案例分析题

1、1994 年，童某、陈某和姜某三人共同在某市设立了一家儿童制衣有限公司，公司注册资本为 60 万元。章程中载明三人的出资分别是 20 万元，15 万元和 25 万元，但实际上，三方的出资都没有交足，总共只有价值 20 万元的生产设备和 5 万元的流动资金，公司的注册是陈某通过欺骗手段获得出资证明办理的。公司成立后，一直运营正常，也与其他的企业签订了大量的合同，其中多数合同已经履行完毕。但是由于经营不善，公司一直都没有真正赢利。1995 年，该企业因对市场估计失策，导致严重亏损。该市布料厂前来追讨公司所欠的 50 万元的债务，后起诉到法院。

请问：（1）该“公司”是否具有法人资格？（2）本企业所欠债务应由谁承担？

2、某建筑安装公司从邻省的安电设备制造厂购进了 2000 只电源开关，但回来经检测，发现有三分之一的质量不合格。经双方协商，安电制造厂同意全部退货。但是某建筑安装公司却一直没有收到 2000 只电源开关的退货款，几经催讨都没有结果，于是某建筑安装公司以安电设备制造厂为被告向法院起诉。但此时安电制造厂已经被某电力设备有限公司所兼并，成为其分公司。原制造厂领导以制造厂已经不存在为由，不归还欠款；而某电力设备有限公司认为，此债务属原制造厂，与公司业务没有任何关系，也拒绝承担责任。

请问：某安装公司应该以谁为被告？此债务应该由谁来承担？

参考答案

一、单项选择题

1、C 2、D 3、B 4、D 5、A 6、C 7、C

二、多项选择题

1、BD 2、BC 3、AC 4、ABCD 5、ABCD

三、名词解释

- 1、法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
- 2、企业法人是指以营利为目的，独立从事商品生产和经营活动的法人。
- 3、机关法人是指依法享有国家赋予的行政权力，并因行使职权的需要而享有相应的民事权利能力和民事行为能力的国家机关。
- 4、事业单位法人是指为了社会公益事业目的，从事文化、教育、卫生、体育、新闻等公益事业的单位。
- 5、社会团体是指自然人或法人自愿组成，为实现会员共同意愿，按照其章程开展活动的非营利性社会组织。
- 6、社团法人是以社员权为基础的人的集合体，也称为人的组合。公司、合作社、各种协会与学会等都是典型的社团法人。
- 7、财团法人是指为一定目的而设立的，并由专门委任的人按照规定的目的进行使用的各种财产，也称财产组合。
- 8、营利法人是指以取得营利并分配给其成员为活动目的的法人，如公司等。
- 9、公益法人是指以公益为其活动目的的法人，如学校、医院、慈善组织等。
- 10、法人机关是指根据法律、章程或条例的规定，于法人成立时产生，不需要特别委托授权就能够以法人的名义对内负责法人的生产经营或业务管理，对外代表法人进行民事活动的集体或个人。法人机关是根据法律、章程或条例的规定而设立；法人机关是法人的有机组成部分，并不是独立主体，它不能独立于法人之外而单独存在，而是依附于法人，并且作为法人组织机构的一个重要组成部分而存在；法人的机关是形成、表示和实现法人意志的机构，对内负责法人的生产经营或业务管理，对外代表法人进行民事活动；法人机关由单个的个人或集体组成。
- 11、法定代表人是指依照法律或法人章程的规定，代表法人行使职权的负责人。法定代表人的资格是法定的，是代表法人行使职权的负责人，法定代表人是代表法人从事业务活动的自然人。
- 12、法人的合并是指两个或两个以上的法人合并为一个法人。法人合并分为吸收合并和新设合并。吸收合并是指一个法人归并到一个现存的法人中去，参加合并的两个法人，只消灭一个法人，另一个法人继续存在并吸收了已消灭的法人；新设合并是指两个以上的法人合并为一个新法人，原来的法人消灭，新的法人产生。
- 13、法人的分立是指一个法人分成两个以上的法人。法人分立有新设分立和派生分立两种。新设分立，即解散原法人，而分立为两个以上的新法人；派生分立，即原法人存续，但从中分出新的法人。

四、简答题

1、法人的本质特征包括：（1）法人是社会组织。作为民事主体的法人或为多个自然人组成的社会集合体，或由一定数量的财产集合为基础组成的社会组织；（2）法人是具有民事权利能力和民事行为能力的社会组织；（3）法人是依法独立享有权利和承担民事义务的组织，法人是独立的组织，拥有独立的财产，承担独立的责任。

2、法人、自然人是两种不同的民事主体，其民事主体资格的享有均是法律赋予的。二者的主要区别如下：

（1）享有的时间不同。自然人民事权利能力的享有始于出生终于死亡，而自然人的生死是自然现象，法人则不一样，法人的成立与终止不是自然现象，是行为的结果。因此，自然人民事权利能力享有的时间不由自然人自己所左右，而法人的成立、终止则是一系列行为的结果。（2）享有的范围不同。自然人是生命体。因此依法享有的民事权利能力范围较广，既包括一般财产权，也包括与自然人生命密不可分的人身权，如生命健康权、肖像权。而法人是组织体，不享有与生命密切相关的生命健康权、肖像权等人身权内容。（3）法人的民事权利能力具有差异性。自然人的民事权利能力一律平等，不因自然人的性别、年龄、智力、健康状况等不同而有所区别。法人的民事权利能力具有差异性，不同的法人，其民事权利能力的范围是不一样的，各类依法登记的法人应在核准登记的范围内从事活动，享有相应的民事权利能力。而非登记法人即依法不需办理法人登记的法人，则应严格按照法人成立的目的、活动范围等享有相应的民事权利能力。

3、社团法人是以社员权为基础的人的集合体，也称为人的组合。财团法人是指为一定目的而设立的，并由专门委任的人按照规定的目的进行使用的各种财产，也称财产组合。二者区分的意义是：（1）成立基础不同。社团法人以人为基础，有自己的组织成员或社员；财团法人以财产为基础，因而没有法人成员。

（2）设立人的地位不同。社团法人的设立人，在法人成立时成为其成员，并享有成员权；而财团法人的设立人，由于法人成立时与法人相脱离，故不为法人成员。（3）设立行为不同。社团法人的设立行为属于共同的民事法律行为，且为生前行为；而财团法人的设立行为则为单方行为，有的为死后生效的行为。

（4）有无意思机关不同。社团法人有自己的意思机关，故又称自律法人；财团法人则没有该机关，故又称他律法人。（5）目的不同。社团法人设立的目的可以是为了营利，也可以为了公益，故社团法人可分营利法人、公益法人和中间法人；**财团法人的设立目的只能是为了公益，所以财团法人只能是公益法人。**

4、（1）必须为具有完全民事行为能力；（2）必须具有一定管理能力和业务知识；（3）须不存在不得担任法定代表人的情形。（4）已担任一个法人的法定代表人者，原则上不得再担任其他法人的法定代表人。社会团体的**法定代表人**，不得同时**担任其他**社会团体的**法定代表人**”

5、（1）两者的性质不同。法人的设立是一种准备行为，这种准备行为既有法律性质上的，也有非法律性质的；而法人的成立则不同，它属于法人产生的形成阶段，其行为性质均属于法律意义上的法律行为。

（2）两者的要件不同。法人的设立一般要有合法的设立人，存在设立基础和设立行为本身合法等要件；而法人的成立一般应具备依法成立，有必要的财产或经费以及有自己的名称、组织机构和场所等要件。因此，法人的设立并不当然导致法人的成立，当设立无效时，法人就不能成立。（3）两者的效力不同。法人在设立阶段，仍不具有民事主体资格，其行为是法人设立人的行为，所发生的债权债务，由法人设立人享有和承担；而法人成立后，即享有民事主体资格，所发生的债权和债务，由法人享有和承担。

6、（1）依法被撤销。它是指法人依照法律的直接规定或因违反法律的规定而被解散的情况。（2）自行解散。它主要指法人的目的事业完成或无法完成、法人机关的决议、法人章程规定的存续期限届满或解散事由的发生而自动解散的情况。（3）依法被宣告破产。企业法人不能清偿到期债务时，人民法院可根据债权人或债务人的申请，依法宣告破产。（4）其他原因。如法人的合并、分立、国家经济政策的调整 and 发生战争等。

五、论述题

1、法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人应具备的条件是指取得法人资格所必须具备的基本条件。根据《民法通则》的规定，法人应具备的基本条件为：（1）依法成立；包括设立宗旨、目的符合国家和社会公共利益的要求，其组织机构、设立方式、经营范围符合国家法律和政策的要求，其成立程序符合法律、法规的要求。（2）有必要的财产和经费。必要财产是指法人财产、经费与法人的规模相适应。特别法、单行法有规定的，依照特别法、单行法的规定。

(3) 有自己的名称、组织机构和场所。(4) 独立承担民事责任。依《民法通则》为法人规定的条件，但学理上一般认为，它非法人的条件，而为特征。

六、案例分析题

1、(1) 本案中的“公司”具有法人资格。公司法人资格的取得，以登记公示为要件。儿童制衣有限公司已经工商局登记注册，具有公示效力。该公司在登记过程中，虽然出资不到位，是通过不正当手段登记注册的，但公司登记注册以后，营运正常，多数合同履行完毕，不属于公司法规定的“情况严重，应予撤销”的情形，因此，**该公司具有法人资格。**

(2) 因为本案中的公司具有法人资格，因此，其所欠布料厂 50 万元的债务，应由公司承担。如果公司的资产不足以清偿该债务，由于该公司三股东出资不到位，三股东应负补足出资额不到位的责任。**在补足出资额的范围内，三股东负有清偿该债务的义务。**

2、某安装公司**应以某电力设备有限公司为被告**。我国《民法通则》第 44 条规定：“企业法人分立、合并，它的权利和义务由变更后的法人享有和承担。”本案中安电制造厂被某电力设备有限公司所兼并，已没有独立的财产，也不再是一个独立的法人，其所欠债务应由某电力设备有限公司承担。某电力设备有限公司自然成为本案被告。

第六章 非法人组织

一、单项选择题 1、C 2、C 3、D 4、C 5、A 6、B 7、D

1、甲乙两人分别出资 4 万元合伙经营一饭店，后因经营管理不善，负债 5 万元。甲乙对该债务应承担()。

- A、无限按份责任 B、有限按份责任
- C、无限连带责任 D、有限连带责任

2、合伙经营期间发生亏损，退伙人已分担合伙债务的，对其参加合伙期间的全部债务()。

- A、不负责任 B、按合伙协议的约定处理
- C、负连带责任 D、适当分担

3、只提供技术性劳务的合伙人，对合伙经营的亏损额，对外()。

- A、按技术性劳务折抵的出资比例承担责任
- B、在分得的利润范围内承担责任
- C、只承担约定的按份责任
- D、承担连带责任

4、甲乙丙三人依法成立一合伙组织，推举甲为负责人，其他合伙人的经营活动()。

- A、对全体合伙人不发生效力 B、只有经甲认可后方发生效力

C、对全体合伙人发生效力 D、须经全体合伙人认可后方发生效力

5、甲乙二人合伙经营，后甲因急事用钱，要将自己的 5 万元份额转让，乙和丙均欲以同一价格购买，甲应如何处理？（ ）

A、卖给乙 B、卖给丙 C、任择其一 D、每人一半

6、甲、乙、丙三人合伙经营，后甲因急需用钱欲将自己五万元的份额转让。乙和丙均主张优先购买权，甲应如何处理？（ ）

A. 由乙、丙抓阄决定谁购买 B. 由甲决定卖给乙或丙

C. 由乙、丙按原来所占的份额行使优先购买权

D. 由乙、丙各购买甲的一半的份额

7、1995 年 5 月甲乙丙经工商部门登记为合伙组织，领取了字号为“幸福饭店”的营业执照，为经营需要，甲向丁借款三万元，借后不久丁即要求返还，应以谁为被告提起诉讼？

A、甲 B、乙 C、丙 D、幸福饭店

45．起字号的个人合伙，在民事诉讼中，应当以依法核准登记的字号为诉讼当事人，并由合伙负责人为诉讼代表人。合伙负责人的诉讼行为，对全体合伙人发生法律效力。

未起字号的个人合伙，合伙人在民事诉讼中为共同诉讼人。合伙人人数众多的，可以推举诉讼代表人参加诉讼，诉讼代表人的诉讼行为，对全体合伙人发生法律效力。推举诉讼代表人，应当办理书面手续。

二、多项选择题 1、ABCD 2、ACD 3、ABC 4、BC 5、AD

1、合伙人退伙时分割的财产应包括（ ）。

A、合伙时投入的财产 B、合伙期间积累的财产

C、合伙期间的债权 D、合伙期间的债务

2、企业法人分支机构的成立条件有（ ）。

A、依法设立 B、无须依法设立，由企业法人决定即可

C、有自己的名称、组织机构和场所 D、有一定的财产或经费

3、某甲提供资金 1 万元，某乙提供房屋五间，某丙提供自己的技术，共同开办一家修理厂，因资金不足，他们又向某丁借贷了 1 万元，这个厂的合伙人是谁？（ ）

A、甲 B、乙 C、丙 D、丁

4、中国农业银行某县支行为某企业的债务提供了担保，因某企业不能偿还债务而发生纠纷，对此，下列判断正确的是（ ）。

- A、该担保合同无效，因为支行不具有缔约能力
- B、该担保合同有效，因为支行具有缔约能力
- C、债权人应以该支行为被告，因为该支行具有诉讼能力
- D、债权人应以该中国农业银行为被告，因为该支行不具有诉讼能力

5、王某以个人名义兴办了一个木制品加工厂，在申请设立企业登记时明确以其家庭共有财产作为个人出资，对此，下列观点，正确的是（ ）。

- A、该加工厂为个人独资企业
- B、该加工厂实为合伙企业
- C、王某应以个人财产对企业债务承担无限责任
- D、王某应以家庭共有财产对企业债务承担无限责任

三、名词解释

- 1、非法人组织 2、合伙 3、入伙 4、退伙
- 5、个体工商户 6、农村承包经营户 7、个人独资企业

四、简答题

- 1、合伙的特征有哪些？
- 2、合伙终止的原因有哪些？
- 3、企业法人分支机构应具备哪些成立条件？

五、论述题

- 1、试述合伙的财产关系。
- 2、试述合伙的债务承担。

六、案例分析题

1、甲有生产一次性卫生巾的技术，乙、丙想使用此技术办工厂。三方协议为甲 4 成，乙、丙各 3 成，但甲不参与经营管理，甲同意乙、丙使用。到 1996 年 3 月止，甲分得 5 万元。后因乙、丙经营管理不善，导致亏损，负债 5 万元。乙、丙找甲要求其承担部分亏损，甲不同意，认为他只是转让技术，而未参与合伙，不应负担亏损。后债权人丁将甲、乙、丙共同告上法院。请回答下列问题：

- (1) 甲是合伙人吗？为什么？
- (2) 5 万元的债务应如何偿还？为什么？

2、甲、乙、丙均为经营长途客运业的专业户，三人商定合伙经营跑运输，每人出资 10 万元入伙，同时甲提出其业务经理丁善于管理，可以由丁以其管理才能入伙，不须交纳出资，乙、丙表示同意。四人一致同意由丁作为日常业务负责人。后甲因其他事项提出退伙，并放弃在合伙中的份额，乙丙丁三人表示同意。三天后，丁在运输过程中撞伤他人，需支付赔偿费 50 万元，为此引起纠纷。请回答下列问题：

(1) 丁以其管理才能入伙是否有效？

(2) 甲放弃的份额应如何处理？

(3) 赔偿费 50 万元应如何承担？

参考答案

一、单项选择题

1、C 2、C 3、D 4、C 5、A 6、B 7、D

二、多项选择题

1、ABCD 2、ACD 3、ABC 4、BC 5、AD

三、名词解释

1、**非法人组织**是指不具有法人资格但可以自己的名义进行民事活动的组织，亦称非法人团体。非法人组织是人合组织体，是具有相应的民事权利能力和民事行为能力的组织体，但是不能完全独立承担民事责任。

2、**合伙**是两个以上民事主体出于共同的经济目的，自愿签订协议，共同出资和经营，共负盈亏和风险，对外负无限连带责任的联合体。合伙是按照合伙协议组成的联合体，合伙的成立除有合伙合同外，还要办理工商登记，领取营业执照，合伙独立从事经营活动，由合伙人共同出资、共同经营，合伙人共享收益、共担风险，并对合伙债务承担连带无限责任。

3、**入伙**，指的是合伙成立之后、解散之前，第三人加入合伙取得合伙人身份的民事法律行为。

4、**退伙**，是合伙人与其他合伙人脱离合伙关系，丧失合伙人身份。退伙分为声明退伙与法定退伙。声明退伙又称任意退伙，是指出于合伙人自己愿意的退伙，原则上当事人自己的意思表示即可生效。法定退伙是指在发生法律规定的情形如合伙人死亡、丧失行为能力或被开除等时出现的退伙。

5、**个体工商户**是指在法律允许的范围内，依法经核准登记，从事工商经营活动的自然人或家庭。从事工商个体经营的是单个自然人或家庭，个体工商户必须依法进行核准登记，并在法律允许的范围内从事工商业经营活动。

6、**农村承包经营户**是指法律允许的范围内，按照承包合同的规定从事商品经营的农村经济组织的成员。农村承包经营户是基于各种承包合同发生的农村集体经济组织的成员，在法律允许的范围内从事商品生产、经营活动。

7、**个人独资企业**是指一个自然人投资，财产属投资人个人所有，投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体。个人独资企业是一个自然人出资，雇工经营，并具有一定生产经营规模的组织形式。

四、简答题

1、合伙的法律特征包括：（1）合伙是按照合伙协议组成的联合体，合伙人成立合伙的合伙协议称为合伙合同，合伙合同是合伙成立的基础。（2）合伙是独立从事经营活动的联合体，可有自己的名称和字号，以自己的名义享受权利和负担义务，在人格、财产、利益和责任等方面是相对独立于合伙人个人的。（3）合伙是由合伙人共同出资、共同经营的联合体。（4）合伙人共享收益、共担风险，并对合伙债务承担连带无限责任。

2、合伙的终止主要有以下原因：（1）合伙的存续期间届满；（2）合伙人全体一致同意终止合伙协议；（3）合伙事业已经完成或已确定无法完成；（4）合伙违反法律而被撤销。

3、（1）依法成立。企业法人的分支机构必须是法律允许设立的经济组织。企业法人设立分支机构应履行法定手续。（2）有自己的名称、组织机构和场所。企业法人的分支机构必须具有不同于其所属法人的依核准登记的名称。在核准登记的范围内，对其名称具有专用权，并以该名称进行业务活动，企业法人分支机构应设有管理内部事务及对外活动的组织机构，有进行业务活动的场所。（3）有一定的财产或经费。这种财产或经费是企业法人分支机构进行经营活动的物质基础。

五、论述题

1、试述合伙的财产关系。

合伙财产指合伙人为经营共同事业所构成的一切财产、权利和利益，它由各合伙人按合伙协议向合伙投入的财产和合伙经营过程中积累起来的财产两部分构成。（1）合伙人投入的财产。合伙人投入的财产，由合伙人统一管理和使用。一般说来，合伙人出资往往直接构成共有财产，而且出资在一般情况下都意味着所有权的转移。（2）合伙经营积累的财产。合伙经营积累的财产，归合伙人共有。即这部分财产，成为合伙的共有财产，合伙共有财产的共有权人是全体合伙人，合伙人应依自己的应有份额享有。共有权在合伙关系存续期间，合伙人对自己的应有份额并无任意处分的权利。按照财产共有关系的一般法则，合伙共有财产由全体合伙人统一管理和使用，非经全体合伙人的一致同意，任何合伙人都不能使用和处分合伙财产。

2、试述合伙的债务承担。

合伙债务，指合伙关系存续期间合伙以全体合伙人名义从事经营活动所产生的债务。合伙债务产生的原因是合伙对第三人的合同行为或侵权行为，履行债务的担保或承担债务的财产范围则是合伙的共有财产和每个合伙人的个人财产。对合伙的债务，合伙人应按照其出资比例或合伙协议的约定，以其个人财产清偿合伙债务，合伙的性质、出资方式 and 合伙财产的规模决定合伙人承担的是无限责任。在对外关系上，全体合伙人对于合伙债务承担无限连带清偿责任，法律另有规定的除外。即每一合伙人都有义务清偿合伙的全部债务，而不受各合伙人对合伙财产的出资比例或合伙协议中约定的债务承担份额的限制。就债权人而言，既可以对某一个、也可以对某几个或全体合伙人先后或同时提出履行全部或部分债务的请求。偿还合伙债务超过自己应当承担数额的合伙人，有权向其他合伙人追偿。

六、案例分析题

1、（1）甲是合伙人。甲虽然未直接参加合伙的经营管理，但甲提供了技术，并且按比例分红，分得5万元，这就是实际的利润。甲应视为合伙人。

(2) 由合伙人共同承担连带偿还责任。合伙人在对外债务承担上，**负无限连带责任，但承担了债务之后，就亏损按合伙协议的约定或者按出资比例分担**。协议未约定债务承担比例或者出资比例的，**按照约定的或者实际的盈余分配比例承担**。对造成合伙经营亏损有过错的合伙人，应当根据其过错程度相应地承担责任。

2、(1) 有效。依《民法通则》和《合伙企业法》规定，合伙人以**劳务**出资，经其他合伙人同意的，合法有效。(实物、资金、技术、劳务等)

(2) 归其他合伙人共有。

(3) 由乙丙丁承担无限连带责任，因为甲已退伙，对退伙后产生的债务不承担责任。

第七章 民事权利客体的种类

一、单项选择题

1、依照我国现行法和司法实践，下列财产中属于不动产的是（ ）。1、C

A、为卖书而临时搭建的书棚 B、田中的稻子

C、林木 D、水库中的鱼

2、下列各物中，属于法定孳息的是（ ）。2、B

A、树上的果实 B、银行存款利息 C、羊生下的小羊 D、买卖的价金

3、下列物中，属于主物与从物关系的是（ ）。3、D

A、甲的汽车与乙的拖斗 B、丙的房屋与其门窗

C、丁的上衣与裤子 D、戊的船舶与船桨

4、利辛学校委托其教务人员王某购买一批电教器材。王某到百货公司购买时，恰逢该公司举行有奖销售，王某因代买电教器材而获得五张奖券，后这五张奖券中的一张中奖，可得到笔记本电脑一台，该电脑应如何处理？（ ）4、A

A、归利辛学校所有 B、归利辛学校所有，但应给王某一定补偿

C、归王某所有 D、归利辛学校和王某共有

5、一幅古画是（ ）。5、B

A、不动产 B、特定物 C、从物 D、可分物

6、设定一定债权的有价证券是（ ）。6、D

A、本票、支票和股票 B、汇票、支票和提单

C、债券、股票和汇票 D、债券、支票和汇票

二、多项选择题

1、下列不属于民法上的物的有（ ）。1、ACD

A、镶在嘴里的金牙 B、池塘中的鱼 C、专利 D、日月星辰

2、下列物中，非专属于国家所有的财产的有（ ）。2、BCD

A、矿藏 B、水库中的水 C、土地 D、黄金

3、依据我国现行法，下列物中，应归国家所有的有（ ）。3、CD

A、甲从垃圾堆里捡回一件旧棉衣

B、乙在田间劳作，捡回一只撞树而亡的野兔

C、丙在耕作土地时，发现一坛所有人不明的银元

D、丁在游泳时捡到一只手表，上缴公共机关公告招领，期满而无人认领

4、下列不属于原物与孳息关系的有（ ）。4、BCD

A、母鸡与其生下的鸡蛋 B、鸡蛋与孵出的小鸡

C、空调与其吹出的风 D、羊与其身上的羊毛

三、名词解释

1、物 2、从物 3、孳息 4、有价证券

四、简答题

1、民法上的物有何法律特征？

2、动产与不动产区分的法律意义有哪些？

3、特定物与种类物区分的法律意义有哪些？

4、可分物与不可分物区分的法律意义有哪些？

5、孳息的法律意义有哪些？

6、货币作为民法上特殊的种类物，其特殊之处有哪些？

五、论述题

1、试述从物应具备的条件及其意义。

六、案例分析题

1、1996年12月，村民甲与县肉联厂达成口头协议：自养的黄牛两头送县肉联厂宰杀，牛肉款按净肉每斤3元5角的价格结算，牛皮、牛头和牛下水归肉联厂，甲再付肉联厂宰杀费80元。在宰杀过程中，肉联厂的屠宰工人乙在其中一头牛的下水中发现牛黄，重100克，卖得价款5000元。甲知道后与乙、县肉联厂为牛黄款归属发生纠纷。现问：

（1）甲与县肉联厂是什么法律关系？

（2）本案中该牛黄款应如何处理？为什么？

参考答案

一、单项选择题

1、C 2、B 3、D 4、A 5、B 6、D 7、

二、多项选择题

1、ACD 2、BCD 3、CD 4、BCD

三、名词解释

1、民法上的物，作为民事法律关系客体之一，是指存在于人身之外，能够满足人们的社会需要而又能为人所实际控制或支配的物质客体。

2、在必须结合使用才能发挥经济效益的两个独立的物中，处于附属地位，起辅助和配合作用的物是从物，从物是相对于主物而言的，主物是在两个结合使用中起主要作用的物。

3、孳息是指因物或权益而生的收益，孳息是相对原物而言的，原物是指依照法律规定或依其自然性质产生新物的物。孳息分为天然孳息和法定孳息。天然孳息是指依照物的自然性质而产生的收益物，又称直接孳息。法定孳息是指依照法律规定产生的收益物，又称间接孳息。

4、有价证券是指设定并证明持券人有权取得一定财产权利的书面凭证。有价证券与证券上所记载的财产权利不能分离，要享有证券上所代表的财产权利，就必须持有证券。有价证券的债务人是特定的，即证券的权利人只能向证券上记载的债务人要求实现债权。而有价证券的债权人则可因证券的转让而发生变更，持券人的合法更换不影响债务人对债务的履行。有价证券的债务人的支付是单方义务，债务人不得要求权利人支付相应对价。但是，债务人有权收回有价证券。

四、简答题

1、物的法律特征包括：（1）物存在于人身之外。民法上所称之物，作为民事法律关系客体之一，具有非人格性。只能是存在于人身之外的一切有体物。（2）物能满足人们的社会需要。民法上的物，必须具有一定的使用价值，能够满足人们一定的社会需要。不具有使用价值的物，不能成为法律意义上的物。社会需要可以分为社会物质生活需要和社会精神生活需要。具有经济价值和用途的物，能够满足人们的物质生活需要，可以成为民法上的物。同样，具有精神价值，如文化价值、情感价值等的物，能够满足人们的精神生活需要，也可以成为民法上的物。（3）物能为人所实际控制或支配。能够为民事主体所实际控制或支配的物质客体才能成为民法上的物。（4）物以有体物为限。德国民法将物限于有体物。所谓有体物，是指占有有一定空间且具有某种形体的物。近年来，学理上对有体物逐渐采扩大解释，认为有体物不必具有一定形状或固定的体积，不论固体、液体或气体，均为有体物。

2、区分动产和不动产的法律意义在于：（1）物权变动的法定要件不同，法律规定不动产权利的变动以向国家行政机关登记为要件，否则不受法律保护；而对于动产物权的变动，则一般以物的实际交付为要件，甚至可以合同成立为要件。（2）物权类型不同。典权、地上权、土地承包权、地役权以不动产为限；而动产质权、留置权以动产为限。（3）诉讼管辖方面的不同。因不动产发生的纠纷，一律由不动产所在地人民法院进行专属管辖，适用不动产所在地法。而动产的诉讼管辖则比较灵活。

3、区分特定物与种类物的法律意义在于：（1）有些法律关系只能以特定物为客体，如所有权法律关系，**租赁**法律关系等；而有些法律关系的客体既可以是特定物也可以是种类物，如**买卖**法律关系等。（2）物意外灭失的法律后果不同。特定物在交付前意外灭失的，由于其具有不可替代的特性，故可以免除义务人的交付义务，而只能请求赔偿损失。种类物如在交付前意外灭失的，由于其具有可替代性，故不能免除义务人的交付义务，可责令义务人以同种类的物为交付。

4、区分可分物和不可分物的法律意义在于：（1）便于共有财产的分割。当数人共有一物时，若物为可分物，则财产分割时可以采取实物分割的方法，各自取回自己的份额；若物为不可分物，则只能采取变价分割或作价补偿其他共有人的方法分割其共有物。（2）便于明确多数人之债的债权债务，多数人之债中，若其标的物为可分物，则数人共享按份债权或共担按份债务；若标的物为不可分物，则数人之债权为连带债权，而其债务为连带债务。此外，当事人可依协议或约定一定期限内不得将可分物分割，则其债权债务于此特定期限内为连带债权或连带债务。

5、孳息的法律意义在于确定孳息的**归属和孳息收取权**。在我国法律实务中，如法律未明确规定或当事人未特别约定，**孳息归原物人享有**。孳息的收取权，天然孳息与法定孳息不同。天然孳息的收取由物权法规定，法定孳息的收取由债权法规定。天然孳息未与原物分离前，不存在孳息收取问题。**一旦与原物相分离，孳息归属物权法确定的权利人**。法定孳息的权利人通常为**债权人**。有收取法定孳息权利的人，按其权利存续期间的日数取得孳息。

6、货币作为民法上特殊的种类物，其特殊之处是：（1）货币所有权的归属。货币占有权与所有权合而为一，货币的**占有人视为货币所有人**。（2）货币所有权的转移。货币所有权的转移以交付为要件，即使在**借款合同中，转移的也是货币所有权，而非货币的使用权**。无行为能力人交付的货币也发生所有权的转移。（3）货币不发生**返还请求权之诉**的问题，仅能基于合同关系、不当得利或侵权行为提出相应的请求。其特殊之处是有货币的流通手段决定的。

五、论述题

1、（1）在必须结合使用才能发挥经济效益的两个独立的物中，处于附属地位，起辅助和配合作用的物是从物，从物是相对于主物而言的，主物是在两个结合使用中起主要作用的物。（2）从物应具有下列构成要件：第一，从物之使用目的应该具有永久性，从物必须常助主物的效用，此项效用不以经济效用和经济目的为限；第二，从物与主物同属于一人；第三，从物须具有独立性，不是主物的部分；第四，须交易上视为从物。在交易上有特殊习惯，不被认为从物的，不得以从物论。（3）从物的法律效力：在法律没有相反规定或当事人没相反约定时，主物所有人处分主物时，效力及于从物，如转移主物所有权，则从物所有权亦随之移转；在当事人没有特别约定的情况下，因标的物主物不合约解除合同的，解除合同的效力及于从物，但不能与之相反；若对主物所有权为一定限制，则限制亦及于从物，如设定抵押，则抵押之效力亦及于从物。

六、案例分析题

1、（1）承揽合同关系（甲付县肉联厂宰杀费 80 元，这是承揽合同的典型特征）和买卖关系（牛肉）以及赠与（牛皮、牛头和牛下水）。

(2) 应归甲所有。我国合同法和当事人均未对该承揽合同中的孳息归属作出约定，依民法原理，孳息在法律没有规定或当事人没有约定的情况下，归原物所有人所有。牛黄是牛的孳息，不是牛下水的孳息。故应归牛的所有人。

第八章 民事法律行为

一、单项选择题

1、下列意思表示中，不属于有相对人的意思表示的是（ ）。

A、悬赏广告 B、债务免除 C、代理权授予 **D、遗嘱行为**

2、附解除条件的民事法律行为，在条件不成就时，该民事法律行为（ ）。

A、开始生效 B、开始无效 C、失去效力 **D、继续有效**

3、就我国无效民事行为的确认权归属的下列说法中，正确的是（ ）。

A、只能由人民法院确认，不能由仲裁机关确认

B、只能由仲裁机关确认，不能由人民法院确认

C、既可由人民法院确认，又可由仲裁机关确认

D、只能由人民法院或者仲裁机关任选其一

4、依据我国现行法，可撤销民事行为的撤销权行使的除斥期间是（ ）。

A、9个月 **B、1年** C、2年 D、4年

5、当事人约定“如果甲的儿子从外地调回”，甲乙之间的房屋租赁合同即行终止。这一民事法律行为所附的条件是（ ）。

A、否定解除条件 B、否定延缓条件

C、肯定解除条件 D、肯定延缓条件

6、甲不知其女友已与他人结婚而到乙商场订购一枚戒指，以作订婚之用。甲的意思表示错误属于何种类型的错误？（ ）。

A、动机错误 B、表示内容错误 C、表示行为错误 D、传达错误

7、甲家的鱼池与乙家鱼池相连，因暴雨甲家鱼池中的鱼进入乙家鱼池中，这一法律事实属于（ ）。

A、事件 B、事实行为 C、民事行为 D、民事法律行为

8、甲向乙借钱，乙说，太阳从西边出来，我就借钱与你。则（ ）。

A、所附条件无效，行为有效 B、所附条件有效，行为无效

C、所附条件有效，行为有效 D、所附条件无效，行为无效

9、无效民事行为的含义是（ ）。

A、不发生当事人预期法律后果的行为

B、不发生任何法律效力的行为

C、通过当事人追认以后才发生法律效力的行为

D、通过享有权利的第三人追认才发生法律效力的行为

10、A 公司委托王某去某市 B 公司购买机械表 1000 只，王某见 B 公司还有电子表可供应，在 B 公司说明电子表是从正规渠道进货后，就在购销合同上添加了购买 2000 只电子表的条款。王某付款后将机械表和电子表运往 A 公司途中，2000 只电子表被海关以走私品没收。A 公司收到机械表后，发现不好销，遂以合同无效要求退货。下列论述正确的是（ ）。

A、该购销合同中购买 2000 只电子表的条款无效

B、该购销合同中购买 2000 只电子表的条款可撤销

C、该购销合同中购买 2000 只电子表的条款效力未定

D、该购销合同无效

11、甲公司董事长张某与乙汽车制造厂订立一份汽车买卖合同，价格 50 万元。乙厂如约运汽车至甲公司所在地时，甲公司其他董事及股东以公司章程规定，因公司规模较小，每名董事对外所签订合同，如标的额超过 20 万元的，应经董事会讨论决定，而张某擅自订立购车合同乃属违反公司章程的行为为由主张合同无效，并拒绝收货拒付货款。乙厂对甲公司章程规定并不知晓。则张某所订合同，其效力如何？（ ）

A、有效

B、无效

C、效力未定

D、可撤销

合同法第五十条 法人或者其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外，该代表行为有效

12、根据我国民法实践的一般作法，书面的意思表示在需要经过传达媒介才能到达对方当事人时，则该意思表示的生效时间为（ ）。

A、表意人完成其表意行为时

B、意思表示表意人时，如函件已邮寄

C、意思表示到达相对人时

D、相对人了解意思表示的内容

13、依照我国法律规定，代理人与第三人之间恶意串通，损害被代理人利益的行为属于（ ）。

A、无效民事行为 B、可撤销的民事行为

C、效力未定的民事行为 D、事实行为

14、甲以绑架乙的儿子为由胁迫乙签订了一份合同。乙事后以受到胁迫为由主张撤销该合同。乙撤销合同的意思何时生效？（ ）

A、乙作出意思表示之时 B、乙撤销通知到达甲时

C、乙的意思经甲同意时 D、乙的意思经法院或仲裁机关同意时

15、可撤销的民事行为被撤销的（ ）。

A、溯及于行为成立时起无效 B、自被撤销之日起无效

C、是否具有溯及力由人民法院或仲裁机构决定 D、是否具有溯及力由当事人约定

二、多项选择题

1、下列属于事实行为的有（ ）。1、ABC

A、无因管理行为 B、正当防卫行为 C、紧急避险行为 D、合同行为

2、王某与张某签订了一份书面合同，约定由王某在签约后3日借给张某2万元，张某于半年后偿还该2万元并支付10%的利息，该行为属于何种民事法律行为？（ ）2、AD

A、有偿民事法律行为 B、无偿民事法律行为

C、诺成民事法律行为 D、实践民事法律行为

3、甲因参加全国律师资格考试，连续三次均差一分而落榜，愤而弃其书于垃圾堆。清洁工人乙于清洁垃圾时发现该套书，喜拾之给其儿子丙学习之用。对此，下列表述中，正确的有（ ）。3、BC

A、甲所为意思表示为有相对人的意思表示

B、甲所为意思表示为无相对人的意思表示

C、甲所为意思表示于完成时发生效力

D、甲所为意思表示于乙拾到时发生效力

4、民事法律行为的形式有（ ）。4、ABCD

A、口头形式 B、书面形式 C、推定形式 D、沉默形式

5、意思表示瑕疵的法定事由包括（ ）。5、ABCD

A、欺诈 B、胁迫 C、乘人之危 D、重大误解

6、民事法律行为的一般成立要件包括（ ）。 6、ABC

A、当事人 B、意思表示 C、标的 D、登记

7、张某新购得一辆“宝来”轿车，遂将其原有的“奥拓”车转让给刘某。双方签订了合同，并约定五日后刘某付款，张某交车并办理过户手续。签约后第三日，张某家车库旁房屋起火，火延及张某家的车库，并将其“奥拓”车烧毁。则张某与刘某之间的合同为（ ）。 7、BD

A、标的主观不能 B、标的客观不能 C、标的自始不能 D、标的嗣后不能

8、甲与乙签订了一房屋买卖合同，但未办理房屋过户登记。下列判断正确的是（ ）。 8、BD

A、房屋买卖合同无效 B、房屋买卖合同有效

C、房屋所有权已转移 D、房屋所有权未转移

9、甲与乙签订一份租房协议，协议规定，如果甲与丙结婚将租用乙的两居室。这一民事行为的性质如何认定？（ ） 9、AC

A、是附条件的民事行为 B、是附期限的民事行为

C、已成立但未生效 D、已成立并已生效

10、下列行为中，不得附条件的有（ ）。 10、ABC

A、法定抵销 B、结婚 C、票据背书 D、借款行为

11、李刚（12岁），其叔叔（30岁）赠与其一台价格5000元的数码相机。因李刚与其同学刘强（12岁）关系甚好，李刚便将该数码相机转卖给刘强。李刚的叔叔和父亲听后都向刘强要求返还该相机，下列有关该事件的论述哪些是正确的？（ ） 11、BC

A、李刚为限制行为能力人，其接受赠与的行为无效

B、李刚为限制行为能力人，其出卖行为效力未定

C、李刚在征得其父亲同意后，可以出卖数码相机

D、李刚在征得其叔叔同意后，可以出卖数码相机

12、李某为给病危的父亲治病急需用款10万元，王某表示愿意借给，但一年后须加倍偿还，否则须以其三居室住房代偿，李某表示同意，此行为属于（ ）。 12、BC

A、无效的民事行为 B、可撤销的民事行为

C、乘人之危的民事行为 D、有效的民事行为

13、乙到甲家玩，看到甲家一幅山水画，甚为喜爱，甲知该画为伪作，故意告知画乃某名画家遗迹。乙遂以 2 万元的价格将其买下。后经鉴定，此画并非名家遗迹，市值仅为 1000 元。对此，下列说法中，正确的有哪些？（ ） 13、AC

A、甲乙之间的行为为受欺诈的民事行为 B、甲乙之间的行为为乘人之危的民事行为

C、甲乙之间的行为为可撤销的民事行为 D、甲乙之间的行为为无效的民事行为

14、甲至西安旅游，在乙旅游商店见一精致之兵马俑，讯问是否当地泥土烧制品，丙店员告知确为当地泥土烧制品，甲遂花费 1000 元价格购买之。后经检验，乃为外地泥土烧制品。对甲的购买行为，下列说法中，不正确的有（ ）。 14、ACD

A、为可撤销的民事行为，因甲受到丙的欺诈

B、为可撤销的民事行为，因甲受到乙的欺诈

C、为效力未定的民事行为，因丙为无权代理

D、为效力未定的民事行为，因丙为无权处分

15、村民甲因外出打工，将自己的一头水牛委托乙照料。乙因儿子结婚急需用钱，遂将该水牛以自己的名义卖给邻村的丙。因丙未带够钱，双方约定，三日后付款取牛。对此，下列表述中，正确的有（ ）。 15、AD

A、乙卖牛的行为为无权处分行为

B、乙卖牛的行为为无权代理行为

C、乙丙所订合同为无效合同

D、乙丙所订合同为效力未定合同

16、甲商场业务员周某到乙电器公司采购冰箱时，见乙电器公司正在优惠销售微波炉，便欲购买，但因未得公司授权无法购买。乙公司负责人吴某为作成生意，就说，先签订合同再说。周某遂以甲商场的名义与乙公司签订了购买微波炉的合同。合同签订后，乙公司催告甲商场于 10 天内追认该合同。甲商场因购得另款微波炉，没有表示。则下列说法中，正确的有（ ）。 16、AC

A、周某的行为为无权代理

B、周某的行为为无权处分

C、甲商场的行为依法视为拒绝追认

D、甲商场的行为依法视为追认

三、不定项选择题

（一）1999 年 5 月，毛一文到某市百货商场买照相机，该商场工作人员工作疏忽，错将一架尼康相机价格 4500 元标成 450 元。毛一文看到这架相机后，觉得非常便宜性能优良，于是就买走了。事隔一周后，商店盘点时发现了错误，就派人找到毛一文，要求补足货款或退款退货，而毛一文却认为你标错了价是你的错，我买东西又不是没付钱，货已经卖出去了，哪有再补钱的道理，拒不补足价款，也不退货。于是该百货商场到人民法院起诉。

1、本案中买卖相机行为性质应如何认定 1、A

A、行为人对行为内容有重大误解

- B、违背社会公共利益的
- C、一方以欺诈的手段使对方在违背真实意思的情况下所为的
- D、以合法形式掩盖非法目的的

2、人民法院对本案如何处理？ 2、AB

- A、如百货商场请求变更，应当予以变更
- B、如百货商场请求撤销，可以酌情予以撤销
- C、认定该买卖行为无效
- D、认定该买卖行为部分无效

3、下列机关中，对该合同纠纷无处理权的是（ ）。 3、ACD

- A、人民检察院
- B、人民法院
- C、消费者协会
- D、公安机关

(二)某甲系工人，工作已近半年，现年 17 周岁，其每月工资和奖金所得，除生活开支外已经积蓄 1000 元人民币。因上下班乘车不方便，某甲便委托其邻居某乙代买自行车一辆。某乙是学生，现年 15 岁，为买一部复读机，决定将其父亲给他买的一辆山地车（价值 1000 元左右）卖给某甲，两人商定卖价为 380 元。某甲付款后，某乙将自行车交付某甲。某乙的父亲知道后，不同意某乙把车卖掉，遂要求某甲返还自行车。

1、某甲与某乙之间的买卖行为 1、B

- A、合法有效
- B、效力未定
- C、可依法撤销
- D、无效

2、就某甲与某乙之间的买卖行为，下列表述正确的有 2、AC

- A、某甲可以请求返还 380 元购车费
- B、某甲可以请求支付 380 元购车费的利息
- C、某乙的父亲可以请求返还山地车

D、某乙的父亲无权请求返还山地车

四、名词解释

- 1、民事行为 2、事实行为 3、民事法律行为 4、意思表示
- 5、欺诈 6、胁迫 7、乘人之危 8、重大误解 9、错误
- 10、附条件民事法律行为 11、条件 12、附期限的民事法律行为 13、期限 14、无效民事行为 15、可变更、可撤销民事行为 16、效力未定民事行为

五、简答题

- 1、民事行为与事实行为的区别有哪些？
- 2、民事法律行为的特征有哪些？
- 3、有偿行为与无偿行为区分的意义如何？
- 4、诺成性行为与实践性行为区分的意义如何？
- 5、要式行为与不要式行为区分的意义如何？
- 6、错误的构成要件有哪些？
- 7、民事法律行为所附条件的要求有哪些？
- 8、附条件民事法律行为的效力有哪些情形？
- 9、民事行为被确认无效的法律后果有哪些？
- 10、效力未定民事行为的特征有哪些？

六、论述题

- 1、试述欺诈的构成要件。
- 2、试述胁迫的构成要件。
- 3、试述乘人之危的构成要件。
- 4、论述民事法律行为的有效要件。

七、案例分析题

1、2000年3月10日清晨，急于到医院分娩的孕妇王丽在丈夫的搀扶下来到马路边，准备乘坐出租车到医院分娩，时值清晨，出租车极少，10余分钟后，一辆出租车终于在王丽一家人身边停下，该车司机于凡对王丽及家人称：该车是新车，孕妇乘坐会弄脏车座，而且三人同时乘坐会增加燃油量，如果想坐，需要支付平时乘车费用6倍的乘车费，否则不能上车，王丽的丈夫考虑到天色较早，搭乘出租车极为困难，

且王丽的情况紧急，于是同意按 6 倍于平时乘车费的款额支付服务费。事后，王丽及其丈夫向法院起诉。要求返还多收的钱款。

请问：（1）司机的行为是否构成乘人之危？

（2）本案应如何处理？

1、（1）本案中司机的行为构成乘人之危。依据《民通意见》第 70 条规定：一方当事人乘对方处于危难之机，为牟取不正当利益，迫使对方作出不真实的意思表示，严重损害对方利益的，可以认定为乘人之危。本案中，被告乘原告分娩之际索要高额服务费，迫使原告于危难之际与其订立服务合同，其行为违背了原告的真实意志，牟取了非法不正当利益，该合同属于因乘人之危而订立的合同。

（2）依《合同法》第 54 条规定，因乘人之危所订立的合同属于可变更、可撤销的合同。对于可变更、可撤销的合同，当事人请求变更的，人民法院或仲裁机构不得撤销。本案中，王丽夫妇请求变更合同，返还多收的钱款，人民法院应予以支持。

2、甲公司因业务开展需要聘请一精通法律实务的常年法律顾问。甲公司的法定代表人知道该市 AAA 律师事务所的张红律师是本市律师界的重量级人物，精通业务，尤擅诉讼事务。甲公司的法定代表人前往 AAA 律师事务所要与张红律师签定一委托合同。不料，接待甲公司法定代表人的是该所另一张红律师。甲公司遂与该张红律师签定了委托合同。该张红律师刚获律师资格，律师业务不是很精通。甲公司查明此事以后，欲解除了该张红律师的委托合同。为此引起纠纷。

请问：甲公司是否可以重大误解为由解除与张红律师的委托合同？为什么？

2、可以。依《民通意见》第 71 条规定，行为人因对行为的性质、对方当事人、标的物品种、质量、规格和数量等的错误认识，使行为的后果与自己的意思相悖，并造成较大损失的，可以认定为重大误解。本案中，甲公司与 AAA 律师事务所张红律师所签定的委托合同是一具有人身性质的合同，当事人的人品、才能、声望和操守对合同的履行和实现具有重大意义，因此甲公司误认当事人构成重大误解。甲公司可以重大误解为由主张撤销与该张红律师的委托合同。

3、甲为一个个体工商户，因经营不善，欠乙 50 万元，现还款期已到。为还款，甲将其好友丙因出国而寄放在甲处的一辆摩托车，以自己的名义出售给丁。戊知晓甲的处境，遂提出要以 30 万元的价格购买甲一件祖传古玩（估价为 50 万元），甲因一时无法找到买主，只好答应了戊的要求。请回答下列问题：

（1）甲与丁之间的买卖摩托车行为效力如何？为什么？

合同法第五十一条 无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。

（2）甲与戊之间的买卖古玩的行为效力如何？为什么？

3、（1）效力未定。甲擅自以自己的名义将丙寄存的摩托车出售，是**无权处分他人财产**的行为，依据我国《合同法》的规定，该行为为效力未定的民事行为。

（2）可变更、可撤销。戊与甲之间的买卖行为是乘人之危的民事行为。乘人之危是行为人利用对方当事人的急迫需要或危难处境，迫使对方作出违背本意而接受于其非常不利的条件的意思表示。本案中，戊利用甲处于还款压力的困难处境，以极其**不利于甲的价格**将其祖传古玩买走，为乘人之危的民事行为。依据

我国《合同法》的规定，乘人之危的民事行为为可撤销、可变更的民事行为，利益受损一方当事人可以请求变更或者撤销该行为。

参考答案

一、单项选择题

1、D 2、D 3、D 4、B 5、C 6、A 7、A 8、D 9、A 10、A

11、A 12、C 13、A 14、B 15、A

二、多项选择题

1、ABC 2、AD 3、BC 4、ABCD 5、ABCD 6、ABC 7、BD

8、BD 9、AC 10、ABC 11、BC 12、BC 13、AC 14、ACD

15、AD 16、AC

三、不定项选择题

(一) 1、A 2、AB 3、ACD

(二) 1、B 2、AC

四、名词解释

1、民事行为是与事实行为相对应的概念，是以意思表示为要素发生民事法律后果的行为。民事行为包括民事法律行为、无效民事行为、可变更或可撤销的民事行为、效力未定的民事行为，但不包括侵权行为、违约行为、无因管理等事实行为。

2、事实行为是指行为人不具有设立、变更或消灭民事法律关系的意图，但依照法律规定能引起民事法律后果的行为。

3、民事法律行为是指公民或法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为。民事法律行为是合法的，它以发生民事法律后果为目的，以意思表示为构成要素。

4、意思表示是指行为人把进行某一民事法律行为的内心效果意思，以一定的方式表达于外部的行为。

5、欺诈是指当事人一方故意编造虚假情况或隐瞒真实情况，使对方陷入错误而为违背自己真实意思表示的行为。

6、胁迫包括威胁和强迫。威胁是指行为人一方以未来的不法损害相恐吓，使对方陷入恐惧，并因此作出有违自己真实意思的表示。强迫是指行为人一方以现时的身体强制，使对方处于无法反抗的境地而作出有违自己真实意思的表示。

7、乘人之危是指行为人利用对方当事人的急迫需要或危难处境，迫使其作出违背本意而接受于其非常不利的条件的意思表示。

- 8、重大误解是指行为人对行为的性质、对方当事人、标的物的品种、质量、规格和数量等的错误认识，使行为的后果与自己的意思相悖，造成较大损失的意思表示。
- 9、错误是指表意人为表意时，因认识不正确或缺认识，以致内心的真实意思与外部的表现行为不一致。
- 10、附条件民事法律行为是指在民事法律行为中规定一定条件，并且把该条件的成就或者不成就作为确定行为人的民事权利和民事义务发生法律效力或者失去法律效力的根据的民事法律行为。
- 11、条件是当事人以将来客观上不确定事实的成就或不成就，决定民事法律行为效力发生或消灭的附款。
- 12、附期限的民事法律行为是指在民事法律行为中约定一定期限，并把该期限的到来作为行为人的民事权利和民事义务发生、变更、消灭的前提的民事法律行为。
- 13、期限是当事人以**将来确定事实**的到来决定民事法律行为的效力的发生或消灭的附款。
- 14、无效民事行为是指欠缺民事法律行为的有效要件，不发生当事人预期法律后果的民事行为。
- 15、可变更、可撤销民事行为是指行为人的意思与表示不一致及意思表示不自由，导致非真实意思表示，法律并不使之绝对无效，而是权衡当事人的利害关系，赋予表意人撤销权的民事行为。
- 16、效力未定民事行为是指其有效或无效处于不确定状态，尚待享有形成权的第三人同意（追认）或拒绝的意思表示来确定其效力的民事行为。

五、简答题

- 1、（1）民事行为以意思表示为其必备要素；而事实行为完全不以意思表示为其必备要素，当事人实施行为的目的并不在于追求民事法律后果。（2）民事行为依行为人的意思表示的内容而发生法律效力；而事实行为依法律规定而直接产生法律后果。（3）民事行为的本质在于意思表示，而不在于事实构成；而事实行为只有在行为人的客观行为符合法定构成要件时，才发生法律规定的后果。（4）民事行为以行为人具有民事行为能力为生效条件；而事实行为的构成不要求行为人具有相应的民事行为能力。
- 2、（1）应是民事主体实施的以发生民事法律后果为目的的行为；（2）应是以意思表示为构成要素的行为；（3）应是合法行为。
- 3、区分无偿行为和有偿行为的意义在于：（1）对行为性质的认定。某些民事法律行为法律规定必须是有偿的或无偿的，如买卖行为必须是有偿的，赠与行为必须是无偿的。如果当事人的意思表示违反了法律规定，则该行为不能成立或依法转换为另一类行为。（2）对行为效力的认定。有偿行为显失公平，受损害人有权请求变更或撤销。无偿行为则不存在**显失公平**的认定问题。（3）对行为人责任的认定。对于行为人责任的轻重，因其行为属于有偿或无偿，法律作出不同的规定，总的来说，无偿行为，行为人承担的**义务较轻**，相应地，其承担的法律責任也较轻。
- 4、**以民事法律行为于意思表示之外是否还必须交付实物作为标准，可以将民事法律行为划分为诺成性行为和**实践性行为****。诺成性行为是指仅以意思表示为成立要件的民事法律行为，又称不要物行为。其特点是，只要行为人的意思表示一致，就能发生民事法律行为，行为人约定的民事权利和民事义务就开始设立。实践性行为是指除意思表示外，还需要以物的**交付作为成立要件**的民事法律行为，又称要物行为。区分诺成性行为和**实践性行为**的意义在于：诺成性行为仅依行为人的意思表示一致而成立，而实践性行为除意思表示外，还需要交付实物才能成立。

5、区分要式行为与不要式行为的法律意义在于：不要式行为由当事人自由选择行为方式，要式行为当事人须采用法定方式。对于法定要式行为，法律未规定需采用规定方式才生效的，不影响行为的效力。

6、（1）错误是由表意人自己的原因造成的；（2）表意人的内心真意与表示不一致；（3）表意人不知其内心真意与表示不一致；（4）错误必须具有严重性，即足以影响表意人决定为意思表示；（5）错误是否存在，以意思表示成立之时为决定标准。

7、（1）将来发生的事实，行为人把已知的已发生的事实作为条件时，如果该条件决定着法律行为效力的产生，则视为该法律行为未附加任何条件，如果该条件决定着民事行为效力的消灭，则视为行为人并不希望从事该民事行为，因而该民事行为应宣告无效。（2）不确定的事实，是可能发生或可能不发生的事实，如果在民事行为成立时，行为人已经确定作为民事行为的条件是根本不可能发生的，已经成立的民事行为无效；如果行为人把不可能发生的事实作为民事行为失效的“条件”，则视为未附任何条件。（3）由行为人约定的事实，是行为人意思表示一致的结果，而不能是法律规定或者合同性质决定的事实。凡是民事法律行为中附有法定条件的，应视为未附条件，民事法律行为当然有效。（4）应是合法的事实，违反法律和社会公共利益的违法条件不能作为民事法律行为所附的条件。

8、（1）条件成就。对于积极条件，以条件事实的发生为条件成就；对于消极条件，以条件事实的发生为条件不成就。条件成就后，民事法律行为当然发生法律效力，不须再有当事人的意思表示或其他行为，又可分为非要式法律行为和要式法律行为两种情况。（2）条件不成就，即构成条件内容的事实确定的不实现。对于积极条件，以该事实的不发生为条件不成就；对于消极条件，以该事实的发生为条件的不成就。附延缓条件的民事法律行为，条件不成就时，该民事法律行为视为不存在。附解除条件的民事法律行为，条件不成就时，视为该民事法律行为不再附有条件，维持该民事法律行为的原有效力。（3）当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。（4）条件成就时的效力。附条件的民事法律行为，其效力因条件而受限制。条件成就后，民事法律行为当然发生法律效力，不须再有当事人的意思表示或其他行为。又可分为两种情形：第一，非要式法律行为。条件一旦成就，直接发生法律效力。第二，要式法律行为。如不动产转让，须经登记才发生法律效力。仅仅条件成就并不直接发生法律效力。（5）条件不成就时的效力。通说认为，附延缓条件的民事法律行为，条件不成就时，该民事法律行为视为不存在。附解除条件的民事法律行为，条件不成就时，视为该民事法律行为不再附有条件，维持该民事法律行为的原有效力。（6）条件成就与否未确定前的效力。通说认为，相对人在条件成就与否未确定前，应有因条件成就而取得权利或利益的希望。如附延缓条件买卖合同的买受人，有因条件成就而取得权利的希望。这种希望或可能性，在学理上，称为**期待权**。期待权虽不确定，但有实现的可能，因此，法律应予保护。

9、（1）返还财产。民事行为被确认无效，当事人因民事行为取得的财产，应当返还给对方。如果一方取得，取得方应返还给对方；如果双方取得，则双方返还。（2）赔偿损失。民事行为被确认无效后，有过错的当事人应当赔偿对方的损失；双方有过错的，则应各自承担相应的责任。反之，虽然有损失，但是对方没有过错，就不能够请求赔偿。（3）收归国家、集体所有或返还第三人。双方恶意串通，实施民事行为损害国家、集体或者第三人利益的，应当追缴双方取得的财产，收归国家、集体所有或者返还第三人。这里所说双方取得的财产，应包括双方当事人已经取得或约定取得的财产。

10、（1）效力未定的民事行为的效果效力是不确定的，它既非有效，亦非无效，而是处于**悬而未决的不确定状态之中**。（2）效力未定的民事行为的效力确定，取决于享有形成权的第三人的行为。该第三人称**同意权人或追认权人**，对效力未定的民事行为享有同意或拒绝的权利。同意权人对效力未定的民事行为所为的同意或拒绝的意思表示，相对于效力未定的民事行为来说，为辅助民事行为。（3）效力未定的民事行为经同意权人同意后，其效力确定地溯及于行为成立时。效力未定的民事行为，经同意权人拒绝，即确定地自始无效。

六、论述题

1、欺诈是当事人一方故意编造虚假情况或隐瞒真实情况，使对方陷入错误而为违背自己真实意思表示的行为。其构成要件包括：（1）须有欺诈人的欺诈行为。其情形有三：一是捏造虚伪事实；二是隐匿真实事实；三是歪曲真实事实。（2）欺诈人必须有欺诈的故意。即行为人须有使对方受欺诈而陷入错误，并因此为意思表示的目的。欺诈故意的含义有二：一是使相对人陷于错误的认识，如果行为人非明知其表述的事实为虚假或虽明知其表述之事实为虚假，而无使相对人陷于错误的认识，不为欺诈。二是使相对人因其错误而为一定意思表示的意思，故行为人虽明知其所表示的事实为虚假，而无利用相对人的错误，使其为一定意思表示的意思，不为欺诈。在此两种意思之外，行为人有无取得财产利益的意思，及使相对人受财产损失的意思，对欺诈的成立，没有影响。（3）须表意人因相对人的诈欺而陷入错误。不仅指表意人原无错误，受欺诈人的欺诈而陷于错误，而且包括表意人已有错误，受欺诈人的欺诈而陷于更深的错误。如果相对人未受欺诈而陷于错误，则不构成欺诈，如出卖人用种种手段隐瞒货物的瑕疵，仍被买受人发现，而未购买其货的，不为欺诈。（4）须对方因陷入错误而为意思表示，即错误与意思表示之间有因果关系。错误与意思表示之间的因果关系可分为两种情况：一是无此错误，则根本不为意思表示；二是无此错误，则不以此条件为意思表示。

2、胁迫包括**威胁和强迫**。威胁是指行为人一方以**未来的不法损害**相恐吓，使对方**陷入恐惧**，并因此作出有违自己真实意思的表示。强迫是指行为人一方以**现时的身体强制**，使对方处于无法反抗的境地而作出有违自己真实意思的表示。其构成要件是：（1）须胁迫人有胁迫的行为。胁迫行为既可以直接对相对人实施，也可对其亲属或友人实施；胁迫的对象不仅包括人的生命、身体健康及自由，也包括人的名誉、荣誉、隐私及财产。（2）胁迫人须有胁迫的故意。即胁迫人有通过胁迫行为而使表意人产生恐惧，并因此而为意思表示。胁迫故意的含义有二，一是有使表意人陷于恐惧的意思，二是有使表意人因恐惧而为一定意思表示的意思。（3）胁迫的本质在于对表意人的自由意思加以干涉，所以，胁迫行为应具有违法性，其情形有三，一是目的违法，手段亦违法；二是目的合法，手段违法；三是手段合法，目的违法。（4）须相对人受胁迫而陷入恐惧状态。恐惧状态应依被胁迫人的主观状态决定。恐惧状态有二，一是表意人原无恐惧，因行为人的胁迫而发生恐惧；二是表意人原有恐惧，因行为人的胁迫而加深恐惧。（5）须相对人受胁迫而为意思表示，即表意人陷入恐惧或无法反抗的境地，与意思表示之间有因果关系。

3、乘人之危是指行为人利用对方当事人的急迫需要或危难处境，迫使其作出违背本意而接受于其非常不利的条件的意思表示。其构成条件是：（1）须有表意人在客观上正处于急迫需要或紧急危难的境地。表意人所处的这种境地是客观的，而不是想象的或臆测的。（2）须有行为人乘人之危的故意，即相对人明知表意人正处于急迫需要或紧急危难的境地，却故意加以利用，使表意人因此而被迫作出对行为人有利的意思表示，若行为人没有利用表意人的危难迫使表意人作出意思表示，则不构成乘人之危的意思表示。（3）须有相对人实施了足以使表意人为意思表示的行为。（4）须相对人的行为与表意人的意思表示之间有因果关系。（5）表意人因其意思表示而蒙受重大不利。

4、民事法律行为的有效要件，是指已经成立的民事行为能够按照意思表示的内容而发生法律效果所应当具备的法定条件。民事法律行为的有效要件包括实质要件和形式要件。实质要件包括：（1）行为人具有相应的民事行为能力。就自然人而言，完全民事行为能力人可以以自己的行为取得民事权利，履行民事义务；限制民事行为能力人只能从事与其年龄和智力发育程度相当的民事法律行为，其他行为由其法定代理人代理，或者征得法定代理人的同意；无民事行为能力人不能独立实施民事法律行为，他们的民事法律行为必须由其法定代理人代理。法人的民事行为能力是由法人的核准登记的经营范围决定的，法人只能在核准登记的经营范围内的活动，如果从事核准经营范围以外的经营活动，它就没有与此相适应的民事行为能力。但是，从维护相对人的利益和维护市场关系的稳定性出发，当事人超越经营范围订立合同，人民法院不因此认定合同无效，但违反国家限制、特许经营以及法律、行政法规规定禁止经营的除外。法人或其他经济组织的法定代表人、负责人超越权限订立合同的，除相对人知道或应当知道其超越权限的以外，该代表行为有效。（2）行为人的意思表示要真实。意思表示真实包括两个方面：其一，行为人的意思表示须是**自**

愿的，任何个人和组织都不得强迫行为人实施或不实施某一民事行为。其二，行为人的意思表示须是真实的，即行为人的主观意愿和外在的意思表示是一致的。行为人主观意思与外在表示不一致或意思表示不自由的民事行为，可以撤销。（3）标的须合法。即标的不能违法，不违法的行为就是合法的。法律规范依其适用可分为强制性规范和任意性规范。行为不违法，是指不违反法律的强制规范。（4）标的须可能和确定。标的可能，是指民事行为的标的可能实现，民事行为的标的不能实现的称为标的不能，标的不能的，民事行为不生效力。标的确定，是指民事行为的标的自始确定，或能够确定。在绝大多数情况下，民事法律行为只要具备实质要件就发生法律效力，但在某些特殊情况下，民事法律行为还须具备形式要件才发生效力。

七、案例分析题

1、（1）本案中司机的行为构成乘人之危。依据《民通意见》第70条规定：一方当事人乘对方处于危难之机，为牟取不正当利益，迫使对方作出不真实的意思表示，严重损害对方利益的，可以认定为乘人之危。本案中，被告乘原告分娩之际索要高额服务费，迫使原告于危难之际与其订立服务合同，其行为违背了原告的真实意志，牟取了非法不正当利益，该合同属于因乘人之危而订立的合同。

（2）依《合同法》第54条规定，因乘人之危所订立的合同属于可变更、可撤销的合同。对于可变更、可撤销的合同，当事人请求变更的，人民法院或仲裁机构不得撤销。本案中，王丽夫妇请求变更合同，返还多收的钱款，人民法院应予以支持。

2、可以。依《民通意见》第71条规定，行为人因对行为的性质、对方当事人、标的物品种、质量、规格和数量等的错误认识，使行为的后果与自己的意思相悖，并造成较大损失的，可以认定为重大误解。本案中，甲公司与AAA律师事务所张红律师所签定的委托合同是一具有人身性质的合同，当事人的人品、才能、声望和操守对合同的履行和实现具有重大意义，因此甲公司误认当事人构成重大误解。甲公司可以重大误解为由主张撤销与该张红律师的委托合同。

3、（1）效力未定。甲擅自以自己的名义将丙寄存的摩托车出售，是无权处分他人财产的行为，依据我国《合同法》的规定，该行为为效力未定的民事行为。

（2）可变更、可撤销。戊与甲之间的买卖行为是乘人之危的民事行为。乘人之危是行为人利用对方当事人的急迫需要或危难处境，迫使对方作出违背本意而接受于其非常不利的条件的意思表示。本案中，戊利用甲处于还款压力的困难处境，以极其不利于甲的价格将其祖传古玩买走，为乘人之危的民事行为。依据我国《合同法》的规定，乘人之危的民事行为为可撤销、可变更的民事行为，利益受损一方当事人可以请求变更或者撤销该行为。

第九章 代理

一、单项选择题

1、C 2、B 3、B 4、A 5、D 6、B 7、A 8、D 9、C 10、D

1、甲委托乙代签合同，乙因病并征得甲同意后又委托丙代签合同，则乙丙之间为（ ）。

A、共同代理 B、指定代理 C、再代理 D、法定代理

2、下列各项中，不能当然引起委托代理关系终止的原因是（ ）。

A、被代理人取消委托 B、被代理人死亡

C、代理人辞去委托

D、代理人死亡

3、甲厂业务员王某被开除后，为报复甲厂，用盖有甲厂公章的空白合同书与乙厂订立一份购销合同。乙厂并不知情，并按时将货送至甲厂所在地。甲厂拒收引起纠纷。下列说法中，正确的是（ ）。

A、王某的行为为无权代理，合同无效

B、王某的行为为无权代理，合同有效

C、王某的行为为有权代理，合同无效

D、王某的行为为滥用代理权，合同无效

4、在代理关系中，下列连带责任中，属于补充的连带责任的是（ ）。

A、因代理人授权不明，代理人与被代理人对第三人所负的连带责任

B、因代理人和被代理人的违法行为，代理人与被代理人对第三人所负的连带责任

C、因代理人和第三人恶意串通，代理人与第三人对被代理人所负的连带责任

D、因第三人明知代理人为无权代理人，代理人和第三人对被代理人所负的连带责任

8 1. 委托代理人转托他人代理的，比照民法通则第六十五条规定的条件办理转托手续。因委托代理人转托不明，给第三人造成损失的，第三人可以直接要求被代理人赔偿损失；被代理人承担民事责任后，可以要求委托代理人赔偿损失，转托代理人有过错的，应当负连带责任。

5、司机吴某要出差到山东，李某委托其代买一箱苹果，吴某见当地苹果物美价廉，就以李某的名义多买了一箱。吴某多买一箱苹果的行为属于（ ）。

A、代理权终止以后的行为

B、有权代理行为

C、滥用代理权行为

D、超越代理权行为

6、委托代理人选定的转托代理人是（ ）。

A、委托代理人的代理人

B、被代理人的代理人

C、委托代理人与被代理人的代理人

D、委托代理人的代理人或被代理人的代理人

7、王岚，16岁，高中学生。其外祖父去世时，曾在遗嘱中指明，给王岚25万元购买一处房屋，但未指定由谁来购买。王岚的父亲便以王岚的名义用该25万元买了一套商品房，下列论述正确的是（ ）。

A、王岚的父亲所为的代理属于法定代理

B、王岚的父亲所为的代理属于委托代理

C、王岚的父亲所为的代理属于指定代理

D、王岚的父亲所为的代理属于无权代理

8、甲委托乙为其购买电脑，乙已为购买电脑付出了一定的时间和精力，现甲发现自己急需的电脑通过其它的途径很容易取得，便电话告知乙取消委托，乙不同意。下列论述中正确的是（ ）。

A、该委托代理的终止需经甲、乙双方同意。

B、 甲如取消委托，应以书面形式为之。

C、 取消委托属于双方法律行为

D、 甲取消委托给乙造成损失，甲应承担民事责任

9、甲素慕丙的一幅字画，欲委托乙为其代理人，与丙协商购买事宜。其授权的意思表示（ ）。

A、 只能向乙表示

B、 只能向丙表示

C、 既可以向乙表示，也可以向丙表示

D、 需同时向乙丙二人表示

10、甲委托同村的乙代为带回一匹马。但乙在牧区未遇上好马，担心甲家中活重，就未买马。自己带回良骡一口。甲将骡领回，并付给乙相应款项。下列说法中，正确的是（ ）。

A、 甲的领骡行为是基于对表见代理的接受

B、 甲的领骡行为是基于对乙无权代理的追认

C、 甲的领骡行为是基于对乙委托代理的承受

D、 甲的领骡行为是基于与乙的买卖关系的受领

二、多项选择题

1、下列行为中，可适用代理的有（ 1、ABD ）。

A、 代理合同订立

B、 代理税款缴纳

C、 代理订立遗嘱

D、 代理专利申请

2、滥用代理权的情况包括（2、BCD ）。

A、 指定代理

B、 自己代理

C、 双方代理

D、 代理人与第三人恶意串通的代理

3、甲委托乙为自己的代理人，授权乙代为购买一台冰箱，乙亲自购买了一台冰箱。他们之间的代理关系属于何种代理？（3、ABC ）

A、 委托代理

B、 一般代理

C、 单独代理

D、 特别代理

4、下列行为中，不属于代理的是（4、ABCD ）。

A、 甲有朋自远方来，甲不在，乙代甲招待甲之客人的行为

B、 甲为公司的董事长，甲以该公司的名义与乙公司签订合同的行为

C、 甲为贸易货栈，将乙委托给自己出卖的自行车以自己的名义出卖给丙的行为

D、 甲将邮局转来的给乙董事长的信件送给乙董事长的行为

5、甲公司委托业务员乙到某地采购电视机，乙到该地发现丙公司的 VCD 机畅销，就用盖有甲公司公章的空白介绍信和空白合同与丙公司签订了购买 500 台 VCD 机的合同。双方约定货到付款。货到后，甲公司拒绝付款，下列论述正确的是哪些？（5、ABCD ）

- A、 乙购买 VCD 机的行为没有代理权
- B、 乙购买 VCD 机的行为构成表见代理，产生有权代理的法律后果
- C、 甲公司应接受货物并向丙公司付款
- D、 若甲公司受到损失，有权向乙追偿

6、乙为矿工，甲灯具厂委其为代理人，在矿区出售矿灯。乙设立甲灯具厂矿灯销售处。因煤矿塌方，乙死亡。其子丙将剩余的矿灯继续以甲灯具厂的名义出售。对此，下列说法中，正确的有（ 6、AD ）。

- A、丙为无权代理
- B、丙为转代理
- C、甲应直接承受丙出售矿灯行为的后果
- D、甲可以选择承受丙出售行为的后果，也可以不承受其行为的后果

7、依照我国《民法通则》的规定，委托代理的授权委托书应当载明（7、ABCD ）。

- A、代理人的姓名或者名称 B、代理期限
- C、代理事项 D、代理权限

8、在委托代理中，代理人为了被代理人的利益转托他人代理，发生再代理效力的是（8、AB ）。

- A、事先取得被代理人的同意
- B、事后告知被代理人且取得被代理人的追认
- C、事后告知被代理人，但被代理人未表示同意
- D、事先告知被代理人，但未取得被代理人同意

9、某村居民甲年仅 11 岁，因父母在一次事故中双亡，又无其他法定监护人，在涉讼中需为其指定代理人，下列单位中，有权为其指定代理人的有（9、ABD ）。

- A、人民法院 B、甲父母所在单位 C、民政部门 D、甲所在村委会

10、甲家乡在南方沿海，春节回家，单位同事乙委托其代为购买春茶，丙委托其代为购买土特产，甲概为应允。则甲与乙、丙之间的代理属于（10、AC ）。

- A、单独代理 B、共同代理 C、积极代理 D、消极代理

11、甲已年满 15 岁，就甲担任代理人的下列说法中，正确的有（ 11、BC ）。

- A、可以为法定代理人
- B、可以为委托代理人
- C、不能为法定代理人
- D、不能为委托代理人

12、北方某市甲商场业务员乙到丙公司采购空调，见丙公司生产的浴室防水暖风机小巧实用，在暖气没有来临之前以及在暖气停止之后的一段时间之内对普通家庭大为有用，遂自行决定购买一批该公司生产的暖风机。货运到后，甲商场即对外销售该暖风机。后因该市提前供应暖气，暖风机销量大减。甲商场遂主张乙为无权代理，其所订合同为效力未定的合同，现甲拒绝追认并拒付货款。对此，下列表述中，不正确的有（12、ACD ）。

- A、甲商场应支付货款，因为乙为表见代理
- B、甲商场应支付货款，因为乙的行为已经其追认
- C、甲商场可以拒付货款，因为乙的行为为无权代理
- D、甲商场可以拒付货款，因为乙的行为为滥用代理权的行为

三、不定项选择题

（一）崔某在北京工作，但家在吉林，1991 年春节时要回家探望家人。邻居胡某听说后请他带 1 斤长白山的人参回来，说要泡酒做药用。春节过后，崔某从吉林带回 1 斤人参，价值 1850 元，崔某送至胡家，胡某的儿子说因父亲年事已高，春节期间不幸过世。以前也只有他父亲用人参泡酒做药用，现在他父亲不在了，也就不需要这斤人参，况且他父亲是在他生前委托他代买 1 斤人参，现在他父亲去世了，代理权也就终止了，所以请崔某将这斤人参自己留着再做处理。崔某不得已就去律师事所去请教律师问问他可不可以让胡某的儿子收下这 1 斤人参并支付 1850 元的价款。

1、崔某实施的代理行为的效力如何？（ ）

- A、有效
- B、无效
- C、效力待定
- D、可撤销

2、崔某与胡某之间的委托代理关系是否终止？（ ）

- A、终止，因为代理事务已经完成
- B、终止，因为被代理人已死亡
- C、不终止，因为代理人不知道被代理人已死亡
- D、不能确定

3、委托代理、法定代理、指定代理终止的共同原因有哪些？（ ）

- A、代理人死亡
- B、被代理人死亡

C、代理人丧失民事行为能力

D、被代理人取得民事行为能力

8 2. 被代理人死亡后有下列情况之一的，委托代理人实施的代理行为有效：（1）代理人不知道被代理人死亡的；（2）被代理人的继承人均予承认的；（3）被代理人与代理人约定到代理事项完成时代理权终止的；（4）在被代理人死亡前已经进行、而在被代理人死亡后为了被代理人的继承人的利益继续完成的。

四、名词解释

1、代理 2、共同代理 3、再代理 4、无权代理 5、表见代理

五、简答题

1、代理的特征有哪些？

2、简述代理权的滥用。

3、委托代理权消灭的原因有哪些？

4、法定代理权、指定代理权消灭的原因有哪些？

5、无权代理具有哪些法律特征？

6、狭义无权代理的构成要件有哪些？

六、论述题

1、试述代理权行使的原则。

2、试述表见代理的构成要件及其效力。

七、案例分析题

1、1997 年 10 月，某书画装裱店与某美术学院著名书法家赵某签订了一份委托书法作品创作 合同。双方约定，赵某在 1998 年 2 月以前交付装裱店 20 副对联作品，装裱店支付赵某 5000 元报酬。1997 年 12 月，赵某因不慎跌倒致使右臂受伤，不能创作，于是他委托自己的儿子代为书写了全部对联，以此交付装裱店，装裱店支付了全部报酬。但是不久装裱店感到作品风格 与赵某不同，遂请专家作鉴定，结果发现属他人作品。

请问：（1）赵某转托他的儿子代其创作书法作品是否有效？

（2）赵某儿子的行为是否属于无权代理？

1、（1）《民法通则》第 63 条规定：“依照法律规定或者按照双方当事人约定，应当由本人实施的民事法律行为，不得代理”。本案中合同约定由赵某创作全部 20 副对联的行为是不得代理的行为，因为该行为具有极强的人身性，应当由行为人本人亲自完成。赵某无权委托他人代为履行。

(2) 赵某儿子的行为的不属于无权代理。无权代理是指没有代理权而以他人的名义进行代理活动的民事行为，它包括没有代理权、超越代理权或代理权终止后的代理行为。无权代理经被代理人追认可以产生代理效果。但是不得代理的法律行为是不能由他人代理的行为，即使有合法的委托也不行，这些行为主要是具有人身属性的行为、违法行为或法律规定及合同约定的**不得代理**的行为。

2、甲为一机械厂的采购员，经常在全国各地出差。乙是其邻居，平时以采掘山药为生。1998 年 10 月乙在山中挖到一名贵草药，正好甲要到上海出差，于是乙就委托甲将草药带去卖掉，听说上海这种草药的价钱较高。甲将草药带到邻村的一朋友家中；朋友的父亲丙是一名老中医，他看了之后请甲将草药卖与他，并表示愿给甲 500 元的好处费。结果甲以低于上海市场将近 1000 元的价格把草药卖给了丙，双方还约定，如果事后乙来此处打听这种草药的市场价格，丙就说此草药现在已经大跌价，连上海都不值钱了。不想此事被到丙家来看病的乙的一个远房亲戚听见，不久就告诉了乙。乙遂要求甲和丙赔偿自己损失。

请问：(1) 甲将药卖给丙的行为是一种什么性质的行为？

(2) 乙是否有权要求甲和丙两人赔偿？为什么？

2、(1) 甲的行为是一种与第三人串通，损害被代理人利益的行为。乙委托甲将草药带到上海去卖，而甲却将草药卖与丙，这本身就违背了被代理人的意思；甲在出让草药的过程中，私下收受了丙给予的好处费，将草药以低价卖给丙，并相约共同欺骗乙，这就是相互串通，共同损害被代理人乙的利益。

(2) 我国《民法通则》第 66 条第 3 款规定：“代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人 and 第三人负连带责任。”因此，本案中甲与第三人丙应对乙的损失承担连带赔偿责任。

3、赵某、钱某都是某公司职员，两人同住一宿舍。1999 年春，公司派赵某到珠海办事处工作一年。临行前，赵某将已使用了一年的一台 586 电脑委托给钱某保管并允许其使用。一个月后，赵某给钱某写信说自己买了一台笔记本电脑，委托其保管的电脑可以适当价格出售，但 Modem 因还有用，不要出售。同单位的司机孙某知道此事后，对钱某表示想以低价购买，并指使钱某给赵某写信说该电脑显示器有毛病，屏幕晃动，以便使赵某降价出售。钱某考虑到孙某经常给自己免费送东西，便按孙某的意思给赵某写信。赵某回信说显示器有毛病可以低价出售。于是，孙某以 1500 元的价格买下该电脑。过了几天，钱某因急需用钱，遂将电脑的 Modem 以赵某的名义出售给周某，价格为 500 元（略低于当地的市场价格），周某已经付款，尚未交货。此时，赵某回公司办事后知晓了钱某的行为，十分愤怒。现请回答下列问题：

(1) 赵某能否向孙某请求返还电脑？为什么？

(2) 钱某向周某出售 Modem 的行为性质如何？为什么？

(3) 在 Modem 的买卖关系中，周某享有哪些权利？为什么？

3、(1) 可以。赵某委托钱某代为出售电脑，双方形成代理权法律关系，但钱某滥用代理权，与孙某恶意串通，损害被代理人赵某的利益，依据我国《民法通则》第 58 条规定，代理人和第三人恶意串通，损害被代理人利益的行为是无效民事行为。孙某不能依据无效民事行为而取得电脑的所有权，赵某有权基于其对电脑的所有权请求其返还电脑。

(2) 钱某向周某出售 Modem 的行为是**无权代理行为，为效力未定行为**。赵某没有委托钱某出售 Modem，因此，钱某以赵某的名义出售 Modem 为自始没有代理权的无权代理行为，其行为效力处于不确定的状态：赵某可以追认该行为而使其有效；第三人周某在知道钱某为无权代理之后也可以催告赵某追认或者撤销该行为。

(3) 周某享有催告赵某追认此买卖行为或者撤销该买卖行为的权利。本案中，周某为善意第三人，在狭义无权代理中，善意第三人享有**催告权和撤销权**。

参考答案

一、单项选择题

1、C 2、B 3、B 4、A 5、D 6、B 7、A 8、D 9、C 10、D

二、多项选择题

1、ABD 2、BCD 3、ABC 4、ABCD 5、ABCD 6、AD 7、ABCD

8、AB 9、ABD 10、AC 11、BC 12、ACD

三、不定项选择题

(一) 1、A 2、C 3、AC

四、名词解释

1、代理是指代理人依据代理权，以被代理人的名义与第三人实施民事法律行为，而后果由该被代理人承担。代理是一种法律关系，在代理关系中，一般有三方参加人，涉及三方面的法律关系：即代理人与被代理人之间基于委托授权或法律直接规定而形成的**代理权关系**；代理人依据代理权与第三人之间的**代理行为关系**；被代理人与第三人之间因代理行为而形成的**民事法律关系**。

2、共同代理是指代理权属于两人以上的代理。在共同代理中，代理人之间形成共同关系，享有的代理权是平等的。每个代理人均有权行使全部代理权，每个代理人的代理行为的后果均由被代理人承受。

3、再代理是指代理人为被代理人的利益将其所享有的代理权转托他人而产生的代理，故又称复代理、转代理。再代理是相对于本代理而言的，本代理是指基于被代理人选任代理人或依法律规定而产生的代理，又称原代理。

4、无权代理是代理人不具有代理权，但以本人的名义与第三人进行民事活动的行为。

5、表见代理本属于无权代理，但因本人与无权代理人之间的关系，具有外表授权的特征，致使相对人有理由相信行为人有代理权而与其进行民事法律行为，法律使之发生与有权代理相同的法律效果。

四、简答题

1、代理的特征有哪些？

1、(1) 代理人在代理权限之内实施代理行为，委托代理人应根据被代理人的授权进行代理，法定代理人或指定代理人在法律规定或指定的代理权限内进行代理行为。(2) 代理人以被代理人的名义实施代理行为，代理人如果以自己的名义实施代理行为，则该代理行为发生的法律后果只能由代理人自己承担。(3) 代理行为必须是具有法律意义的行为，只有代理人为被代理人实施的是能够产生民事权利义务的行为才是代理行为。(4) 代理行为须直接对被代理人发生效力，被代理人享有因代理行为产生的民事权利，同时也应承担代理行为产生的民事义务和民事责任。

2、简述代理权的滥用。滥用代理权，是指代理人行使代理权时，违背代理权的设定宗旨和代理行为的基本准则，有损被代理人利益的行为。

构成滥用代理权应具备以下三个要件：（1）代理人有代理权。这一要件使滥用代理权的行为与无权代理行为区别开来。（2）代理人行使代理权的行为违背了诚实信用原则，违背了代理权的设定宗旨和基本行为准则。（3）代理人的代理行为有损被代理人的利益。

滥用代理权包括以下三种类型：（1）自己代理，指代理人以被代理人名义与自己进行民事行为。（2）双方代理，又称同时代理，指一人同时担任双方的代理人为民事行为。（3）代理人和第三人恶意串通，进行损害被代理人利益的行为。

3、委托代理权消灭的原因有哪些？

（1）代理期间届满或者代理事务完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3）代理人死亡；（4）代理人丧失民事行为能力；（5）作为被代理人或者代理人的法人终止。

4、法定代理权、指定代理权消灭的原因有哪些？

（1）被代理人取得或者恢复民事行为能力；（2）被代理人死亡或者代理人死亡或者代理人丧失民事行为能力；（3）指定代理的人民法院或者指定机关取消指定和其他原因等。

5、无权代理具有哪些法律特征？

（1）行为人所实施的民事法律行为，符合代理行为的表面特征，即以本人的名义独立对第三人为意思表示，并将其行为的法律后果直接归属于他人。（2）行为人实施的代理行为不具有代理权。没有代理权包括未经授权、超越代理权和代理权终止三种情况。（3）无权代理行为并非绝对不能产生代理的法律效果。狭义无权代理行为应属效力未定的民事行为，在经本人追认的情况下，无权代理变成有权代理，能产生代理的法律效果；表见代理直接发生代理的法律效果。

6、狭义无权代理的构成要件有哪些？6、（1）行为人既没有法定的或意定的代理权，也没有令人相信其有代理权的事实或理由；（2）行为人以本人的名义与第三人为民事行为；（3）第三人须为善意；（4）行为人与第三人所为的行为不是违法行为；（5）行为人与第三人具有相应的民事行为能力。

五、论述题

1、（1）代理人应在代理权限范围内行使代理权，不得无权代理。代理人只有在代理权限范围内进行的民事活动，才能被看作是被代理人的行为，由被代理人承担代理行为的法律后果。代理人非经被代理人的同意，不得擅自扩大、变更代理权限。代理人超越或变更代理权限所为的行为，非经被代理人追认，对被代理人不发生法律效力，由此给被代理人造成经济损失的，代理人还应承担赔偿责任。

（2）代理人应亲自行使代理权，不得任意转托他人代理。在委托代理中，代理人与被代理人之间，通常具有人身信赖关系。代理人应亲自行使代理权，不得任意转托他人代理；在法定代理中，代理人与被代理人之间多为亲属关系或职务关系，亦应亲自行使代理权，不得任意转托他人代理；在指定代理中，代理人更应亲自行使代理权。只有代理人亲自行使代理权，才有利于代理事务的完成。

（3）代理人应积极行使代理权，尽勤勉和谨慎的义务。代理人只有积极行使代理权，尽勤勉和谨慎的义务，才能实现和保护被代理人的利益。首先，代理人应认真工作，尽相当的注意义务。在法定代理、指定代理和委托代理的无偿代理中，代理人行使代理权，必须尽与处理自己事务相同的注意；在有偿代理中，

代理人应尽善良管理人的注意义务。其次，在委托代理中，代理人应根据被代理人的指示进行代理活动。由于代理的后果由被代理人承受，被代理人可根据客观情况随时给代理人指示，代理人具有遵守被代理人指示的义务。代理人不遵守被代理人指示，构成代理人过错。由此给被代理人造成损失的，代理人应承担赔偿责任。再次，代理人应尽报告与**保密**的义务。若代理人未尽到职责，给被代理人造成损害的，依《民法通则》第 66 条的规定，代理人应承担民事责任。

2、（1）表见代理本属于无权代理，但因本人与无权代理人之间的关系，具有**外表授权**的特征，致使相对人有理由相信行为人有代理权而与其进行民事法律行为，法律使之发生与**有权代理相同的法律效果**。（2）表见代理的构成要件：第一，行为人无代理权；第二，有使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由；第三，相对人为善意；第四，行为人与相对人之间的民事行为应具备民事法律行为成立的有效要件。（4）表见代理的效力：表见代理对**本人产生有权代理**的效力，即在相对人与本人之间产生民事法律关系，本人应受表见代理人与相对人之间实施的民事法律行为的约束，享有该行为设定的权利和履行该行为约定的义务。本人不得以无权代理为抗辩，不得以行为人具有故意或过失为理由而拒绝承受表见代理的后果，也不得以自己没有过失作为抗辩。**表见代理对相对人来说，既可主张狭义无权代理，也可主张成立表见代理。**如果相对人认为向无权代理人追究责任更为有利，则可主张狭义无权代理，向无权代理人追究责任；相对人也可以主张成立表见代理，向本人追究责任。相对人对此享有**选择权**。

六、案例分析题

1、（1）《民法通则》第 63 条规定：“依照法律规定或者按照双方当事人约定，应当由本人实施的民事法律行为，不得代理”。本案中合同约定由赵某创作全部 20 副对联的行为是不得代理的行为，因为该行为具有极强的人身性，应当由行为人本人亲自完成。赵某无权委托他人代为履行。

（2）赵某儿子的行为的不属于无权代理。无权代理是指没有代理权而以他人的名义进行代理活动的民事行为，它包括没有代理权、超越代理权或代理权终止后的代理行为。无权代理经被代理人追认可以产生代理效果。但是不得代理的法律行为是不能由他人代理的行为，即使有合法的委托也不行，这些行为主要是具有人身属性的行为、违法行为或法律规定及合同约定的**不得代理**的行为。

2、（1）甲的行为是一种与第三人串通，损害被代理人利益的行为。乙委托甲将草药带到上海去 卖，而甲却将草药卖与丙，这本身就违背了被代理人的意思；甲在出让草药的过程中，私下收受了丙给予的好处费，将草药以低价卖给丙，并相约共同欺骗乙，这就是相互串通，共同损害被代理人乙的利益。

（2）我国《民法通则》第 66 条第 3 款规定：“代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人 and 第三人负连带责任。”因此，本案中甲与第三人丙应对乙的损失承担连带赔偿责任。

3、（1）可以。赵某委托钱某代为出售电脑，双方形成代理权法律关系，但钱某滥用代理权，与孙某恶意串通，损害被代理人赵某的利益，依据我国《民法通则》第 58 条规定，代理人和第三人恶意串通，损害被代理人利益的行为是无效民事行为。孙某不能依据无效民事行为而取得电脑的所有权，赵某有权基于其对电脑的所有权请求其返还电脑。

（2）钱某向周某出售 Modem 的行为是**无权代理行为，为效力未定行为**。赵某没有委托钱某出售 Modem，因此，钱某以赵某的名义出售 Modem 为自始没有代理权的无权代理行为，其行为效力处于不确定的状态：赵某可以追认该行为而使其有效；第三人周某在知道钱某为无权代理之后也可以催告赵某追认或者撤销该行为。

（3）周某享有催告赵某追认此买卖行为或者撤销该买卖行为的权利。本案中，周某为善意第三人，在狭义无权代理中，善意第三人享有**催告权和撤销权**。

第十章 诉讼时效与期限

一、单项选择题

1、A 2、B 3、B 4、C 5、B 6、A 7、C 8、A

1、甲向乙借款 10 万元，借款期为 1 年。半年后，乙出国深造，3 年后回来，向甲要求还款，甲还款了。后甲听朋友说，该借款已经过了诉讼时效期间，遂要求乙返还。乙不返还，甲诉至法院，对甲的诉讼请求，人民法院应（ ）。

A、不予支持 B、予以支持 C、不予受理 D、支持一半

2、诉讼时效期间届满，当事人丧失（ ）。

A、实体权利 B、胜诉权 C、起诉权 D、起诉权和实体权利

3、甲于 1995 年 5 月 12 日将小件包裹寄存乙保管处。5 月 14 日，该包裹被盗。5 月 25 日，甲提货时得知货物被盗。甲请求乙赔偿损失的诉讼时效期间至何时届满？（ ）

A、1996 年 5 月 14 日 B、1996 年 5 月 25 日

C、1997 年 5 月 14 日 D、1997 年 5 月 25 日

4、诉讼时效中止后，从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间（ ）。

A、重新计算 B、不再计算 C、继续计算 D、届满

5、债务人向债权人表示同意延期履行拖欠的债务，这将在法律上引起（ ）。

A、诉讼时效的中止 B、诉讼时效的中断

C、诉讼时效的延长 D、诉讼时效的改变

6、甲租用乙的房屋，半年后甲拒付租金，乙请求甲支付租金的诉讼时效为（ ）。

A、1 年 B、2 年 C、6 个月 D、9 个月

7、甲出售一批奶牛给乙，双方约定，甲于 1999 年 11 月 4 日在其养牛场向乙交付奶牛，乙于一个月后向甲付款（12 月 4 日）。一个月后，乙没有付款，而甲也忙于其他事务无暇顾及。2001 年 7 月 4 日甲因车祸受伤成了植物人，因对由谁担任其监护人发生争议，迟至 2001 年 8 月 4 日才确定了由丙担任甲之监护人。2002 年 2 月 3 日丙清理甲的财产时，发现尚有乙的欠款没有追回，遂向乙主张权利，因乙认为该债务诉讼时效期间已过不愿偿还发生纠纷。则依法，甲向乙请求偿还债务的诉讼时效期间至何日届满？（ ）
诉讼时效中止

A、2000 年 12 月 4 日 B、2001 年 12 月 4 日

C、2002 年 1 月 4 日 D、2002 年 2 月 4 日

8、1974 年 3 月 1 日晚张某被人打成重伤。经过长时间的访查，于 1993 年 6 月 30 日张某掌握确凿的证据证明将其打伤的是李某。这时，张某应在什么时候之前向李某提出要求赔偿的请求？（ ）

A、1994 年 3 月 1 日 B、1994 年 6 月 30 日

C、1995 年 6 月 30 日 D、1995 年 3 月 1 日

二、多项选择题

1、下列关于诉讼时效的表述中，正确的有（1、ABC ）。

A、诉讼时效是法律事实 B、诉讼时效是法律事件

C、诉讼时效具有强制性 D、诉讼时效是事实行为

2、村民甲将自己一辆旧车出售给村民乙，甲告诉乙：如存在问题，应在半年之内提出请求。乙见该车外表新颖，甚爱之，遂欣然应允。八个月后，乙在一次修车过程中，发现该车之发动机非约定之品牌，遂与甲发生纠纷。对此，下列说法中，正确的有（ 2、BD ）。

A、时效期间已过，乙已丧失胜诉权

B、时效期间未过，乙仍享有胜诉权

C、时效期间已过，因乙已放弃时效利益

D、时效期间未过，因乙未放弃时效利益

3、引起诉讼时效中断的事由有（3、BCD ）。

A、不可抗力 B、起诉 C、当事人一方提出要求 D、义务人同意履行义务

4、下列有关期间的立法表述中，属于除斥期间规定的有（ 4、ABC ）。

A、限制民事行为能力人订立的合同中，相对人可以催告法定代理人在 1 个月内予以追认

B、因重大误解订立合同的撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起 1 年内行使

C、赠与人的继承人对赠与的撤销权，自知道或者应当知道撤销原因之日起 6 个月内行使

D、租赁期间不得超过 20 年，超过 20 年的，超过部分无效

5、诉讼时效期间是（ 5、AC ）。

A、法定期间 B、约定期间 C、可变期间 D、不变期间

6、依照我国法律规定，下列各项中，诉讼时效期间为 1 年的有（ 6、ABCD ）。

A、身体受到伤害要求赔偿的 B、出售质量不合格的商品未声明的

C、延付或拒付租金的

D、寄存财物被丢失或者损毁的

7、1996年6月3日，某甲向某丙借款30万元，由某丁作为保证人。某丁和某丙约定：只有在某甲于债务届满两年还不还款时，某丁才代为履行。1997年6月3日，债务期限届满，某甲没有还款。到了1999年8月4日。某丙向某丁要求代为履行。某丁的一个律师朋友告诉某丁，该债务已经过了时效期间，不用还了。对此，下列说法中，正确的有（ 7、BD ）。

A、债务已经过了时效期间

B、债务没有过时效期间

C、时效期间应到1999年6月3日

D、时效期间应到2001年6月3日

8、甲于1998年9月10日向乙借款1万元，双方约定借款期限为1年。1年后，甲没有还款，但表示将在一个月内还清款项，乙表示应允。对此，下列说法中，正确的有（ 8、BC ）。

A、乙请求甲还款的诉讼时效期间至2001年9月10日届满

B、乙请求甲还款的诉讼时效期间至2001年10月10日届满

C、甲在一个月内还款的表示引起时效期间的中断

D、甲在一个月内还款的表示引起时效期间的延长

9、甲于4月1日与乙签订买卖合同，双方约定，乙应在合同订立之日起6个月内交货，交货时甲付款。则关于合同履行期间的计算，下列说法中，正确的有（9、BD ）。

A、期间应从4月1日开始计算

B、期间应从4月2日开始计算

C、期间至10月1日届满

D、期间至10月4日届满

三、名词解释

1、取得时效 2、诉讼时效 3、除斥期间

1、取得时效，是指占有他人财产，持续达到法定期限，即可依法取得该项财产权的时效。取得时效因其事实状态必须占有他人财产，又称占有时效。我国《民法通则》未规定取得时效制度。

2、诉讼时效是指因不行使权利的事实状态持续经过法定期间，即依法发生权利不受法律保护~~的~~时效。外国一些立法例将诉讼时效称为消灭时效。

3、除斥期间，又称预定期间，是指法律规定某种权利预定存在的期间，权利人在此期间不行使权利，预定期间届满，便发生该权利消灭的法律后果。

四、简答题

1、简述诉讼时效制度的作用。

（1）促使权利人行使权利。诉讼时效制度的作用之一在于促使权利人积极行使权利。权利人如不及时行使权利，就可能导致权利的丧失或不受法律保护，这就促使权利人在法定期间内行使权利，以维护自

己的利益。(2) 避免证据灭失。诉讼时效制度的作用之二在于避免证据灭失。一种事实状态长期存在，必致证据湮灭、证人死亡，此事实状态是否合法，殊难证明。实行时效制度，凡诉讼时效期间届满，即认为权利人丧失权利或不受法律保护，即以时效为证据的代用，避免当事人举证和人民法院调查证据的困难

五、论述题

1、试比较诉讼时效与除斥期间的异同。

诉讼时效和除斥期间都是以一定的事实状态的存在和一定期间的经过为条件而发生一定的法律后果，都属于法律事件。其目的都在于督促权利人及时行使权利及维护法律秩序。但二者又有不同，其主要区别是：

(1) 构成要件不同。诉讼时效须同时具备两个要件，即法定期间的经过和权利人不行使权利的事实状态；除斥期间只需要一个要件，即法定期间经过。(2) 适用对象不同。诉讼时效一般适用于债权请求权；除斥期间一般适用于形成权，如取回权、放弃权、撤销权等。(3) 法律效力不同。依《民法通则》的规定，诉讼时效届满后，实体权利本身并不因此而消灭；而除斥期间届满后，消灭的是实体权利本身。此外，时效利益不能预先抛弃，但对于已完成的时效利益，可以抛弃。如超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受时效限制。抛弃诉讼时效利益的行为，可视为权利人权利的实现，而不是创设新的权利。至于除斥期间届满，权利人丧失了实体权利，抛弃利益的行为则可创设某种权利。(4) 期间性质不同。诉讼时效期间是可变期间，诉讼时效期间可适用中断、中止、延长的规定；除斥期间是不变期间，不可适用中断、中止和延长的规定。

第十一章 物权概述

一、单项选择题

1、C 2、D 3、C 4、A 5、B 6、A 7、B 8、C 9、A 10、A

1、甲将三间私房中的西屋两间作价5万元投入与丙合伙办的综合商店，又将东屋出租给乙居住。现甲因急事用钱，要将整个房屋转让。乙和丙均欲以同一价格购买，甲（ ）。

- A、应将整个房屋卖给乙
B、应将整个房屋卖给丙
C、按照房屋的使用现状，分别卖给乙和丙
D、可以任意选择乙或者丙作为购买者

2、甲有祖传珍贵玉器一件，乙丙均欲购买之。甲先与乙达成协议，以5万元价格出售之，双方约定，次日交货付款。丙知晓后，当晚即携款至甲处，欲以6万元价格购买之。甲欣然应允，并即交货付款。对此，下列表述中，正确的是（ ）。

- A、甲与丙之买卖合同无效
B、甲与乙之买卖合同无效
C、乙得请求丙交付该玉器
D、乙得请求甲承担违约责任

3、下列民事权利中，不属于物权的是（ ）。

- A、典权 B、抵押权 C、隐私权 D、房屋所有权

4、根据物权是否具有独立性不同，物权可以分为（ ）。

- A、主物权和从物权 B、有期限物权和无期限物权

C、动产物权、不动产物权和权利物权 D、用益物权与担保物权

5、甲将自己所有的一套书卖给乙，但甲还想留阅一段时间，遂又与乙达成协议，借阅该书一个月，乙表示应允。乙取得该套书所有权的交付方法为（ ）。

A、简易交付 B、占有改定 C、指示交付 D、拟制交付

6、甲将收藏的一件明代瓷器出售给乙，乙当场付清价金，约定甲 10 天后交货。丙听说后，表示愿意加倍的价钱购买。甲当即决定卖给丙，约定第 5 天交货，并收定金若干。乙听得此事，诱甲七岁子将瓷器从家中取出给她。在瓷器为乙占有的期间，该瓷器所有权应归（ ）。

A、甲 B、乙 C、丙 D、乙丙共有

8、王某在吃饭时丢失瑞士名表罗西尼一块，餐厅人员拾得后交给公安部门。王某未在规定期限内前去认领，公安部门按照有关规定交寄售商店出售。孙某从该商店买得该手表，将手表送给女友林某作生日礼物。手表在林某第二天乘公交车时被偷去，小偷下车后即以 100 元的低价卖给郑某。该手表的所有权属于（ C ）。

A、王某 B、孙某 C、林某 D、郑某

9、1996 年甲将自己的三间私房作价 2 万元转让给乙，乙略加修缮，居住一年后以 4 万元的价格转让给丙，丙居住一年后以 5 万元的价格转让给丁。以上几次转让均未办理私房过户手续。在丁居住其间，房屋所在地被该城市规划为对外经济开发区，该房屋价格涨至 20 万元，甲、乙、丙、丁就房屋所有权发生争议。该房屋所有权应属于（ ）。

A、甲 B、乙 C、丙 D、丁

10、甲乙（均为某村村民）订立借款合同一份，作如下约定：甲借给乙 10 万元，乙交付甲一件黄金饰品作担保，3 年后乙归还本金，甲归还该饰品，如乙无力还款，则该饰品归甲所有。对此，下列说法中正确的是（ ）。

A、甲乙之间关于“如乙无力还款，则该饰品归甲所有”的约定无效

B、因甲乙之间关于“如乙无力还款，则该饰品归甲所有”的约定无效，故担保合同无效

C、因甲乙之间的担保合同无效，故其借款合同无效

D、担保合同的全部条款有效，故甲乙之间的借款合同有效

二、多项选择题

1、下列物权中，属于登记物权的有（1、ABC ）。

A、房屋抵押权 B、土地所有权 C、城镇国有土地使用权 D、留置权

2、甲向乙借款，双方并且约定由甲提供轿车一辆设定抵押，但甲提出应在抵押合同中写明抵押权的存续期限为 3 年，乙表示同意。双方办理了抵押登记。登记部门告知甲乙，应每年到登记部门更新登记，否则，

抵押权消灭。后因借款合同诉讼时效期间届满，乙主张行使抵押权时与甲发生纠纷。对此，下列说法中，不正确的有（ 2、ABC ）。

- A、本案中抵押权的存续期间为 3 年
- B、本案中抵押权的存续期间为 1 年
- C、因借款合同诉讼时效期间届满，抵押权当然消灭
- D、抵押权可因借款合同得到履行而消灭

第十二条 当事人约定的或者登记部门要求登记的担保期间，对担保物权的存续不具有法律约束力。

担保物权所担保的债权的诉讼时效结束后，担保权人在 **诉讼时效结束后的二年内** 行使担保物权的，人民法院应当予以支持。

3、甲和乙共有房屋三间，出租给丙开办商店。现丁要向戊借款 5 万元，在丁的要求下，征得乙的同意后，甲将其在上述三间房屋中的共有份额抵押给戊，并在通知丙后，到房屋管理局作了登记。对其中的法律关系，下列表述正确的是（AB ）。

- A、房屋抵押后，甲、乙与丙之间的租赁合同继续有效
- B、在以出卖共有份额的方式实现该抵押权时，如果 **乙与丙** 都愿意以同一价格购买，则应卖给乙
- C、在以出卖共有份额的方式实现该抵押权时，如果乙与丙都愿意以同一价格购买，则应卖给丙
- D、在以出卖共有份额的方式实现该抵押权时，甲、乙与丙之间的租赁合同即告终止

4、下列属于法定孳息的有（ 4、AC ）。

- A、房屋租金 B、违约金 C、贷款利息 D、合同价金

5、财产所有权是一种（5、ACD）。

- A、自物权 B、他物权 C、完全物权 D、绝对权

6、下列物权中，不属于法定动产物权的是（6、ABD）。

- A、抵押权 B、质权 **C、留置权** D、典权

7、下列属于所有权的原始取得方法的有（ 7、ABCD ）。

- A、某甲误将某乙的一颗钻石加工成钻石戒指，某乙补偿某甲料钱、工钱后取得戒指的所有权
- B、国家取得无人继承又无人受遗赠的遗产所有权
- C、王某将左邻李某委托看管的一匹瘸腿马直接卖给右邻赵某，赵某因善意取得该马的所有权
- D、农民收割自家责任田中的庄稼，并因此取得收获物的所有权

不依所有人的意思而取得：生产、收取孳息、没收、先占、添附、遗失物的取得、埋藏物、隐藏物的发现、善意取得、时效取得

8、下列请求权中，属于物权请求权的有（ 8、ABC）。

- A、妨碍排除请求权 B、恢复原状请求权
C、消除危险请求权 **D、侵权损害赔偿请求权**

9、李某与于某签订了房屋租赁合同，李某租用于某的房屋，合同履行期间，于某又将出租房屋出售给王某，王某因急需利用此房经营，要收回李某租用的房屋，那么，下述表述不正确的有（**ABC**）。

- A、李某与于某之间的租赁合同因出租房屋所有权变更而自动失效
B、于某与王某之间的买卖合同因房屋存在租赁合同而无效
C、因租赁合同期间未满，王某尚未取得房屋的所有权
D、李某有权继续租赁承租的房屋直到租赁合同期满

三、名词解释

- 1、物权 2、物权的优先效力 3、物上请求权 4、公示原则 5、公信原则

四、简答题

- 1、简述物权的法律特征。
2、如何认识物上请求权的性质？
3、简述物权请求权与债权请求权的区别。

五、论述题

试述物权法定主义。

六、案例分析题

1、王某有私房三间，经协商，王某以5万元的价格将房屋出售丁某，双方签订了买卖合同，丁某交付了价金。三日后，李某了解到王某要出售私房，遂与王某协商，愿以7万元的价格购买王某的私房，王某同意，双方签订了房屋买卖合同，李某交付了7万元购房款，王某和李某到房产局办理了房屋产权过户手续，办妥过户手续后，王某找到丁某，告知房屋已出售给李某，并退回了丁某交付的购房款，丁某不同意，要求王某交付房屋，王某则以房屋已办理了过户手续为由拒绝交付房屋，丁某诉至法院，要求法院判定王某和李某的房屋买卖合同无效，要求王某交付房屋给自己。

问：（1）本案涉及哪些法律关系？

（2）本案中，房屋所有权应由谁享有？为什么？

1、（1）本案涉及两个法律关系：王某和丁某的房屋买卖合同关系，王某和李某的买卖合同关系。

（2）房屋所有权应归李某。本案诉争标的物房屋，房屋是不动产，根据法律规定，房屋所有权自办理产权过户登记手续之时起转移，如果仅仅交付房屋，但未办理产权过户手续，所有权不视为转移，房屋登记过户手续具有公示效力，对抗第三人。本案中，丁某虽与王某签订了书面买卖合同，并交付了购房款，但因未办理产权过户手续，因此，房屋所有权并未转归丁某，丁某与王某之间存在的是债权债务关系。相反，李某与王某办理了所有权过户手续，房屋所有权移转归李某所有，李某与王某之间存在的是物权关系，**根据物权的优先效力**，丁某不能主张李某与王某间的房屋买卖行为无效，因此，本案丁某要求法院确认王某与李某的买卖合同无效的主张不能得到支持，**但丁某可以要求王某承担违约责任。**

参考答案

一、单项选择题

1、C 2、D 3、C 4、A 5、B 6、A 7、B 8、C 9、A 10、A

二、多项选择题

1、ABC 2、ABC 3、AB 4、AC 5、ACD 6、ABD 7、ABCD 8、ABC

9、ABC 10、ABD

三、名词解释

1、物权是权利人直接支配其标的物，并享受其利益的排他性权利。

2、物权的优先效力是指在同一标的物上有数个利益相互矛盾、冲突的权利并存时，具有较强效力的权利排斥具有较弱效力的权利的实现。物权的优先效力包括物权相互之间的优先效力和物权对于债权的优先效力。

3、物上请求权是指物权的权利人在其权利的实现遇到某种妨碍时，物权人有权对于造成妨碍其权利事由发生的人请求排除此等妨碍的权利。

4、公示原则是指物权在变动时，必须将物权变动的事实通过一定的方法向社会公开，从而使第三人知道物权变动的情况。不动产物权以登记作为物权变动公示的方法；动产物权以交付作为物权变动公示的方法。交付和登记是物权公示的基本方法。

5、公信原则是指一旦当事人变更物权时，依据法律的规定进行了公示，则即使依公示方法表现出来的物权不存在或存在瑕疵，但对于信赖该物权的存在并已从事了物权交易的人，法律仍然承认其具有与真实的物权存在相同的法律效果，以保护交易安全。

四、简答题

1、（1）物权是权利人直接支配物的权利；（2）物权是权利人直接享受物的利益的权利；（3）物权是排他性的权利。

2、物上请求权是以物权为基础的一种独立的请求权。（1）物上请求权是请求权，是在物权受到妨碍时发生，是物权人请求权特定的人（妨碍物权的人）为特定行为（除去妨碍）的权利，为行为请求权。它不以

对物权标的物的支配为内容，故不是物权本体。（2）物上请求权是物权的效用，它以恢复物权的支配状态为目的，在物权存续期间不断的发生。（3）物上请求权附属于物权，其命运与物权相同，即其发生、移转与消灭均从属于物权。

3、（1）物权请求权是在物权的完满状态受到妨害或者可能受到妨害时，以恢复物权的完满状态为目的提出的请求权，是一种旨在保护物权的防卫性请求权。债权请求权一般是要求对方当事人为给付，而只有在对方当事人为给付的情况下，债权人的权利才能得到实现，因此，债权请求权是一种索求性请求权。（2）物权请求权并不需要法律的特别赋予，也无须根据一定的法律关系产生。因此，物权请求权不能转让。债权请求权的产生必须有法律上特别的原因，而且债权请求权可以转让。（3）物权请求权的效力优先于债权请求权的效力。（4）物权请求权原则上不考虑相对人是否有过错。

五、论述题

1、物权法定主义是指在物权的创设上，由法律规定物权的种类和内容，不允许当事人依其意思设定与法律规定不同的物权。现代各国民法，就物权的创设大都采法定主义。

物权法定主义原则是在罗马法时就已经确定的原则。以后各国物权法均毫无例外地继受了罗马法中确定的这一原则，其原因主要是：（1）整理旧物权类型的需要。近代物权法定主义原则是资本主义民法首先完全确立的，当时针对十分复杂的封建土地关系，为避免允许种种繁杂的权利登记而造成的混乱结果，使权利体系得以简明化，民法上需要对物权（主要是土地权利）的类型及内容作出明确规定。这样规定的更深层次的意旨在于一方面限制土地所有权的效力，不赋予所有权人任意设定他物权的权限，另一方面限制过多繁杂的权利对土地及其他财产所有权的束缚，从而赋予所有权以独占性、完全性。（2）物尽其用的考虑。物权与社会经济有密切的联系，如果允许任意创设物权种类，对所有权设定种种的限制和负担，会影响对物的利用。以法律明确物权的种类和内容，尽量将切合现实的物权形式纳入物权法，建立能够满足社会经济关系的发展需要的、权利种类简明、效力明确的物权体系，有助于物的利用。（3）保护交易安全的要求。物权具有排他性，通常会涉及第三人的利益，所以物权的存在及其变动应力求透明。如果允许当事人自由创设物权，不仅易于给第三人造成损害，而且还给物权的公示增加了困难，因为法律不可能对每一种当事人所创设的物权都提供一种相对应的公示方法。在物权的种类和内容法定化以后，便于物权的公示，以确保交易的安全和快捷。

按照物权法定主义原则的要求：（1）物权的种类不得创设，即不得创设法律未规定的新种类的物权。例如对于担保物权，虽然世界各国关于担保物权的种类很多，但在我国就只能依《担保法》及其他法律设定其认可的抵押权、质权、留置权等担保物权形式。（2）物权的内容不得创设，即不得创设与法律规定的内容不同的物权。例如，创设不移转占有的质权，即使名为质权，但由于与质权的法律规定的内容不同，故也是不允许的。

当事人如果违反物权法定主义原则的要求，其行为一般不发生物权效力，但法律也可以用明文规定的形式承认其一部分的效力。如规定典权的期限不能超过30年，但当事人关于典期的约定超过30年时，并非典权无效，而是可将典期缩短为30年。法律还可以对物权的内容规定一定的范围，当事人可以在这个范围内自由选择。例如地役权的内容当事人就可以根据法律规定的内容选择其中的一种或数种设定。

物权的种类和内容法定，在这一点上与债权不同。债权依合同自由原则，当事人在不违反法律和社会公共利益的范围，可以创设任何种类的债权。法律也往往不限制合同的种类和内容，允许当事人协商确定合同的内容，并承认其效力。

六、案例分析

1、（1）本案涉及两个法律关系：王某和丁某的房屋买卖合同关系，王某和李某的买卖合同关系。

（2）房屋所有权应归李某。本案诉争标的物系房屋，房屋是不动产，根据法律规定，房屋所有权自办理产权过户登记手续之时起转移，如果仅仅交付房屋，但未办理产权过户手续，所有权不视为转移，房屋登记过户手续具有公示效力，对抗第三人。本案中，丁某虽与王某签订了书面买卖合同，并交付了购房款，但因未办理产权过户手续，因此，房屋所有权并未转归丁某，丁某与王某之间存在的是债权债务关系。相反，李某与王某办理了所有权过户手续，房屋所有权移转归李某所有，李某与王某之间存在的是物权关系，**根据物权的优先效力**，丁某不能主张李某与王某间的房屋买卖行为无效，因此，本案丁某要求法院确认王某与李某的买卖合同无效的主张不能得到支持，**但丁某可以要求王某承担违约责任。**

7、某甲委托某乙购买某品牌电视机。乙至百货公司购买时，正值该品牌电视机举行有奖销售。乙选购了一款电视机并按照规定得到3张抽奖券，但未把这3张抽奖券交给甲。后来开奖，奖券中的一张中了头奖，可得手机一部。这部手机应当（ ）。

- A、归某甲所有
- B、归某乙所有
- C、归某甲所有，但应适当奖励某乙
- D、归甲、乙二人共有

10、甲在某风景区兴建别墅，与其邻居乙约定，乙不得在别墅前兴建房屋，以免妨碍眺望。半年后，乙将其房屋出售给丙，丙欲拆除旧房，兴建大厦。对此，下列说法中不正确的有（ ）。

- A、甲可依据债权协议向乙提出异议，要求丙停工
- B、甲可依据债权协议向丙提出异议，要求其停工
- C、甲得与丙协商停工事宜
- D、甲可依据债权协议向乙主张违约责任

第十二章 所有权

一、单项选择题一、单项选择题

1、C 2、A 3、C 4、C 5、A 6、C 7、D 8、B 9、C 10、A

1、法院采取财产保全措施扣押当事人的财产，其对扣押财产的占有是（ ）。

- A、善意占有
- B、非法占有
- C、合法占有
- D、恶意占有

2、财产所有人无权向第三人追索原物的情况是（ ）。

- A、原物由合法占有人非法转让给善意第三人的
- B、原物由合法占有人非法转让给恶意第三人的
- C、原物由非法占有人非法转让给第三人，该第三人是善意、无偿取得的
- D、第三人取得的财产是属于拾得物的

3、所有人不明的埋藏物，所有权归（ ）。

A、发现人 B、土地使用权人 **C、国家** D、发现人和土地使用权人

4、下列财产所有权取得方法中，属于继受取得的是（ ）。

A、添附 B、生产 **C、继承** D、拾得遗失物

依所有人的权利和意思基于法律行为或法律事件而取得所有权。买卖、互易、赠与、接受继承、遗赠

6、下列现象中，属于加工的是（ ）。

A、木窗安装在房屋上 B、大米与小米掺在一起做饭

C、将他人的玉石雕刻成玉器 D、啤酒中加入饮料

7、甲和乙共有两间平房，因拆迁，双方发生争议，甲主张该房是按份共有财产，乙主张是共同共有财产，但双方都没有证据证明共有性质，法院应当认定该房为（ ）。

A、按份共有 B、收归国有 C、甲个人所有 **D、共同共有**

8、下列共有财产，可以进行实物分割的有（ ）。

A、汽车 **B、粮食** C、耕牛 D、电视

9、甲、乙、丙共有房屋一套，甲欲以 4000 元的价格转让自己的份额，丙表示不买，甲未通知乙转让之事。3 个月后，丁愿意购买，甲接受了丁的购房款，此时，丙、乙均要求以同一价格购买甲的份额，甲父也要购买，甲的份额应当转让给（ ）。

A、乙与丙 B、丁 **C、乙** D、甲父

10、李里盖房挖地基时，挖出一瓦罐，内有银元 5000 块及棉布一块，上写“为防日寇搜查，特埋此。王天明，1938 年 4 月 2 日”。王天明是王伟的爷爷，1938 年被日寇杀害。该银元（ ）。

A、应归王伟所有 B、应归国家所有

C、应归李里所有 D、应归李里、王伟共有

11、下列不能成为集体组织财产所有权的客体的有（ ）。

A、森林、山岭、草原、荒地、滩涂

B、教育、文化、卫生、体育、交通设施

C、道路、交通设施

D、矿藏、水流

12、养牛专业户王某的一头奶牛得了重病，王某恐怕此牛得的是传染病，传染了别的牛会造成更大的损失，于是将此牛拉到野外抛弃。刘某经过时发现了，将牛拉回家中，经过刘某的精心喂养，此牛病愈并成为一头高产奶牛。半年后，王某听说此事，向刘某索要此牛。依照法律，王某（ ）。

- A、有权请求刘某返还此牛，因为刘某拾得牛并据为己有，构成不当得利
- B、有权请求刘某返还此牛，但应补偿刘某喂养此牛所指出的费用及劳务费
- C、无权请求刘某返还此牛，因为他的抛弃行为已使其所有权消灭，刘某基于先占而取得牛的所有权
- D、无权请求刘某返还此牛，但可以请求刘某给予适当补偿

13、下列财产应该依法收归国家所有的是（ ）。

- A、所有人不明的埋藏物、隐藏物
- B、遗失物
- C、漂流物
- D、失散的饲养物

14、甲公司出卖一批钢材给乙公司，订立合同的日期是 1999 年 3 月 1 日，并在合同中注明“钢材所有权在乙公司支付完货款时才转移”。乙公司在 1999 年 3 月 5 日支付第一笔货款，甲公司按照合同规定于 3 月 10 日将木材运至乙公司，乙公司验收并接受木材，并于 3 月 15 日付清剩余的货款。这批钢材的所有权转移时间是（ ）。

- A、3 月 1 日
- B、3 月 5 日
- C、3 月 10 日
- D、3 月 15 日

15、根据我国法律规定，下列财产中专属于国家所有的是（ ）。

- A、历史文物
- B、矿藏和水流
- C、土地
- D、生物化石

16、下列不属于收益行为的是（ ）。

- A、收取牛身体内部的牛黄
- B、采摘苹果树上成熟的苹果
- C、三资企业中白领工人领取奖金
- D、股民通过买卖股票获取股息

18、王某因长期出国工作，将所藏的一幅名人字画交给好友李某保管。李某将该字画挂在自己家中欣赏，来访的客人也都以为这幅字画是李某的。后李母生病，需用钱动手术，李某四处筹钱未果，遂将该字画以 5 万元的价格卖给并不知情的张某。王某回国后，发现自己的字画在张某家中，便向张某索要。对本案的认识，下列说法正确的是（ ）。

- A、该幅字画应归张某所有
- B、如李某不能赔偿王某的损失，该字画的所有权就归王某
- C、该幅字画应归王某所有
- D、王某可以收回字画所有权

19、依照我国法律，下列属于无主物的是（ ）。

- A、附合物
- B、抛弃物
- C、混合物
- D、加工物

20、李四为一精神病人，将家中的一万元现金抛洒在自家门前，为他人所捡。因李四的监护人要求拾得人返还而引起纠纷。下列表述正确的是（ ）。

- A、一万元现金为抛弃物，拾得人享有所有权
- B、一万元现金为抛弃物，国家享有所有权
- C、李四的抛弃行为不具有效力，拾得人应予返还
- D、如果一万元现金为李四的个人财产，则抛弃行为具有效力，拾得人不予返还

21、下列各项属于财产所有权的原始取得的是（ ）。

- A、叔叔送给今年刚满 7 岁的小明一辆自行车作为生日礼物
- B、小张继承哥哥的一处房子
- C、小陈的 50000 元存款共得利息 1000 元
- D、10 岁的小高把爸爸给买的铅笔刀送给小朋友

24、某块河滩地曾属甲村所有，因洪水将该地的表层浮土卷走，只剩下裸露的石头而被甲村撂荒。乙村经多年培土，使该块地变成良田。现甲村和乙村均主张对该块地的所有权。应如何处理？（ ）

- A、应支持甲村对该块地的所有权，但甲村应给乙村相应的补偿
- B、应支持乙村对该块地的所有权，但乙村应给甲村相应的补偿
- C、由甲村和乙村按份共有
- D、由甲村和乙村共同共有

25、王、潘两家同往李村。王家有子王达，潘家有女潘美，两人正在恋爱。两家为子女结婚住房问题议定由潘家出钱，王家出工，在王家已有的三间平房上面加盖上房三间作新人成亲之用。双方对上房三间的权属未作约定。上房三间盖成后，王达和潘美因性情不合解除恋爱关系。为此，王、潘两家反目成仇，并对房屋权属发生争议。根据民法原理，上房三间的所有权应属谁？（ ）

- A. 王家因附合而取得所有权，但应返还潘家所出之钱
- B. 王家因加工而取得所有权，但应返还潘家所出之钱
- C. 潘家因出钱而取得所有权，但应给王家适当补偿
- D. 王家和潘家因合作建房而成为房屋的共有人

二、多项选择题

1、下列行为属于法律上的处分的是（ 1、ABD ）。

A、将代别人保管的几箱苹果中即将发霉的一些卖掉

B、向乞讨的流浪汉施舍饭食

C、将年久失修的房屋自己加以修缮

D、将得病的狗弃于荒野之中

2、下列对他人之物的使用，不为侵权的有（ 2、ABD）。

A、未经许可而用别人的三轮车将突然晕厥的女友送到医院

B、为翻盖房屋而使用邻居的宅基地搭脚手架

C、明知为邻居家的材料加工成门窗安装在自家房子上

D、租期已满而继续交房租，房东也未提异议

3、甲擅自将乙借给他的手表出让给丙，下列表述，哪些是正确的？（3、ABC ）

A、甲以自己的名义出让给丙，甲丙之间的合同属于效力未定的合同

B、甲以乙的名义出让给丙，甲丙之间的行为属于无权代理行为

C、丙因善意而取得该手表的所有权

D、丙只能因乙的追认才能取得该手表的所有权

4、处理相邻关系应遵循的原则是（4、ABCD ）。

A、有利生产 B、方便生活 C、团结互助 D、公平合理

5、甲欠乙 100 元，一天甲将 4 张面值 25 元的奖券拿给乙，说：“本该给你钱的。这 4 张 25 元的奖券，一年后可以兑现，利息比一般的存款高。”乙表示同意并收下了奖券。第二年 4 张奖券中的一张得了特等奖，奖金 1 万元。甲得知后，就立即找到乙，要用 100 元换回那 4 张奖券，乙不同意。下列说法中不正确的有（5、ACD ）。

A、奖券的所有权归甲，奖金的所有权也归甲

B、奖券的所有权归乙，奖金的所有权也归乙

C、奖券的所有权归甲，奖金的所有权归乙

D、奖券的所有权归乙，奖金的所有权归甲

6、下列选项中，不适用善意取得的动产是（6、ABCD ）。

A、采登记对抗主义的动产 B、非以无记名有价证券表彰的债权

C、法律禁止流通的物品 D、遗失物和盗赃

7、李某将一部手机丢失，孙某捡到后，委托做手机旧货交易的朋友王某（有营业执照）在旧货市场上出卖，胡某买下该手机，后被李某发现，要求胡某返还手机。对此，下列判断正确的是（7、AD）。

- A、胡某已经取得手机的所有权，理由是善意取得
- B、胡某没有取得手机的所有权，理由是该手机为遗失物
- C、李某有权请求胡某返还手机
- D、李某只能请求孙某承担责任

8、在下列民事关系中，哪些应按照相邻关系处理？ 8、ABC

- A、甲在乙的房屋后挖菜窖，造成乙的房屋基础下沉，墙体裂缝引起纠纷（地基动摇防免关系）
- B、甲新建的房屋滴水，滴在乙的房顶上，引起纠纷（建筑越界、相邻环保关系）
- C、甲村在河流上游修建拦河坝，使乙村用水量剧减，引起纠纷(相邻用水关系)
- D、甲家与乙家相邻，甲家的猫闯入乙家，打碎乙家的花瓶，引起纠纷

10、土地所有人在其权利范围内享有排他的支配权，下列行为中，所有权人依法不得请求排除的有（10、ABCD）。

- A、地铁公司在地下开凿地铁隧道 B、电力公司在地上架设输电线路
- C、电信公司在地下铺设通信光缆 D、航空公司在地上通航飞机

11、下列财产可作为公民个人财产所有权客体的有（ 11、ABD ）。

- A、房屋 B、交通工具 C、土地 D、林木

12、下列土地属于国家所有的有（12、ABCD）。

- A、城市市区的土地
- B、农村集体经济组织全部成员转为城镇居民时，原属于其成员集体所有的土地
- C、因国家组织移民、自然灾害等原因，农民集体迁移后不再使用的原属于迁移农民集体所有的土地
- D、城镇居民的宅基地

13、下列现象中，属于事实上处分的是（13、BD）。

- A、出售商品 B、粮食被食用
- C、赠送电视 D、钢铁投入生产转化为汽车

14、下列现象中，引起所有权消灭的原因有（14、ABCD）。

- A、公民死亡 B、煤在生产中燃烧
- C、丢弃旧沙发于垃圾站 D、家具被洪水冲走

三、不定项选择题

（一）1996年5月1日，某甲在公园游玩时，把佩戴的一圈项链丢失。该项链被公园的管理人员拾得后交给了有关的行政管理部门。因某甲未能在行政管理部门规定的保管期限内前去认领，该行政管理部门即依照有关规定将项链交给代售店拍卖。这块项链后来被某乙以拍卖价买下。1997年秋，某乙因参加运动会，把项链放在更衣室中，因人多混杂，管理不善，项链被小偷偷走。1998年1月，这个小偷被抓获。在审讯过程中，小偷供认自己曾偷得一块项链，并已将该项链以400元现金卖给了同事某丙，某丙并不知情。经查，项链的失主为某乙。某乙即根据公安局的通知前去认领。而某甲也偶然认得此项链是自己在公园丢失的那块，要求某乙返还，某乙不允；某丙也认为项链是自己买的，要求拥有该项链，三方争执不下，于是，某甲和某丙均起诉至人民法院，要求确认各自对项链的所有权。

1、在本案中谁最终享有项链的所有权？

- A、某甲 B、某乙 C、某丙 D、国家

2、某丙从小偷处购得项链的行为属于

- A、善意取得
- B、无因管理
- C、不当得利
- D、无效民事行为

3、行政管理部门将项链交给代售店拍卖的行为

- A、非法。因为侵犯了某甲对项链的所有权
- B、非法。因为行政部门的义务只是找到失主并归还项链
- C、合法。因为某甲超过认领期限而未认领，已经丧失了对项链的所有权
- D、合法。因为项链在此时已属无主财产，由国家取得所有权

4、某乙从代售店购得项链的行为，其结果为：

- A、不当得利
- B、所有权的转移
- C、买卖合同的履行

D、善意取得

四、名词解释

- 1、所有权 2、房屋的区分所有权 3、相邻关系 4、善意取得 5、先占 6、遗失物
7、埋藏物 8、隐藏物 9、添附 10、混合 11、附合 12、加工

五、简答题

- 1、简述所有权的特征。
- 2、简述所有权的权能。
- 3、房屋区分所有的内容。

六、论述题

试述善意取得的构成条件。

七、案例分析题

1、王某住一商住楼的二层，一层是街道办事处的房产，街道办事处将其作为退休工人的棋牌室，老人们天天在棋牌室打麻将，王某和孩子常在深夜被楼下的洗牌声惊醒，无法入睡，王某多次找办事处协商，要求其关闭棋牌室或限制晚上打麻将的时间，办事处则认为，打麻将是一项正常的娱乐活动，有益于老人的身心健康，拒绝了王某的要求。王某向法院起诉，要求限制打麻将时间。

问：王某的请求能否支持？

1、（1）王某住房与街道办事处的棋牌室系上下楼关系，是相邻的两处不动产，形成不动产相邻关系。（2）打麻将虽是正当娱乐活动，但必须以不妨害他人为限，办事处将一楼作为棋牌室，又不限制打麻将的时间，深夜打麻将，洗牌声构成噪音污染，势必影响楼上王某休息，因此，办事处行使不动产权利，侵害了相邻方的利益，应当停止侵害行为，王某的诉讼请求应当支持。

2、王某盖房，故用于某挖地基，一日，于某挖到一只古瓷瓶，后经文物鉴定机关鉴定，该瓷瓶属国家一级文物。王某认为该瓷瓶系在自己的宅基地下挖出，故瓷瓶应归自己所有。于某则认为，该瓷瓶系埋藏在地下的，是自己挖出的，应归自己所有。双方争执不下，后经第三人协商，双方达成书面协议：瓷瓶归王某、于某共同所有，因瓷瓶不能分割，于某将自己拥有的份额转让给王某，王某须在一个月内向于某支付转让款5万元。到期后，王某未支付转让款，于某诉至法院，要求王某按照协议约定支付转让款5万元。

问：该案如何处理？

2、（1）瓷瓶埋藏于地下，为于某挖得，此物系所有人不明的埋藏物瓷瓶虽埋藏在王某的宅基地下，因王某只是取得宅基地的使用权而非所有权，故瓷瓶的所有权并不归王某。**（2）**由于瓷瓶经鉴定为国家一级文物，按照有关法律，国家一级文物属于具有重大艺术、历史价值的文物，其所有权应属于国家，故瓷瓶的所有权属于国家。**（3）**瓷瓶所有权属于国家，王某、于某均不享有所有权，双方共有也就没有法律根据，据此，双方达成的共有协议无效，由于协议无效，瓷瓶归国家，王某也不承担支付5万元对价的义务。

参考答案

一、单项选择题

1、C 2、A 3、C 4、C 5、A 6、C 7、D 8、B 9、C 10、A

11、D 12、C 13、A 14、D 15、B 16、C 17、A 18、A 19、B 20、C

21、C 22、D 23、D 24、A 25、D

二、多项选择题

1、ABD 2、ABD 3、ABC 4、ABCD 5、ACD 6、ABCD 7、AD 8、ABC

9、AB 10、ABCD 11、ABD 12、ABCD 13、BD 14、ABCD 15、ABD

三、不定项选择题

(一) 1、B 2、D 3、CD 4、BC

四、名词解释

1、所有权是财产所有人在法律规定的范围内，对属于他的财产享有的占有、使用、收益、处分的权利。所有权属于物权，即直接管领一定的物的排他性权利，与同属于民事权利的债权构成财产权的两个分类。

2、房屋的区分所有权，是指根据使用功能，数人区分某一房屋而各专有其一部分，就专有部分享有单独所有权，并就该房屋及其附属物的共同部分，除另有约定的外，按其专有部分比例共有的房屋所有权。

3、相邻关系是指不动产相邻各方在对各自所有的或占有的不动产行使所有权或使用权时，因相互间依法应给予方便或接受限制而发生的权利义务关系。从实质上说，相邻关系是相邻不动产的所有人或占有人行使其权利的一种延伸或限制，因此，相邻关系从权利上讲，又称为相邻权，即两个或两个以上相互毗邻的不动产所有人或使用人(占有人)之间，一方行使所有权或使用权时，享有要求另一方提供便利或接受限制的权利。

4、善意取得又称即时取得，是指无权处分他人动产的让与人，不法将其占有的他人动产交付于受让人后，若受让人取得该动产时出于善意，即取得该动产所有权，原动产所有人不得要求受让人返还。

5、先占是指以所有的意思，先于他人占有无主的动产而取得其所有权的事实。在我国，先占取得动产所有权只存在于两种情况：(1)依法对所有人抛弃的废弃物品的先占，依据《废弃物品回收条例》的规定，拾得人对拾得的废弃物品可依据先占取得所有权；(2)依习惯先占取得所有权。

6、遗失物是指他人丢失的动产。遗失物并不是无主物，也不是所有人抛弃的或因为他人的侵害而丢失的物，而是因所有人不慎所丢失的动产。

7、埋藏物是指埋藏于土地之中且所有人不明的财产。

8、隐藏物是指隐藏于他物之中，并且所有人不明的财产。

9、添附是指不同所有人的财产或劳动成果合并在一起形成一种不能分离的新的财产，如果要恢复原状则在事实上不可能或者在经济上不合理。在这种情况下，就要确定这个新物的所有权的归属。添附包括混合、附和和加工三种形式。

10、混合是指不同所有人的动产混杂合并在一起，对原物已经不能识别，且难以分离从而形成新的财产。

11、附和是指不同所有人的财产密切结合在一起而形成新的财产，对原物虽然尚能辨明，但无法分离或分离后会大大降低新物的价值。

12、加工是指一方使用他人的财产加工改造，形成具有更高价值的新财产。

五、简答题

1、（1）所有权是绝对权。所有权不需要他人的积极行为，只要他人不加以干预，所有人自己便能实现其所有权。所有权关系的义务主体是所有权人以外的一切人。（2）所有权具有排他性。所有权属于物权，具有排他的性质。所有权人有权排除他人对于其所有物的干涉，并且同一物上只能有一个所有权存在，而不能同时并存两个或两个以上的所有权。（3）所有权是一种最完全的权利。所有权是所有人对于其所有物进行一般的、全面的支配的最全面、最充分的物权，它不仅包括对于物的占有、使用、收益，还包括了对于物最终予以处分的权利。（4）所有权具有弹性性。当所有物上设定的其他权利消灭，所有权的负担除去的时候，所有权仍然恢复其圆满的状态。（5）所有权具有永久性。即所有权的存在不能预定其存续期间。

2、（1）占有。即占有人对物的实际掌握、控制。所谓控制，可以是对物的直接把握，也可以是在自己力量范围内对物的控制。（2）使用。即指按照物的性能和用途对物加以利用，以满足生产、生活需要。使用是所有人的一项重要权能，拥有所有权的目的是，在绝大多数情况下，正是为了对物或财产加以利用，以实现物或财产的使用价值，因此，对财产的使用在一定意义上是财产所有人的目的。（3）收益。即指利用物并获取一定的经济利益。所有权人取得其财产的收益，通常是对物或财产使用的结果，即使用自己的财产取得收益。（4）处分。即指所有人依法对物进行处置，从而决定物的命运。处分包括事实上的处分（实物形态上的处分）和法律上的处分（价值形态上的处分）。

3、（1）专有部分。即数人区分一建筑物而各有的那一部分。以此专有部分为客体的区分所有权，为各区分所有人单独所有，在性质上与一般所有权并无不同。但此项专有部分与同一建筑物上其他专有部分有密切的关系，彼此休戚相关，具有共同的利益。因此区分所有人就专有部分的使用、收益、处分，不得违反各区分所有人的共同利益。（2）共有部分。即区分所有的建筑物及其附属物的共同部分，即专有部分之外的建筑物的其他部分。如建筑物的支柱、屋顶、外墙等基本构造部分，建筑物的楼梯、走廊、电梯、自来水管、贮水塔、消防设备、大门等公用部分。另外，还有仅为部分区分所有人所共有的部分，如各楼层间之楼板、房屋之间的隔墙。建筑物的共有部分，为相关区分所有人所共有，均不得分割。各区分所有人对共有部分，应按其目的加以使用。共有部分的修缮费以及其他负担，由各区分所有人按其所有部分的价值分担。

六、论述题

1、善意取得，又称即时取得，是指无权处分他人动产的让与人，不法将其占有的他人动产交付于受让人后，若受让人取得该动产时出于善意，即取得该动产所有权，原动产所有人不得要求受让人返还。善意取得制度是为维护动产交易的安全而设计的。其构成要件包括：

(1) 标的物须为动产。不动产的转让一般须经登记，因而不适用善意取得制度；善意取得的标的物仅限于动产，但以下几类动产不适用善意取得：第一，采登记对抗主义的动产：如船舶、航空器、机动车辆；第二，非以无记名有价证券表彰的债权；第三，法律禁止流通的物品如毒品、淫秽物品等；第四，未分离的不动产的出产物是该不动产的组成部分，不能成为善意取得的标的；第五，依法被查封的财产；第六，遗失物和盗赃原则是不适用善意取得，但货币、票据、通过竞买方式和交易所方式取得的动产除外。

(2) 受让人须基于交易行为而受让动产的占有。善意取得应以受让人取得受让动产的占有为要件。但是受让人的占有必须是通过交易行为而取得。若受让人不是因为交易行为而受让动产的占有时，即便受让人实际占有该动产，也不发生善意取得的效力。

(3) 受让人取得动产时须为善意。即受让人在受让动产时不知道或不应当知道让与人无处分权。受让人事后知道出让人无处分权的，对善意取得没有影响。在交易时受让人以明显不合理的低价受让财产的，应认定受让人不具有善意。

七、案例分析题

1、(1) 王某住房与街道办事处的棋牌室系上下楼关系，是相邻的两处不动产，形成不动产相邻关系。(2) 打麻将虽是正当娱乐活动，但必须以不妨害他人为限，办事处将一楼作为棋牌室，又不限制打麻将的时间，深夜打麻将，洗牌声构成噪音污染，势必影响楼上王某休息，因此，办事处行使不动产权利，侵害了相邻方的利益，应当停止侵害行为，王某的诉讼请求应当支持。

2、(1) 瓷瓶埋藏于地下，为于某挖得，此物系所有人不明的埋藏物瓷瓶虽埋藏在王某的宅基地下，因王某只是取得宅基地的使用权而非所有权，故瓷瓶的所有权并不归王某。(2) 由于瓷瓶经鉴定为国家一级文物，按照有关法律，国家一级文物属于具有重大艺术、历史价值的文物，其所有权应属于国家，故瓷瓶的所有权属于国家。(3) 瓷瓶所有权属于国家，王某、于某均不享有所有权，双方共有也就没有法律根据，据此，双方达成的共有协议无效，由于协议无效，瓷瓶归国家，王某也不承担支付 5 万元对价的义务。

5、下列现象中，不属于先占的是（ ）。

- A、无人继承又无人受遗赠的遗产
- B、从垃圾桶中捡得旧电视
- C、回家途中拾得一撞树死亡的野兔
- D、马路上拾得一落叶

9、下列所有权取得方式中属于国家所有权专有的有（ ）。

- A、征收
- B、税收
- C、接受无主财产
- D、接受无人继承的财产

17、卢某有坐落于某市某街的房屋一幢。卢于 1967 年下放回原籍，该房屋暂由刘某等人居住。1969 年因房屋过旧，刘某等人迁走，该房屋交由居委会代管。1969 年 11 月，王某夫妇无房居住，经居委会安排搬进该房暂住，当时讲明：“以后房主回来要房，除非他们另有房屋居住，否则你们就要搬走。”王某夫妇表示同意，将该房屋稍加修理，便搬进居住至 1976 年 5 月。因该房屋确实破烂不堪，王某夫妇未经居委会和市房管部门同意，也未告知房主卢某，便将房屋翻盖一新。后来，卢某发现自己的房屋被侵占改建，于 1985 年向人民法院提起诉讼，要求保护房屋所有权。对此房屋所有权的归属，下列说法中正确的是（ ）。

- A、房子应归卢某所有，但应该适当补偿王某夫妇
- B、房子应归卢某所有，王某夫妇侵害房屋所有权，应该承担赔偿责任
- C、房子归王某夫妇所有，但应该适当补偿卢某
- D、房子归王某夫妇和卢某共同所有

22、甲、乙共用小清河的水灌溉，甲的承包地在乙的上游。为确保农田灌溉，甲在河中筑了一条水坝，使下游的水量减少了三分之二。甲、乙为此发生冲突，对其纠纷的解决方案，下列说法不正确的是（ ）。

- A、甲应该根据乙的请求拆除水坝
- B、甲向乙支付适当赔偿，可以不拆除水坝
- C、甲、乙应当共同协商、合理分配用水
- D、甲未断绝水流，故乙无权请求甲拆除水坝

23、甲在处理家中旧物时，将一件旧棉袄当作垃圾扔掉，没发现妻子藏在口袋中的 3000 元国库券。乙发现后，欲据为己有。甲妻发现后，与甲一同找到乙索要国库券，乙拒不归还。对此案的分析，下列各项中正确的是（ ）。

- A、甲的抛弃行为使其对国库券的所有权消灭
- B、乙基于所有的意思占有该国库券，根据先占原则应取得国库券的所有权
- C、此国库券为埋藏物，乙为发现人，应取得所有权
- D、甲能证明其对此宗国库券的所有权，故乙应将国库券返还给甲

第十三章 共有

一、单项选择题

- 1、D 2、C 3、D 4、D 5、A 6、B 7、D 8、A 9、D 10、A
- 11、B 12、D 13、B

1、甲、乙共同共有的房屋出租后，因年久失修山墙倒塌砸毁承租人丙的汽车，关于赔偿责任的承担，表述正确的是（ ）。

- A、甲、乙按照共有份额的比例承担赔偿责任
- B、甲、乙各按 50%的比例承担责任
- C、甲承担赔偿责任
- D、甲、乙承担连带赔偿责任

2、甲、乙、丙三人各出资 2000 元买一条船后，甲欲投资开商店，故想转让自己的份额，甲通知乙、丙后，乙表示愿出 1500 元买下甲的份额，丁知道后愿以 2000 元买下，丙即表示愿以 2000 元买下。根据法律规定，甲应将其份额卖给谁？（ ）

A、乙 B、丁 **C、丙** D、丁或丙都可以

3、甲、乙共有一间房屋，甲拥有 20%的份额，乙拥有 80%的份额，出租给丙住，合同尚未到期，现甲欲将自己的份额转让，则下列论述正确的是（ ）。

A、乙有优先购买权，丙没有优先购买权

B、丙有优先购买权，乙没有优先购买权

C、乙、丙都有优先购买权，两人处于平等地位

D、乙、丙都有优先购买权，乙的优先购买权优先于丙的优先购买权

5、在按份共有中，按份共有人的共有权及于（ ）。

A、共有财产的全部 B、共有人的份额

C、有约定时为共有人的份额 D、无约定时为共有财产的全部

6、在按份共有中，对于共有财产所负税金，按份共有人应承担（ ）。

A、连带责任 **B、按份责任** C、连带责任或按份责任 D、连带责任和按份责任

7、甲是一机关单位干部，乙原为工厂工人，二人结婚已有 10 年。后乙辞职经商，依法登记为个体户。甲起初反对乙下海经商，但后来见收入不少，就不再反对，但一直没有参与乙的经营。乙的经营收入用于家庭消费和储蓄。一次因车祸导致乙损失货物价值 13 万元，债主找甲要帐。甲有存款 14 万元，这 14 万元是甲多年的工资收入以及继承其父亲财产所得。对于乙所负债务，下列说法中正确的是（ ）。

A、乙的债务是个人债务，依《婚姻法》的规定，夫妻之间的个人债务，由债务人自己承担，不能由共同财产承担。故此甲没有还债义务；

B、甲的 14 万元存款虽然是其个人财产，但夫妻间有相互扶养的义务，故甲有义务偿还乙所负债务；

C、应按照乙的经营收入所用于家庭消费而为乙所分享的比例，确定甲所应承担的该宗债务中的适当份额；

D、14 万元存款是夫妻共同财产，乙所欠债务是共同债务，故甲有义务偿还债务。

二、多项选择题

2、下列共有财产中，属于共同共有的财产是（ABD ）。

A、夫妻共同财产 B、家庭共有财产

C、妻子婚前财产 D、甲乙丙共有的尚未分割的遗产

3、甲与乙系继母子关系。甲的丈夫丙去世时留下甲、丙共同修建的房屋四间，但甲、乙未进行析产和继承，而是由甲、乙共同居住。后来乙通过熟人关系，将四间房屋产权变更为自己个人所有，并将房屋出售给善意的丁。下列论述正确的有哪些？（ 3、AC ）

A、乙的行为侵犯了甲对房屋的所有权

B、乙的行为没有侵犯甲对房屋的所有权，而是在行使自己的所有权

C、在析产和继承前，甲与乙对四间房屋共同共有

D、在析产和继承前，甲与乙对四间房屋按份共有

4、在对共有财产进行分割时，可以采用的分割方法为（4、ABC ）。

A、实物分割 B、变价分割 C、作价补偿 D、上述选项都不对

5、下列情况中成立共同共有关系的有（ 5、BD ）。

A、小王和小张各出资 2 万元，准备合伙购买化肥在本村销售；

B、甲与其邻居乙对两家的分界墙归属发生争议，甲主张为按份共有，乙主张为共同共有，双方均无证据；

C、甲将其经营的地毯厂折为 1000 股，卖给乙、丙各 200 股；

D、兄弟二人在共同生活期间购买的生活用品。

6、甲、乙、丙三人共有一辆拖拉机，农闲时往往有几个月搁置不用。乙、丙均想将拖拉机卖掉。甲外出之时，乙、丙二人就协商将拖拉机卖给了丁，卖得价款为甲留下一份，其他由乙、丙各自取走。甲回来后获悉此事，认为乙、丙未经自己同意无权出卖拖拉机。乙、丙认为应该少数服从多数。对此，下列说法正确的有（ 6、ABCD）。

A、乙、丙的行为侵犯了甲的份额所有权；

B、乙、丙的行为侵犯了甲的优先购买权；

C、如果丁取得拖拉机并非善意，则甲可以主张该买卖无效；

D、若丁善意取得拖拉机的所有权，则乙、丙应赔偿给甲造成的损失。

7、下列各项属于夫妻共同财产的有（ 7、AC ）。

A、婚姻关系存续期间，夫妻各自或共同劳动所得的收入和购置的财产；

B、财产系婚前财产或婚后财产无法查清的；

C、婚姻关系存续期间，复员、转业军人所得的复员转业费；

D、虽属婚前财产，但在共同生活中由双方共同长期使用、经营、管理的财产。

9、下列不须全体共有人同意即可为之的行为有（9、ABD）。

A、财产的保存行为；

B、财产的改良行为；

C、财产的转让行为；

D、履行财产所负担义务的行为。

三、名词解释

1、共有 2、准共有 3、按份共有 4、共同共有

四、简答题

1、简述共有的特征。

2、简述按份共有的特征。

五、论述题

1、试述按份共有人的权利义务。

六、案例分析题

1、1995 年，李某与张某出资购买了两辆东风牌汽车从事长途贩运，其中，李某出资 10 万元，张某出资 6 万元，双方约定：盈亏按照出资比例分担。两年中，双方赢利均按约定比例作了分配。1998 年，李某乘张某外出之机，将一辆车以 9 万元的价格出售给王某，双方办理了车辆过户手续，张某回来后，不同意卖车，要求李某追回该车，李某则认为，自己当初出资 10 万元，可以买一辆多汽车，因而认为自己有权出售汽车，张某诉至法院，要求确认李某和王某的买卖行为无效。

问：（1）李某与李某之间对汽车形成何种关系？（2）李某出卖汽车的行为是否有效？为什么？（3）王某能否取得汽车的所有权？为什么？

1、（1）李某、张某合伙买车从事运输，对汽车形成共有关系。（2）共有人之一处分共有财产，必须征得对方事前同意或事后追认，否则，处分行为无效。本案中，李某未经共有人张某同意擅自出售共有财产，其行为无效。（3）由于王某基于善意购买了汽车，并且办理了产权过户手续，因此，王某合法取得了汽车的所有权，张某不能要求王某返还汽车，但张某可以要求李某承担赔偿责任。

2、甲乙丙对某套房屋享有共有权，甲占有 50% 的份额，乙占有 30% 的份额，丙占有 20% 的份额。三方约定，该房屋轮流分别由甲乙丙使用 5 个月、3 个月和 2 个月。请回答下列问题：

（1）设甲现欲转让自己的份额，乙丙均主张优先购买权，应如何处理？

（2）设甲抛弃自己的份额，该份额归属如何？为什么？

（3）设乙在居住期间，房屋廊檐因年久失修掉落，砸伤行人，责任应如何承担？为什么？

2、（1）由甲决定将该份额转让给乙或丙。乙丙均为共有人，其优先购买权是平等的，故应尊重出卖份额所有人的意志，因此，由甲决定将该份额转让给乙或丙。

（2）抛弃份额归其他共有人。依据所有权的弹力性原则，其他共有人按照自己的份额相应增加。

（3）由甲乙丙负连带责任。修缮房屋是全体共有人的义务，因此，按民法理论，共有物致人损害属不可分之债，共有人负连带责任。

3、张庄、王庄、董庄三村分别按照 30%、30%、40%的比例共同投资兴建一座蓄水量 10 万立方米的水库，并约定三村按照投资比例分配水量。某年，李庄灌溉用水不足，与董庄达成协议：董庄从自己的用水量中供应李庄灌溉用水 1 万立方米，李庄支付价款 1 万元。供水时，流经两村之间的陈庄时，陈庄将水截流三分之二，灌溉本村农田。李庄因未及时灌溉，秧苗损失 3000 元。同时，李庄以为董庄故意减少供水，夜间派人偷偷将水库闸门打开放水 3 万立方米。因放水不当，造成张庄鱼塘中鱼苗损失 3000 元。王庄看到上述情形，决定将自己的 30%份额转让给魏庄。

问：（1）本案涉及哪些民事法律关系？

（2）王庄转让其份额，应履行什么义务？

3、（1）涉及的民事法律关系有：张庄、王庄、董庄对水库的共有关系、董庄与李庄的供水合同关系、陈庄截流李庄所买之水的侵权关系、李庄偷开水闸放水对张庄、王庄、董庄的侵权关系、王庄与魏庄的水库份额转让关系等六种。

（2）首先，作为对共有份额的处分，王庄应征得另两位共有人张庄和董庄的同意；第二，在转让时，因张庄和董庄作为共有人享有同等条件下的优先购买权，所以，王庄应将与魏庄协议的条件通知张庄和董庄，限期两方作出答复。

参考答案

一、单项选择题

1、D 2、C 3、D 4、D 5、A 6、B 7、D 8、A 9、D 10、A

11、B 12、D 13、B

二、多项选择题

1、ABCD 2、ABD 3、AC 4、ABC 5、BD 6、ABCD 7、AB 8、ABC

9、ABD

三、名词解释

1、共有是两个或两个以上的人（公民或法人）对同一项财产享有所有权。

2、准共有是指两个或两个以上的人（公民或法人）共同享有所有权以外的财产权。

3、按份共有亦称分别共有，是指两个或两个以上的人对同一项财产按照份额享有所有权。

4、共同共有是指共有人对全部共有财产不分份额地享有平等的所有权。

四、简答题

1、（1）共有的主体不是单一的，而是两个或两个以上的公民、法人或公民和法人。其主体是多数人，而不是单一主体。（2）共有的客体也是特定的独立物。共有物在共有关系存续期间，不能分割为各个部分由各个共有人分别享有所有权，而是由各个共有人共同享有其所有权，各个共有人的权利及于共有物的全部。（3）共有人对共有物或者按照各自的份额、或者平等地享有权利。但是，共有人对于自己权利的行使，并不是完全独立的，在许多情况下要体现全体共有人的意志，要受其他共有人的利益的制约。

2、（1）各个共有人对于共有物按照份额享有所有权。（2）各个共有人按照各自的份额对共有物分享权利、分担义务。（3）各个共有人虽然拥有一定的份额，但共有人的权利并不仅限于共有物的某一部分上，而是及于共有物的全部。

五、论述题

1、按份共有人除按其份额有对财产的占有权、使用权、收益权、处分权外，还享有一些可以按个人意愿单独行使的权利：（1）分出自己份额。行使这项权利要受到限制：第一，只有在不影响其他共有人共同经营的前提下方可要求分出实物。第二，法律或协议对分出权的行使有规定时，必须遵守这些规定。（2）转让自己份额。除非共有人另有约定，共有人依法将自己的份额转让给他人，无须征得其他共有人的同意。按份共有人死亡，其份额可以作为遗产为继承人所继承。公民不损害社会和他人的利益，可以抛弃其共有的份额，其抛弃部分的利益由其他共有人取得。（3）对其他共有人出售之份额享有优先购买权。按份共有人出售自己的份额，其他共有人在同等条件下有优先于其他人购买的权利。优先购买权的行使要符合相应的条件和程序。

按份共有人的义务有：（1）共有人与第三人发生的债权债务，如果权利义务可分，各共有人只按照各自份额承担义务。第三人也只能请求各共有人按其份额履行义务。（2）共有人与第三人发生的债权债务关系中的权利、义务是不可分的，共有人之间应负连带的权利义务。（3）各共有人的义务及于共有财产的全部，而不是仅对共有财产某一部分负有义务。

六、案例分析题

1、（1）李某、张某合伙买车从事运输，对汽车形成共有关系。（2）共有人之一处分共有财产，必须征得对方事前同意或事后追认，否则，处分行为无效。本案中，李某未经共有人张某同意擅自出售共有财产，其行为无效。（3）由于王某基于善意购买了汽车，并且办理了产权过户手续，因此，王某合法取得了汽车的所有权，张某不能要求王某返还汽车，但张某可以要求李某承担赔偿责任。

2、（1）由甲决定将该份额转让给乙或丙。乙丙均为共有人，其优先购买权是平等的，故应尊重出卖份额所有人的意志，因此，由甲决定将该份额转让给乙或丙。

（2）抛弃份额归其他共有人。依据所有权的弹性性原则，其他共有人按照自己的份额相应增加。

（3）由甲乙丙负连带责任。修缮房屋是全体共有人的义务，因此，按民法理论，共有物致人损害属不可分之债，共有人负连带责任。

3、（1）涉及的民事法律关系有：张庄、王庄、董庄对水库的共有关系、董庄与李庄的供水合同关系、陈庄截流李庄所买之水的侵权关系、李庄偷开水闸放水对张庄、王庄、董庄的侵权关系、王庄与魏庄的水库份额转让关系等六种。

（2）首先，作为对共有份额的处分，王庄应征得另两位共有人张庄和董庄的同意；第二，在转让时，因张庄和董庄作为共有人享有同等条件下的优先购买权，所以，王庄应将与魏庄协议的条件通知张庄和董庄，限期两方作出答复。

4、有关共有的性质，下列表述正确的是（ ）。

A、共有是所有权的历史类型 B、共有是所有权的权能

C、共有是所有权的种类 D、共有是所有权的联合

8、赵某和刘某共同出资购买了一间房并其出租给石某。在租赁期间，刘某因急需用钱，欲转让自己的共有份额。赵某和石某都表示愿意购买，该房屋（ ）。

A、在同等条件下应由赵某优先购买；

B、在同等条件下应由石某优先购买；

C、在同等条件下由刘某决定卖给谁；

D、根据二人的实际需要程度，由法院确定由谁购买。

9、甲欲开一饭店，想请厨师乙加盟，说：“你无需投资，店面、设备、资金都由我负责，你只负责厨房，利润分成你三我七”。乙欣然答应。饭店第一年盈利 10 万，二人合计后，决定用来扩大经营范围，开一家分号，于是未分成。翌年，饭店出现食物中毒事件，顾客索赔 20 万元，该责任（ ）。

A、应由甲全部承担

B、应首先由甲承担，不足部分方可由乙承担

C、甲承担 14 万元，乙承担 6 万元

D、应由甲、乙二人连带承担

11、甲的哥哥 1997 年底去世，留下遗嘱给甲一处房子作新房。甲与乙于 1998 年 1 月登记结婚，3 月接到房子并办理登记，搬进居住。因该房屋年久失修，且过于简陋，经有关部门同意后，二人对房屋进行了翻盖，共花费 6 万元。现二人离婚，对房屋的权属发生了争议。依法该房屋所有权应（ ）。

A、属于甲乙的夫妻共同财产，因为房屋办理登记时，二人已登记结婚，

B、属于甲单独所有，因为甲已于其哥哥去世时取得房屋的所有权；

C、属于甲乙的夫妻共同财产，因为甲的哥哥的遗嘱中已说明将房屋给甲和其妻子共有；

D、属于甲乙的共同财产，因为二人以共同财产对房屋进行翻盖。

10、王某写信给其侄女王芳，表示要赠与 5000 元美金，王芳回信表示接受，但此款因故一直未实际给付。后王芳与李岩登记结婚，婚后第六个月接到王某的赠金 5000 元美金。该项钱款依法（ ）。

- A、应属于王芳的婚前个人财产；
- B、应属于王芳与李岩的夫妻共同财产；
- C、属于婚前取得，但归二人共有；
- D、应视王某的意思而定其所有权之归属。

8、下列需要分割共同共有财产的情形有（ ）。

- A、子女成人，分家析产；
- B、父母亡故，遗产继承；
- C、感情破裂，夫妻离婚；
- D、目的达到，合伙解体。

第十四章 用益物权

一、单项选择题

1、天虹房地产开发公司于 1995 年 7 月 1 日以出让方式获得某市一块国有土地的使用权，使用年限为 40 年。经开发建成商品房后，1999 年 7 月 1 日将该宗房屋一并转让给大洋公司，大洋公司将其作为职工住宅分配给职工居住，职工李某于 2000 年 1 月 1 日搬入新居，此时李某对该土地的使用年限为（ ）。

- A、 40 年
- B、 70 年
- C、 35 年 6 个月
- D、 36 年

2、根据我国土地法，下列关于土地权利的表述，正确的是（ ）。

- A、城市市区的土地属于国家所有
- B、农村和城市郊区的土地属于集体所有（农村和城市郊区的土地除由法律规定属于国家所有的以外，属于集体所有）
- C、宅基地属于农民个体所有
- D、自留地、自留山属于农民个体所有

3、赵某将私房三间典与郑某，典价 5 万元。后郑某将该房租与陈某。郑某与陈某之间的租赁合同效力如何？（ ）

- A、无效，理由未经赵某同意 B、有效，理由无须经赵某同意
- C、效力未定，理由郑某欠缺出租权 D、无效，理由郑某未将该房出租的事实通知赵某

4、下列对国有土地使用权的最长期限的说法不正确的是（ ）。

- A、居住用地 70 年 B、工业用地 50 年
- C、教育、科技、文化、卫生、体育用地 50 年 D、商业、旅游、娱乐用地 50 年（40）

5、下列权利中不属于用益物权的是（ ）。

- A、土地承包经营权 B、抵押权
- C、土地使用权 D、典权

6、我国《民法通则》所明确规定的用益物权是（ ）。

- A、典权 B、地上权
- C、相邻权 D、承包经营权

7、下列权利不为典权人所享有的是（ ）。

- A、占有、使用、收益典物 B、出租典物
- C、转让典物 D、优先购买权

8、在我国，用益物权（ ）。

- A、只能在动产上设立 B、只能在不动产上设立
- C、可以在动产上设立 D、既可以在动产上设立也可以在不动产上设立

9、国有土地使用权取得的方式有两种，它们是（ ）。

- A、出让方式和赠与方式 B、出让方式和赠与方式
- C、赠与方式和划拨方式 D、划拨方式和出让方式

10、下列主体中，可以为宅基地使用权的权利主体的是（ ）。

- A、法人 B、村委会 C、自然人 D、村办企业

11、下列财产中，能够成为典权客体的是（ ）。

A、家具 B、电视机 C、汽车 D、房屋

二、多项选择题

1、BCD 2、ABC 3、ABCD 4、AC 5、ABCD 6、BC 7、ABC 8、ABCD

9、ABCD 10、ACD

1、在地役权法律关系中，下列表述正确的有哪些？（P241）

A、地役权是为特定人设定的 B、地役权是为需役地设定的
C、地役权可以是有偿取得的 D、地役权也可以是无偿取得的

2、国有土地使用权出让合同是（ ）。

A、要式合同 B、双务合同 C、有偿合同 D、实践性合同

3、典权的消灭方式包括（ ）。

A、回赎 B、作绝 C、别卖 D、混同

4、地役权的属性包括（ ）。

A、从属性 B、可分性 C、不可分性 D、独立性

5、地役权的消灭的特殊原因包括（ ）。

A、土地灭失 B、目的事实不能 C、抛弃 D、存续期间的届满

6、依照我国现行土地承包法，发包方和承包方在承包期内的权利义务关系，下列表述正确的是（ ）。

A、承包方全家迁入小城镇落户的，发包方有权收回承包土地

B、承包方全家迁入小城镇落户的，承包方有权保留其土地承包经营权

C、承包方全家迁入设区的市转为非农业户口的，发包方有权收回承包的土地

D、承包方全家迁入设区的市转为非农业户口的，承包方有权对其承包的土地依法进行流转

7、依照我国土地承包法，关于承包期限，下列表述正确的是（ ）。

A、耕地的承包期为30年 B、草地的承包期为30至50年

C、林地的承包期为30至70年 D、耕地、林地、草地的承包期均为30年

8、依照我国土地承包法，承包方对取得的土地承包经营权享有流转的权利，该权利包括（ ）。

A、转包权 B、出租权 C、互换权 D、转让权

9、依照我国土地承包法，不宜采取家庭承包的“四荒”农村土地，其土地承包经营权依法可采取哪些方式流转？（ ）

A、转让 B、出租 C、入股 D、抵押

10、依照我国土地承包法，对于家庭承包取得的土地承包经营权，承包方欲行使流转的权利，下列表述正确的有（ ）。

A、采取转让方式流转的，应当经发包方同意

B、采取互换方式流转的，应当经发包方同意

C、采取出租方式流转的，应当报发包方备案

D、采取转包方式流转的，应当报发包方备案

三、名词解释

1、用益物权 2、地上权 3、土地承包经营权 4、典权 5、回赎

6、找贴 7、作绝 8、别卖 9、地役权

四、简答题

1、简述用益物权的特征。

2、简述土地承包经营权的特征。

3、简述典权的特征。

五、论述题

试述地上权人的权利。

六、案例分析题

1、大明公司通过**划拨形式**获得一块土地使用权用于建设厂房，项目批准后，大明公司为了提高收益，更改图纸，将厂房改建成写字楼，因资金不到位，大明公司与通达公司签订合作建房协议，约定：大明公司负责写字楼的建设施工，通达公司提供建设资金 5000 万元，写字楼建成后，双方各分得写字楼的一半面积。写字楼建成后，大明公司拒绝按照协议分配楼房面积，只同意退还同达公司的建楼款。通达公司诉至法院，要求大明公司履行协议。本案如何处理？

1、（1）大明公司的土地是划拨取得，只能用于公益，划拨土地非经批准，不得用于商业开发牟利，大明公司违反划拨地的用途未经批准改建写字楼，其写字楼是违章建筑。（2）由于写字楼是违章建筑，大明公司与通达公司合作建房协议的标的物即为不法，因此，合建协议无效，双方互相返还财产。

参考答案

三、名词解释

- 1、用益物权是对他人所有的物，在一定范围内进行占有、使用、收益、处分他物权的权利。
- 2、地上权是因建筑物或其他工作物而使用国家或集体所有的土地的权利。
- 3、土地承包经营权是承包人（个人或单位）因从事种植业、林业、畜牧业、渔业生产或其他生产经营活动而承包使用、收益集体所有或国家所有的土地或森林、山岭、草原、荒地、滩涂、水面的权利。
- 4、典权是典权人支付典价，对他人的不动产进行占有、使用、收益的权利。
- 5、回赎是出典人向典权人提出以支付原典价消灭典权的单方行为。回赎是出典人的权利，它只需要出典人一方的意思表示并支付原典价即可，不必取得典权人的同意即产生效力。
- 6、找贴是在典权存续中出典人将典物所有权让与典权人，找回典物的当时价格与典价的差额，从而使典权消灭的一种方法。
- 7、作绝是指有期限的典权，附有“到期不赎，即作绝卖”条款的，因期限届满（作绝）由典权人取得所有权，典权亦因混同而消灭。
- 8、别卖是指典权附有到期不赎，听由典权人出卖典物收回典价条款时，因典物别卖于第三人而使典权消灭。
- 9、地役权是以他人土地供自己土地便利而使用的权利。

四、简答题

- 1、（1）用益物权以对标的物的使用、收益为其主要内容，并以对物的占有为前提。由此决定了用益物权的设立，以对标的物的占有为要件。也就是说，必须将标的物的占有（直接占有）移转给用益物权人，由其在实体上支配标的物。否则，用益物权的目的就无法实现。（2）用益物权是他物权、限制物权和有期限物权。用益物权是在他人所有物上设定的物权，是非所有人根据法律的规定或当事人的约定对他人所有物享有的使用、收益的权利。因而从其法律性质上讲，用益物权属于他物权。用益物权作为他物权，其客体是他人所有之物。它是所有人为了充分发挥物的效用，将所有权与其部分权能相分离，由用益物权人享有和行使对物的一定范围的使用、收益权能的结果。但是，用益物权的这种派生性并不影响用益物权作为一种独立的财产权的存在。用益物权是一种限制物权，它只是在一定方面支配标的物的权利，没有完全的支配权。用益物权还是一种有期限物权，它有一定的期限，在其存续期限届满时用益物权即当然归于消灭。（3）用益物权是不动产物权。用益物权的标的物只限于不动产。

（4）用益物权主要是以民法为依据，但也有以特别法为依据的。在法律适用上应当首先适用特别法，只有在特别法无规定时，才适用民法。

- 2、（1）承包经营权是存在于集体所有或国家所有的土地或森林、山岭、草原、荒地、滩涂、水面的权利。即承包经营权的标的，是集体所有或国家所有的土地或森林、山岭、草原、荒地、滩涂、水面，而不是其他财产。（2）承包经营权是承包使用、收益集体所有或国家所有的土地或森林、山岭、草原、荒地、滩涂、水面的权利。承包人对于承包土地等生产资料有权独立进行占有、使用、收益，进行生产经营活动，并排除包括集体组织在内的任何组织或个人的非法干涉。但承包人并不取得承包土地或其他生产资料的全部收益的所有权。（3）承包经营权是为种植业、林业、畜牧业、渔业生产或其他生产经营活动而承包使用、收益集体所有或国家所有的土地等生产资料的权利。种植，不仅是指种植粮食、棉花、油料等作物，

也包括树木、茶叶、蔬菜等。另外，在承包的土地或森林、山岭、草原、荒地、滩涂、水面经营林业、牧业、渔业等，都属承包经营权的范围。（4）承包经营权是有一定期限的权利。但应当根据从事承包经营事业的具体情况，确定承包经营的期限。

3、（1）典权是不动产物权。典权的标的物应以不动产为限。在我国的目前，典权的标的物是私有房屋。（2）典权是以支付典价而成立的物权。典权的设立，以支付典价为要件。（3）典权是占有、使用、收益他人不动产的物权。典权的成立，必须把占有转移给典权人，但不以直接占有为限，只要典权人取得间接占有即可。典权还以使用、收益为内容，其范围很广，除了当事人有特别约定加以限制外，凡是依物的性质可以进行的使用、收益，典权人都可为之。故其性质主要为用益物权。

五、论述题

1、地上权是因建筑物或其他工作物而使用国家或集体所有的土地的权利。地上权人的权利主要有：

（1）占有和使用土地。地上权就是为保存建筑物或其他工作物而使用土地的权利，因此使用土地是地上权人的最主要权利。地上权人对土地的使用权，应当在设定地上权的行为所限定的范围内进行。由于地上权为使用土地的物权，地上权人为实现其权利，自然以占有土地为前提。同时，地上权人也可以准用不动产相邻关系的规定。

（2）权利处分。地上权人可以处分其权利。这主要有以下几种情形：第一，转让。地上权人可以将其权利转让给他人，但合同另有约定不得转让的则不得转让。既然地上权是以保存建筑物或其他工作物为目的，则其必须与建筑物共命运，因此地上权人可以附随于其建筑物的处分而转让其处分权。在建筑物被出卖、赠与、继承时，地上权也随之转移。但是，在设定地上权时如果当事人对地上权的转让作了限制，则地上权人不得超出该限制转让其地上权。第二，抵押。地上权可以作为抵押权的标的物，此时，其地上的建筑或其他工作物也随之抵押。另外，当地上的建筑物或其他工作物抵押时，其使用范围内的地上权也随之抵押。

第三，出租。地上权人可以作为出租人将地上权连同地上的建筑物或其他工作物租赁给他人使用并收取租金。在地上权出租后，地上权人（出租人）仍须向土地所有人履行义务。但是，通过土地划拨取得的地上权，只有在下列几种情况下，才可以转让、抵押、出租：其一，土地使用者为公司、企业、其他经济组织和个人；其二，领有国有土地使用证；其三，具有地上建筑物、其他附着物合法的产权证明；其四，签订土地使用权出让合同，向当地市、县人民政府补交土地使用权出让金或者以转让、出租、抵押所获收益抵交土地使用权出让金。在其他情况下，通过划拨土地取得的地上权不得转让、出租、抵押。

（3）附属行为。地上权人可以在其地基范围内进行非保存建筑物或其他工作物的附属行为，如修筑围墙、种植花木、养殖等。

（4）取得地上建筑物或其他工作物的补偿。地上权人在土地上建造的建筑物或其他工作物以及其他附着物，其所有权应当属于地上权人。

六、案例分析题

1、（1）大明公司的土地是划拨取得，只能用于公益，划拨土地非经批准，不得用于商业开发牟利，大明公司违反划拨地的用途未经批准改建写字楼，其写字楼是违章建筑。（2）由于写字楼是违章建筑，大明公司与通达公司合作建房协议的标的物即为不法，因此，合建协议无效，双方互相返还财产。

一、单项选择题

1、C 2、A 3、A 4、B 5、C 6、B 7、A 8、C 9、D 10、C

11、D 12、B 13、C 14、A 15、C 16、D 17、C 18、C 19、B 20、D

1、有关留置权，下列表述正确的是（ ）。

A、承运人为取得运费对承运的扶贫物资可行使留置权

B、保管人为取得保管费对保管的救灾物资可行使留置权

C、加工人为取得加工费对加工物可行使留置权

D、财产的侵占人因对该财产支付了修理费，所有人未支付修理费的情况下，侵占人可行使留置权

2、物权中，属于担保物权的有（ ）。

A. 留置权

B. 典权

C. 土地承包权

D. 国有土地使用权

3、下列财产中，不得抵押的是（ ）。

A. 土地所有权

B. 抵押人所有的房屋

C. 抵押人所有的机器

D. 在建工程

4、下列关于抵押合同的形式，正确的是（ ）。

A. 抵押合同可以口头订立

B. 抵押合同必须书面订立

C. 抵押合同口头、书面订立均可

D. 抵押合同可以采用书面合同以外的其他方式订立

5、以下列财产设定的抵押权中，协议生效的是（ ）。

A、房屋 B、航空器 C、电视 D、车辆

6、按照担保法的规定，下列合同中，可以附最高额抵押合同的是（）。

A、运输合同 B、借款合同 C、委托合同 D、合伙合同

第五十九条 本法所称最高额抵押，是指抵押人与抵押权人协议，在最高债权额限度内，以抵押物对一定期间内连续发生的债权作担保。

第六十条 借款合同可以附最高额抵押合同。

7、依照我国担保法的规定，下列财产中，可以抵押的是（）。

A、某大学的小汽车 B、自留山 C、某大学的教学楼 D、宅基地使用权

8、根据担保法的规定，质权分为（）。

A. 动产质权和不动产质权

B. 不动产质权和权利质权

C. 动产质权和权利质权

D. 不动产质权、动产质权和权利质权

9、下列关于权利质权的表述，不正确的是（）。

A. 汇票可以质押

B. 提单可以质押

C. 依法可以转让的股票可以质押

D. 公路渡口的收益权不可以质押

第七十五条 下列权利可以质押：

（一）汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；

（二）依法可以转让的股份、股票；

（三）依法可以转让的商标专用权，专利权、著作权中的财产权；

（四）依法可以质押的其他权利。

10、下列合同中，可以发生留置权的是（）。

A. 合伙合同 B. 买卖合同 C. 行纪合同（行纪合同是行纪人以自己的名义为委托人从事贸易或商务活动，由委托人支付报酬的合同”。购销、寄售或有价证券的买卖等法律行为）（保管、运输、加工承揽合同） D. 租赁合同

11、下列关于留置权的表述，正确的是（）。

A. 留置权是用益物权

B. 留置权是约定担保物权

C. 留置权是自物权

D. 留置权是法定担保物权

12、留置物所有人的财产被留置后，以该留置物为标的而向他人设定抵押权，关于受偿顺序的表述，正确的是（ ）。

A. 留置权与抵押权同时受偿

B. 留置权优先于抵押权受偿

C. 抵押权优先于留置权受偿

D. 何者优先受偿，取决于抵押权是否办理了登记

13、甲与乙签订借款合同，并与乙就自己的汽车出质给乙签订了字据，后甲未将该车按交付给乙，并将该车卖与了丙。后为此引起纠纷。下列选项正确的是（ ）。

A、丙不能取得该车的所有权，因为该车已质押给了乙

B、丙能取得该车的所有权，但乙可依质权向丙进行追偿

C、丙能取得该车的所有权，乙不能向丙要求返还该车

D、甲与乙之间的质权合同生效

14、甲因向乙借款将自己的汽车抵押与乙，并办理了抵押登记，后甲因丙借款，又将自己的汽车出质给丙。现甲无力还款，对该车，乙欲行使抵押权，丙欲行使质权，并引起纠纷。下列选项正确的是（ ）。

A、乙的抵押权优于丙的质权受偿

B、丙的质权优于乙的抵押权受偿

C、乙的抵押权与丙的质权按比例同时受偿

D、乙的抵押权与丙的质权谁先受偿应由他们抓阄决定

第七十九条 同一财产法定登记的抵押权与质权并存时，抵押权人优先于质权人受偿。

同一财产抵押权与留置权并存时，留置权人优先于抵押权人受偿。

15、甲向乙借款并将自己的房子抵押给乙，并办理了抵押登记。抵押后甲又将该房屋出租给丙，因甲无力还款，乙欲行使抵押权。下列表述正确的是（ ）。

A、甲与丙之间的租赁合同不具有效力，因为该房已抵押给乙

B、甲与丙之间的租赁合同具有效力，抵押权行使后租赁合同对新的受让人具有效力

C、甲与丙之间的租赁合同具有效力，但抵押权行使后租赁合同对新的受让人不具有效力

D、甲与丙之间的租赁合同效力未定

16、甲向乙借款并将自己的房屋抵押给乙，双方在合同中约定，乙的债权在期满后未受清偿时，该房屋的所有权为乙所有。下列表述正确的是（ ）。

- A、抵押合同无效
B、抵押合同内容全部有效
C、抵押合同为可撤销的合同
D、抵押合同有效，但房屋所有权为乙所有的条款无效

17、甲为一农民，因建房而向乙借款，双方约定，将自己承包的五亩及地上所种的小麦抵押给乙。因甲无力还款而引起纠纷。下列表述正确的是（ ）。

- A、该抵押合同全部有效
B、该抵押合同全部无效
C、该抵押合同中涉及小麦作为抵押物的条款有效
D、该抵押合同中涉及的五亩承包地作为抵押物的条款有效

第三十四条 下列财产可以抵押:

- (一) 抵押人所有的房屋和其他地上定着物；
- (二) 抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产；
- (三) 抵押人依法有权处分的国有的土地使用权、房屋和其他地上定着物；
- (四) 抵押人依法有权处分的国有的机器、交通运输工具和其他财产；
- (五) 抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权；
- (六) 依法可以抵押的其他财产。

19、甲向乙借款，约定以自己的皇冠车抵押与乙。双方为此签订了抵押合同，但在抵押登记时，登记为甲的奥迪车抵押给乙。因甲未能及时还款，乙欲行使抵押权。下列表述正确的是（ ）。

- A、乙只能对甲的皇冠车行使抵押权
- B、乙只能对甲的奥迪车行使抵押权
- C、乙是对皇冠车还是对奥迪车行使抵押权，由乙决定
- D、乙是对皇冠车还是对奥迪车行使抵押权，由甲决定

20、甲向乙借款，并约定将自己的奥迪车出质给乙，乙因自己不会开车，要求甲将该车开回。后甲向丙借款，又将该车出质给丙。丙对该车进行了占有。因甲无力还款而引起纠纷。乙丙均欲行使对该车的质权。下列表述正确的是（ ）。

- A、甲与丙之间的质押合同无效
B、甲与乙之间的质押合同生效
C、乙可对依法对抗丙的质权
D、乙对抗丙的质权人民法院不予支持

二、多项选择题

1、BC 2、AD 3、AD 4、CD 5、CD 6、ABC 7、BCD 8、CD 9、ABCD

10、ABCD 11、ABCD 12、ABD 13、ABCD 14、ABD 15、BD 16、BD

17、AD 18、AC 19、AC 20、BD

1、甲将一匹马租给乙，乙因向丙借款，又将该马出质给丙（丙并不知道乙不享有该马的所有权），因乙无力还款，丙欲对该马行使质权，遭甲反对，为此发生纠纷。下列选项正确的是（ ）。

- A、乙对该马享有出质权 B、丙对该马享有质权（善意）
C、乙对该马不享有出质权 D、丙对该马不享有质权

2、甲以其自有房屋作抵押向乙借款，并办理了抵押登记。在抵押期间，甲未通知乙，便将该房屋转让给丙，并办理了过户登记手续。对此，下列说法中，正确的有哪些？（ ）

- A、乙仍可以就该房屋行使抵押权
B、乙不得就该房屋行使抵押权
C、丙不能取得该房屋所有权
D、丙可以取得该房屋所有权

3、甲以自有的一批布匹作抵押向乙借款，未办理登记。在抵押期间，甲未通知乙，便将该批布匹卖给了丙，并已交货付款完毕。对此，下列说法中，正确的有哪些？（ ）

- A、甲与乙之间的抵押合同有效 B、丙无权取得对该批布匹的所有权
C、乙的抵押权可以对抗受让人丙的所有权 D、乙的抵押权不得对抗受让人丙的所有权

4、甲将自己的一批货物出质给乙，但乙将这批货物未放置在仓库里，而是放在露天，货物有毁坏灭失的可能，甲可以主张怎样的权利？（ ）

- A、有权要求将该批货物收回
B、有权要求解除该质押关系
C、有权要求提前清偿债权而返还质物
D、有权要求将质物提存

5、依我国《担保法》规定，选项所列合同中哪些合同债务人不履行债务的，债权人享有留置权？（ ）

- A、买卖合同 B、租赁合同 C、保管合同 D、加工承揽合同

6、1995年3月黄某将一幅价值6万元的名画送到某装裱店装裱，由于黄某未按期付给裱店费用。装裱店通知黄某应在30日内支付其应付的费用，但黄某仍未能按期交付，装裱店遂将画变价受偿，扣除了费用后，将其差额退还给黄某。下列表述正确的有（ ）。

- A、黄某与装裱店之间的合同系承揽合同
- B、装裱店对该画有留置权
- C、装裱店通知黄某支付费用的期限不符合法律规定
- D、装裱店通知黄某支付费用的期限符合法律规定

第八十七条 债权人与债务人应当在合同中约定，债权人留置财产后，债务人应当在不少于两个月的期限内履行债务。债权人与债务人在合同中未约定的，债权人留置债务人财产后，应当确定两个月以上的期限，通知债务人在该期限内履行债务。

债务人逾期仍不履行的，债权人可以与债务人协议以留置物折价，也可以依法拍卖、变卖留置物。

留置物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿。

7、根据我国担保法的规定，我国担保物权的类型包括（ ）。

- A、典权
- B、抵押权
- C、质权
- D、留置权

8、下列财产中，可以抵押的有（ ）。

- A、违章建筑物
- B、机关法人的公益性财产
- C、预购的房屋
- D、抵押人所有的汽车

9、抵押权所担保的范围包括（ ）。

- A、原债权
- B、原债权的利息
- C、抵押权实现的费用
- D、违约金或损害赔偿金

10、根据担保法的规定，下列财产设立抵押时，必须办理登记的是（ ）。ABCD

- A、房屋
- B、林木
- C、企业的设备
- D、船舶

11、下列关于抵押人权利的表述，正确的是（ ）。11、ABCD

- A、抵押人享有对抵押物的占有权
- B、抵押人不享有对抵押物的处分权
- C、抵押人可以对抵押物设立多项抵押权
- D、抵押人对抵押物享有处分权

12、抵押权终止的原因是（ ）。12、ABD

- A、主债权消灭 B、抵押物灭失
- C、抵押权人死亡 D、抵押权实现

13、下列权利中，可以设立质押的有（ ）。13、ABCD

- A、依法可以转让的商标专用权 B、依法可以转让的股票
- C、债券 D、公路桥梁等不动产收益权

14、甲向乙借款而以自己的房屋抵押与乙，双方签订了抵押合同，但因当地登记部门的原因而未登记。但甲将房屋的产权证交付与乙。后甲又以该产权证的复印件与丙签订了抵押合同，并办理了抵押登记。因甲无力还款引起纠纷。下列表述正确的有（ ）。14、ABD

- A、乙对甲的房屋享有抵押权 B、丙对甲的房屋享有抵押权
- C、乙优先于丙对甲的房屋行使抵押权 D、丙优先于乙对甲的房屋行使抵押权

16、甲乙为按份共有人，甲享有 70% 份额，乙享有 30% 份额。该共有物因与丙的财产发生附合而形成附合物，该附合物为甲乙丙共有。甲曾就其 70% 份额向丁借款设置抵押，并办理了相关手续，因甲无力还丁的借款而引起纠纷。下列表述正确的是（ ）。16、BD

- A、甲与丁之间的抵押无效 B、甲与丁之间的抵押有效
- C、丁的抵押权的效力及于该附合物全部
- D、丁的抵押权的效力只及于该附合物中甲之份额

17、甲向乙借款，将自己所有的受孕母牛出质于乙，质押期间，母牛产下牛犊。对于该牛犊下列表述正确的是（ ）。17、AD

- A、牛犊所有权归甲享有 B、牛犊所有权归乙享有
- C、甲可基于牛犊所有权享有牛犊占有返还请求权
- D、甲对牛犊虽享有所有权，但不享有牛犊占有返还请求权

18、甲向乙借款，将自己所有的皇冠车出质于乙，乙又将该车出租于丙，丙因违章驾驶造成该车灭失，为此引起纠纷。下列表述正确的是（ ）。18、AC

- A、乙无权将该车出租 B、乙有权将该车出租
- C、对该车的损失应由乙承担 D、对该车的损失应由乙丙负连带责任

19、甲向乙借款，将自己所有的奥迪车出质于乙，乙又擅自将该车转质于丙，丙因违章驾驶该车造成该车灭失，为此引起纠纷。下列表述正确的有（ ）。19、AC

- A、乙无权将该车转质 B、乙有权将该车转质

C、对该车的损失应由乙承担

D、对该车的损失应由乙丙负连带责任

20、甲从乙处偷来一台电视机，因故障送至丙处修理。丙修好后又被丁偷走。丙不知该电视机为赃物。甲到期未支付修理费而引起纠纷。下列表述正确的有（ ）。20、BD

A、丙对该电视机不享有留置权

B、丙对该电视机享有留置权

C、丙对丁不享有占有返还请求权

D、丙对丁享有占有返还请求权

三、名词解释

1、担保物权 2、抵押权 3、共同抵押 4、最高额抵押 5、财团抵押

6、质权 7、留置权

四、简答题

1、简述担保物权的特征。

2、简述动产质权人的权利。

五、论述题

1、试述留置权取得的条件。

六、案例分析题

1、甲因经商向乙借款 15 万元，甲用自己使用了一年的富康轿车（价值 5 万）抵押，双方签订了抵押合同并办理了抵押登记。一天，甲开车与他人相撞，保险公司支付保险金 5 万元，因车受损，乙向甲提出了如下的请求：（1）甲提供新的担保物；（2）甲要将 5 万元提存；（3）请求甲提前还款。案件诉讼到法院，乙的哪些请求不能成立？

1、（1）乙的第一项和第三项请求不能成立。

根据担保法第 51 条第 2 款的规定，抵押人对抵押物价值减少无过错的，抵押权人只能在抵押人因损害而得到的赔偿范围内要求提供担保，抵押物价值未减少的部分，仍作为债权的担保。据此，乙的第一项请求不能成立。（2）根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第 80 条第 2 款的规定，抵押物灭失、毁损或者被征用的情况下，抵押权所担保的债权未届清偿期的，抵押权人可以请求人民法院对保险金、赔偿金或补偿金等采取保全措施。据此，乙的第三项请求不能成立。

2、开元公司建设商住楼，建设中，因资金短缺，向银行贷款，双方签订的贷款协议约定：银行向开元公司贷款 2000 万元，开元公司以在建工程作抵押，到期不还，该在建工程归银行所有，充抵贷款。双方办理了抵押登记手续。同时，开元公司向大发公司借款 500 万元，开元公司以同一在建工程作抵押，为减少税费，双方签订了抵押借款合同，未办理抵押登记手续。后来开元公司向中原公司借款 300 万元，到期后，开元公司未能偿还上述三笔款项，除在建工程外又无其他财产，中原公司诉至法院，要求开元公司还款。银行和大发公司知道后，也起诉开元公司还款。银行认为，开元公司已约定，如不能偿还贷款，在建工程归银行所有充抵贷款。现还贷期已到，开元公司无力偿还，该在建工程应归银

行所有。大发公司认为，开元公司也以在建工程作抵押从大发公司借款，该抵押有效，大发公司应当优先于中原公司受偿。本案如何处理？

2、（1）按照担保法司法解释，**在建工程可以设立抵押**。（2）开元公司与银行的抵押进行了登记，故该抵押权有效成立，但由于双方在抵押合同中约定：开元公司到期不还贷款，该在建工程归银行所有。此为流质条款的约定，按照担保法，流质条款无效。银行因设定抵押享有优先受偿权，但不能直接将抵押物据为己有。（2）开元公司与大发公司签订了抵押合同，但因未进行登记，不具备对抗效力，开元公司应与中元公司按比例同等受偿，不存在先后问题。

3、**冯某**系养鸡专业户，为改建鸡舍和引进良种鸡需资金 20 万元。冯某向**陈某**借款 10 万元，以自己的一套价值 10 万元的音响设备抵押，双方立有抵押字据，但未办理登记。冯某又向**朱某**借款 10 万元，以该音响设备质押，双方立有质押字据，并将音响设备交付朱某占有。冯某得款后，改造了鸡舍，且与县**良种站**签订了良种鸡引进合同。合同约定良种鸡款共计 2 万元，冯某预付定金 4 千元，违约金按合同总额的 10 % 计算，冯某以销售肉鸡的款项偿还良种站的货款，合同没有明确约定合同的履行地点。后县良种站将良种鸡送交冯某，要求支付**运费**，冯某拒绝。因发生不可抗力事件，冯某预计的收入落空，冯某因不能及时偿还借款和支付货款而与陈某、朱某及县良种站发生纠纷。诉至法院后，法院查证上述事实后又查明：朱某在占有该设备期间，不慎将该设备损坏，送**蒋某**修理，朱某无力交付蒋某的修理费 1 万，该设备现已被蒋某留置。

现问：

（1）某与陈某之间的抵押关系是否有效？为什么？

（2）冯某与朱某之间的质押关系是否有效？为什么？

（3）朱某与蒋某之间存在什么法律关系？

（4）陈某要求对该音响设备行使抵押权，朱某要求行使质押权，蒋某要求行使留置权，应由谁优先行使其权利？为什么？

3、（1）冯某与陈某之间的抵押关系有效。根据《担保法》第 43 条，“当事人以其他财产抵押的，可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效。**当事人未办理抵押物登记的**，不得对抗第三人。”

（2）冯某与朱某之间质押关系有效。由于冯某与陈某之间的抵押合同未办理抵押物登记，抵押合同不得对抗第三人。根据《担保法》第 64 条，“出质人与质权人应当以书面形式订立质押合同。质押合同自质物移交于质权人**占有时生效**。”由于冯某与朱某之间双方立有质押字据，并将该设备交与朱某占有，故质押关系有效。

（3）朱某与蒋某之间存在承揽合同关系（修理合同关系）和**留置权**法律关系。

（4）对该设备，应由蒋某优先行使其权利。因为留置权是为了恢复标的物本身价值而发生的权利，在各担保权中应最优先。

参考答案

一、单项选择题

1、C 2、A 3、A 4、B 5、C 6、B 7、A 8、C 9、D 10、C

11、D 12、B 13、C 14、A 15、C 16、D 17、C 18、C 19、B 20、D

二、多项选择题

1、BC 2、AD 3、AD 4、CD 5、CD 6、ABC 7、BCD 8、CD 9、ABCD

10、ABCD 11、ABCD 12、ABD 13、ABCD 14、ABD 15、BD 16、BD

17、AD 18、AC 19、AC 20、BD

三、名词解释

1、担保物权是与用益物权相对应的他物权，指的是为确保债权的实现而设定的，以直接取得或者支配特定财产的交换价值为内容的权利。

2、抵押权是对于债务人或第三人不移转占有而供担保的不动产及其他财产，优先清偿其债权的权利。

3、共同抵押是为同一债权就数个物设定的抵押。在共同抵押中，数个物并不是本身结合而视为一物，而是在担保同一债权的目的上互相结合担保债权。

4、最高额抵押是对于将来发生的债权，预先确定一最高的限度设定的抵押权。

5、财团抵押是将企业现有的财产，包括动产、不动产及其他权利视为一个整体，于其上成立的抵押权。

6、质权是指为了担保债权的履行，债务人或第三人将其动产或权利移交债权人占有，当债务人不履行债务时，债权人有权就其占有的财产优先受偿的权利。

7、留置权是债权人按照合同约定占有债务人的财产，在债务人逾期不履行债务时，有留置该财产，并就该财产优先受偿的权利。

四、简答题

1、（1）担保物权以确保债务的履行为目的。担保物权的设立，是为了保证主债权债务的履行，使得债权人对于担保财产享有优先受偿权，所以它是对主债权效力的加强和补充。（2）担保物权是在债务人或第三人的特定财产上设定的权利。担保物权的标的物，必须是特定物（抵押物可以为不动产、动产，质权、留置权则为动产），否则就无从由其价值中优先受清偿。（3）担保物权以支配担保物的价值为内容，属于物权的一种，与一般物权具有同一性质。所不同的是，一般物权以对标的物实体的占有、使用、收益、处分为目的，而担保物权则以标的物的价值确保债权的清偿为目的，以就标的物取得一定的价值为内容。（4）担保物权具有从属性和不可分性。其从属性，是指担保物权以主债的成立为前提，随主债的转移而转移，并随主债的消灭而消灭。其担保物权的不可分性，是指担保物权所担保的债权的债权人得就担保物的全部行使其权利。这体现在：债权一部分消灭，如清偿、让与，债权人仍就未清偿债权部分对担保物全部行使其权利；担保物一部分灭失，残存部分仍担保债权全部；分期履行的债权，已届履行期的部分未履行时，债权人就全部担保物有优先受偿权；担保物权设定后，担保物价格上涨，债务人无权要求减少担保物，反之，担保物价格下跌，债务人也无提供补充担保的义务。

2、动产质权，是以动产为其标的物的质权。动产质权人的权利包括：（1）占有质物。对质物的占有，既是质权的成立要件，也是质权的存续要件，质权人有权在债权受清偿前占有质物。（2）收取孳息。质权人有权收取质物的孳息，但质权合同另有约定的除外。质权人收取的孳息应当先充抵收取孳息的费用。（3）

质权的保全。质物有损坏或价值明显减少的可能，足以危害质权人权利的，质权人可以要求出质人提供相应的担保。出质人不提供的，质权人可以拍卖或变卖质物，并与出质人协议，将拍卖或变卖所得的价款用于提前清偿所担保的债权，或向与出质人约定的第三人提存。（4）优先受偿，债务履行期届满，质权人未受清偿的，可以与出质人协议以质物折价，也可以依法拍卖、变卖质物。质物折价或拍卖、变卖以后，其价款超过债权数额的部分归出质人所有，不足部分由债务人清偿。

五、论述题

1、留置权的取得条件可以分为积极要件和消极要件。

留置权取得的积极要件，是留置权的取得所应具有的事实。这主要有以下几项：（1）须债权人占有债务人的动产。留置权的目的是，在于担保债的履行，因此享有留置权的应当是债权人。至于债权的发生原因，依《担保法》第84条的规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人享有留置权。留置权的取得，债权人须合法占有债务人的财产，其占有方式不论是直接占有还是间接占有均可。但单纯的持有，不为占有，故不能成立留置权。（2）须债权已届清偿期。债权人虽占有债务人的动产，但在债权尚未届清偿期时，因此时尚不发生债务人不履行债务的问题，不发生留置权。只有在债权已届清偿期，债务人仍不履行债务时，债权人才可以留置债务人的动产。（3）须债权的发生与该动产有牵连关系。债权人所占有的债务人的动产必须与其债权的发生有牵连关系，才有留置权可言。即债权与标的物的占有的取得是基于同一合同关系。在债权的发生与标的物的占有取得是因同一合同关系而发生，并且债务人不履行债务时，债权人有留置权。由于留置权所担保的债权与留置物有牵连关系，故而与留置权有牵连关系的债权，都在留置权所担保的范围之内，包括原债权、利息（包括迟延履行利息）、实行留置权的费用及因留置物的瑕疵给留置权人造成的损害赔偿请求权。而留置物的范围，除了留置物本身外，还包括其从物、孳息和代位物。

留置权取得的消极条件：（1）对动产的占有不是因侵权行为取得。留置权的取得，以对债务人的动产的占有为前提，但其占有必须是合法占有。如果是因侵权行为占有他人的动产，不发生留置权。（2）对动产的留置不违反公共利益或善良风俗。对动产的留置如果违反公共利益或善良风俗。（3）对动产的留置不得与债权人的义务相抵触。债权人留置债务人的动产如果与其所承担的义务相抵触时，亦不得为之。

六、案例分析题

1、（1）乙的第一项和第三项请求不能成立。

根据担保法第51条第2款的规定，抵押人对抵押物价值减少无过错的，抵押权人只能在抵押人因损害而得到的赔偿范围内要求提供担保，抵押物价值未减少的部分，仍作为债权的担保。据此，乙的第一项请求不能成立。（2）根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第80条第2款的规定，抵押物灭失、毁损或者被征用的情况下，抵押权所担保的债权未届清偿期的，抵押权人可以请求人民法院对保险金、赔偿金或补偿金等采取保全措施。据此，乙的第三项请求不能成立。

2、（1）按照担保法司法解释，在建工程可以设立抵押。（2）开元公司与银行的抵押进行了登记，故该抵押权有效成立，但由于双方在抵押合同中约定：开元公司到期不还贷款，该在建工程归银行所有。此为流质条款的约定，按照担保法，流质条款无效。银行因设定抵押享有优先受偿权，但不能直接将抵押物据为己有。（2）开元公司与大发公司签订了抵押合同，但因未进行登记，抵押物又是不动产，故该抵押权不成立，开元公司应与中元公司同等受偿，不存在先后问题。

3、（1）冯某与陈某之间的抵押关系有效。根据《担保法》第43条，“当事人以其他财产抵押的，可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效。当事人未办理抵押物登记的，不得对抗第三人。”

（2）冯某与朱某之间质押关系有效。由于冯某与陈某之间的抵押合同未办理抵押物登记，抵押合同不得对抗第三人。根据《担保法》第64条，“出质人与质权人应当以书面形式订立质押合同。质押合同自质物移交于质权人占有时生效。”由于冯某与朱某之间双方立有质押字据，并将该设备交与朱某占有，故质押关系有效。

（3）朱某与蒋某之间存在承揽合同关系（修理合同关系）和留置权法律关系。

（4）对该设备，应由蒋某优先行使其权利。因为留置权是为了恢复标的物本身价值而发生的权利，在各担保权中应最优先。

15、甲企业向乙丙借款，将自己的房屋分别抵押与乙丙，并先后办理了抵押权登记，乙的抵押权登记在先，丙的抵押权登记在后。后因乙企业兼并甲企业。下列表述正确的有（ ）。15、BD

A、乙企业对甲企业享有的抵押权因混同而消灭

B、乙企业对甲企业享有的抵押权不因混同而消灭

C、乙企业因混同而使抵押权消灭，故该房屋由丙企业行使抵押权

D、乙企业不因混同而使抵押权消灭，故其可以以登记在先的抵押权对抗丙企业的抵押权